

中国



法院 2025 年度案例

国家法官学院 最高人民法院司法案例研究院 / 编

劳动纠纷
(含社会保险纠纷)

中国法治出版社
CHINA LEGAL PUBLISHING HOUSE

《中国法院2025年度案例》通讯编辑名单

刘晓虹	北京市高级人民法院	唐 竞	湖南省高级人民法院
王 凯	北京市高级人民法院	邵静红	广东省高级人民法院
张 荷	天津市高级人民法院	邹尚忠	广西壮族自治区高级人民法院
徐翠翠	河北省高级人民法院	韦丹萍	广西壮族自治区高级人民法院
崔铮亮	山西省高级人民法院	黄文楠	海南省高级人民法院
杨钰奇	内蒙古自治区高级人民法院	吴 小	重庆市高级人民法院
张 健	辽宁省高级人民法院	任 梦	四川省高级人民法院
苏 浩	吉林省高级人民法院	颜 源	贵州省高级人民法院
桑 松	黑龙江省高级人民法院	戚 雷	贵州省贵阳市中级人民法院
张 蕾	上海市高级人民法院	李丽玲	云南省高级人民法院
左一凡	江苏省高级人民法院	赵鸿章	云南省昆明市中级人民法院
冯禹源	江苏省南通市中级人民法院	索朗达杰	西藏自治区高级人民法院
宋婉龄	江苏省无锡市中级人民法院	郑亚非	陕西省高级人民法院
李 波	浙江省高级人民法院	吴 莹	甘肃省高级人民法院
刘伟玲	安徽省高级人民法院	王 晶	青海省高级人民法院
林冬颖	福建省高级人民法院	马博文	宁夏回族自治区高级人民法院
杨云欣	江西省高级人民法院	石孝能	新疆维吾尔自治区高级人民法院
李璐璐	山东省高级人民法院	李 冰	新疆维吾尔自治区高级人民法院 生产建设兵团分院
卓峻帆	河南省高级人民法院		
吴 杨	湖北省高级人民法院		

序

为深入学习贯彻习近平法治思想，落实习近平总书记“一个案例胜过一打文件”的重要指示精神，人民法院始终把完善中国特色案例制度，加强以案释法作为推进全面依法治国、支撑和服务中国式现代化的重要途径。人民法院案例库向社会开放一年多来，最高人民法院始终坚持高标准建设，实现入库案例对常见案由和罪名全覆盖，对于促进法律适用统一，实现严格公正司法发挥了重要作用。

“中国法院年度案例系列”丛书以及时记录人民法院司法审判工作新发展、新成就为己任，通过总结提炼典型案例的裁判规则、裁判方法和裁判理念，发挥案例鲜活生动、针对性强的优势，以案释法，以点带面，有针对性地阐释法律条文和立法精神，促进社会公众通过案例更加方便地学习法律，领悟法治精神，体现司法规范、指导、评价、引领的重要作用，大力弘扬社会主义核心价值观，积极服务人民法院案例库建设，加强对案例库案例的研究，促进统一法律适用，提升审判质效，丰富实践法学研究，增强全民法治意识和法治素养，展现新时代我国法治建设新成就。

“中国法院年度案例系列”丛书自2012年编辑出版以来，已连续出版13年，受到读者广泛好评。为更加全面地反映我国司法审判执行工作的发展进程，顺应审判执行实践需要，响应读者需求，丛书于2014年度新增金融纠纷、行政纠纷、刑事案例3个分册，2015年度将刑事案例调整为刑法总则案例、刑法分则案例2个分册，2016年度新增知识产权纠纷分册，2017年度新增执行案例分册，2018年度将刑事案例扩充为4个分册，2022年度将土地纠纷(含林地纠纷)分册改为土地纠纷(含环境资源纠纷)分册。自2020年起，丛书由国家法官学院与最高人民法院司法案例研究院共同编辑，每年年初定期出版。在全国各级人民法院的大力支持下，丛书编委会现编辑出版《中国法院2025年度案

例系列》丛书，共23册。

“中国法院年度案例系列”丛书以开放务实的态度、简洁明快的风格，在编辑过程中坚持以下方法，努力让案例书籍“好读有用”：一是高度提炼案例内容，控制案例篇幅，每个案例字数基本在3000字左右；二是突出争议焦点，力求在有限的篇幅内为读者提供更多有效信息，便于读者快速抓取案例要点；三是注重释法说理，案例由法官撰写“法官后语”，高度提炼、总结案例的指导价值，引发读者思考，为司法审判提供借鉴，为法学研究提供启迪。

“中国法院年度案例系列”丛书编辑工作坚持以下原则：一是以研究案例库案例为首要任务。自2024年起，“中国法院年度案例系列”丛书优先选用人民法院案例库案例作为研究对象，力求对案例库案例裁判要旨的基本内涵、价值导向、法理基础、适用要点等进行深入分析，增强丛书的权威性、参考性。二是广泛选编案例。国家法官学院和最高人民法院司法案例研究院每年通过各高级人民法院从辖区法院汇集上一年度审结的典型案​​例近万件，使丛书有广泛的精选基础，通过优中选优，可提供给读者新近发生的多种类型的典型、疑难案例。三是方便读者检索。丛书坚持以读者为本，做到分卷细化，每卷案例主要根据案由或罪名分类编排，每个案例用一句话概括裁判要旨或焦点问题作为主标题，让读者一目了然，迅速找到目标案例。

中国法治出版社始终全力支持“中国法院年度案例系列”丛书的出版，给了编者巨大的鼓励。2025年，丛书将继续提供数据库增值服务。购买本系列丛书，扫描腰封二维码，即可在本年度免费查阅往年同类案例数据库。我们在此谨表谢忱，并希望通过共同努力，逐步完善，做得更好，探索出一条充分挖掘好、宣传好人民法院案例库案例和其他典型案例价值的新路，为广大法律工作者和社会公众提供权威、鲜活、精准的办案参考、研究素材，更好地服务司法审判实践、服务法学教育研究、服务法治中国建设。

“中国法院年度案例系列”丛书既是法官、检察官、律师等法律工作者的办案参考和司法人员培训辅助教材，也是社会大众学法用法的经典案例读本，同时为教学科研机构开展案例研究提供了良好的系列素材。当然，编者们在编

写过程中也难以一步到位实现目标愿景，客观上会存在各种不足甚至错误，欢迎读者批评指正。我们诚心听取各方建议，立足提质增效，不断拓宽司法案例研究领域，创新司法案例研究方法，助推实现中国特色司法案例研究事业的高质量发展。

国家法官学院 最高人民法院司法案例研究院

2025年3月

目 录

Contents

一、确认劳动关系

1. 以用工事实与用工合意二要素认定劳动关系	1
——冯某诉某餐饮公司劳动合同案	
2. 跨境用工中劳动关系及工资标准的司法认定	6
——某科技公司诉杨某劳动争议案	
3. 新业态用工模式下劳动关系的认定标准	11
——王某诉某货运公司劳动争议案	
4. 在校学生假期实习期间担任“网络主播”劳动关系的认定	16
——张某诉某传媒公司劳务合同案	
5. 投资人与企业之间劳动关系的认定	20
——某科技公司诉宋某劳动争议案	
6. 企业与投资人之妻订立劳务外包协议，劳务提供者与企业是否成 立劳动关系的认定	26
——陈某诉某清洁服务部劳动争议案	
7. 公司高级管理人员劳动关系的认定	30
——李甲诉某投资公司劳动合同案	

2 中国法院2025年度案例·劳动纠纷(含社会保险纠纷)

8. 用人单位与超龄劳动者之间的用工关系及工伤保险责任的认定	35
——杨某甲等诉某劳务公司劳动争议案	
9. 逐月领取退役金的退役军人是否符合劳动者身份的认定	40
——孙某诉某装饰公司劳动争议案	
10. 确认劳动关系应以“事实优先”为原则,且兵团职工可以建立 双重劳动关系	45
——乔某诉某物资公司劳动争议案	
11. 共享用工三方法律关系认定标准及司法适用	53
——胡某诉某服务公司确认劳动关系案	
12. 关联公司混同用工模式下劳动关系的确认	59
——郑某诉甲科技公司劳动争议案	
13. 承包人与实际施工人招用的工人之间劳动关系的认定	63
——黄某甲诉某电力建设公司、吴某劳动合同案	
14. 未签订劳动合同情况下,挂靠经营模式中的劳动关系主体认定	69
——某体育发展公司诉董某、某体育文化中心劳动争议案	
15. 超过仲裁时效后义务人同意履行,诉讼时效重新计算	77
——廖某诉某塑料机械厂劳动争议案	

二、劳动合同的订立

16. 《实习协议》内容符合劳动合同法律特征,应认定为劳动合同 关系	83
——郭某诉某文化公司、某文化公司分公司劳动争议案	
17. 事业单位聘用合同的订立规则	88
——周某诉某小学人事争议案	

三、劳动合同的履行和变更

18. 出差在途时间占用休息日或法定节假日的加班工资认定	92
——郑某诉某科技公司劳动争议案	
19. 公司因出差给予的补助和调休是否可以代替加班费	96
——王某诉某机械公司劳动争议案	
20. 网络在线形式“加班”的认定标准	101
——曹某诉某管理公司劳动争议案	
21. 提成工资中“款到提成”的效力认定	106
——某广告公司诉文某劳动争议案	
22.“待公司账户解封后支付工资”的约定无效	111
——L公司诉马某劳动争议案	
23. 工资异议期条款的效力认定	115
——赵某诉某信息公司劳动争议案	
24. 未订立书面劳动合同应付二倍工资差额诉讼时效的认定	120
——朱某诉某环卫服务中心劳动争议案	
25. 劳动者主张停工留薪期内二倍工资的不予支持	125
——孙某诉某速运公司劳动争议案	
26. 劳动合同约定不明情形下劳动者因本人原因致用人单位损失的 赔偿责任认定	128
——某保安公司诉胡某、罗某劳动争议案	
27. 电子合同中“一签多用”情形下格式条款提示说明义务的认定	133
——某顾问公司诉张某劳动争议案	
28. 劳动合同履行过程中劳动者达到法定退休年龄后的用工关系认定	139
——文乙诉某演艺经纪公司劳动争议案	

4 中国法院2025年度案例·劳动纠纷(含社会保险纠纷)

29. 人事争议中对双方签订《服务协议》性质及违约金数额的认定	144
——某医院诉罗某人事争议案	
30. 未续签劳动合同继续履行的法律后果	148
——海某诉某策划公司劳动争议案	
31. 用人单位单方调整劳动者工作地点的效力	153
——秦某诉某房地产公司劳动合同案	
32. 用人单位单方调整劳动者岗位是否合法的认定	158
——李某诉某体育公司劳动争议案	
33. 用人单位调岗行为存在程序瑕疵不影响实体合法性	163
——臧某诉某休闲用品公司劳动争议案	
34. 合理界定待岗适用范围, 尊重用人单位自主管理权	168
——孟某诉某配件公司劳动争议案	
35. 劳动者重大技术调岗后用人单位应适当履行培训义务	172
——李某诉某稀有金属公司劳动争议案	
36. 附条件的薪酬条款变更的法律效力认定	177
——某化妆品公司诉黄某劳动争议案	
37.“ 长期两不找” 状态下劳动关系的认定	183
——喻某诉某机械公司劳动争议案	
38. 劳动者在休息时间未能及时回复公司微信不能按照规章制度处罚	189
——王某诉某技术公司劳动争议案	
39. 下属无理举报上司是否属于严重违反公司规章制度	194
——曾某诉某器材公司劳动争议案	
40. 用人单位与其工会委员会在劳动者违反公司规章制度调查程序 中应保持相对独立	198
——某水泥公司诉傅某经济补偿金案	

41. 用人单位对劳动者追偿权比例的确定 202
—— 某建设工程公司诉卢某劳动争议案

四、劳动合同的解除和终止

42. 劳动者离职前年终奖发放应当综合离职原因、时间及工作表现认定 207
—— 李某诉某电气公司劳动争议案

43. 劳动者提供虚假病历“骗取”病假有违诚实信用，用人单位可
依法解除劳动合同 211
—— 某运输公司诉高某劳动争议案

44. 经济性裁员单位报告义务瑕疵不影响经济性裁员有效性 217
—— 某汽车配件公司诉王某劳动合同案

45. 以员工拒绝企业外调岗致旷工为由解除劳动关系行为认定 222
—— 蒲某诉甲百货公司劳动争议案

46. 用人单位在法律规定以外创设劳动合同解除条件效力的认定 227
—— 某房地产公司诉康某劳动争议案

47. 用人单位截取劳动者在特定时间节点的脱岗状态以证明劳动者
存在旷工行为的不予采纳 233
—— 曹某诉某生活服务公司劳动争议案

五、竞业限制

48. 劳动者违反竞业限制期间报告义务的违约责任的认定 238
—— 某软件公司诉黄某劳动争议案

49. 违反竞业限制义务的认定标准 242
—— 某供应链公司诉邱某劳动争议案

6 中国法院2025年度案例 · 劳动纠纷(含社会保险纠纷)

50. 用人单位以停付竞业补偿金的方式豁免竞业禁止义务的效力认定	248
—— 某科技公司诉盛某劳动争议案	
51. 用人单位约定劳动者工资中包含竞业限制经济补偿认定规则	252
——王某诉某科技公司劳动争议案	
52. 离职竞业限制协议合意的司法认定	257
—— 甲服务公司诉耿某竞业限制案	
53. 应从竞业限制到期日计算经济补偿金的仲裁时效起算点	262
—— 吴某诉某科技公司劳动争议案	

六、社会保险

54. 工伤认定中“因履行工作职责受到暴力伤害”的认定	267
—— 王某某诉某区人民政府改变原行政行为的行政复议案	
55. 第三人侵权的工伤事故中已判赔但未执行到位的重复项目赔偿 款不应抵扣	272
—— 熊某诉鲜某工伤保险待遇案 ·	
56. 工伤员工仲裁期间死亡,用人单位是否仍须支付“三个一次性” 补助金	278
—— 某保安公司诉王某乙工伤保险待遇案	
57. 交通事故与工伤竞合时,劳动者能否获得双重赔偿	284
—— 某机械公司诉肖某2劳动争议案	
58. 用人单位违法解雇孕期女职工应赔偿生育津贴损失	291
—— 张某诉某科技公司劳动争议案	

七、劳务派遣

59. 劳务派遣单位与劳动者是否应签订无固定期限劳动合同的认定 297
——某人力资源公司诉彭某劳动合同案
60. 违反“三性”要求的劳务派遣法律关系的认定 301
——郑某诉某人力资源公司等劳动争议案
61. 未取得劳务派遣许可对工伤认定的裁判思路 308
——杨某诉某市人力资源和社会保障局工伤保险资格认定案

八、劳动争议仲裁

62. 劳动者和用人单位分别对“一裁终局”裁决提起诉讼、申请撤销下，基层法院“一并审理”的审查范围 314
——赵某诉某人力资源公司劳动争议案
63. 当事人就仲裁时效抗辩未在劳动仲裁阶段提出而在诉讼阶段提出情形下的司法认定 320
——潘某诉某房地产公司追索劳动报酬案

一、确认劳动关系

1

以用工事实与用工合意二要素认定劳动关系

——冯某诉某餐饮公司劳动合同案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

上海市第一中级人民法院(2023)沪01民终2827号民事判决书

2. 案由：劳动合同纠纷

3. 当事人

原告(上诉人):冯某

被告(被上诉人):某餐饮公司

第三人:张某、沈某

【基本案情】

2020年11月16日,冯某经张某招聘至某餐饮公司经营的酒家厨房工作。

2020年12月至2021年10月,除某餐饮公司法定代表人朱某于2020年12月以及案外人“华先生”于2021年5月向冯某转账两笔款项外,冯某的报酬主要由张某、沈某支付。

2021年1月至2022年2月,朱某向沈某或张某转账数十笔,其中2021年

11月之前大多附言为工资，其后大多附言为承包款。

冯某请求法院判令：(1)某餐饮公司支付2020年12月17日至2021年10月26日未签订书面劳动合同二倍工资差额94137元；(2)某餐饮公司支付2020年11月16日至2021年10月26日休息日加班工资55861.65元、法定节假日加班工资9930.96元，共计65792.61元；(3)某餐饮公司支付违法解除劳动合同关系赔偿金18000元。某餐饮公司不同意冯某的诉讼请求。

一审中，某餐饮公司提供了其与张某、沈某签订的承包期限为2020年11月1日至2022年10月31日后厨承包协议。冯某未就后厨承包协议签章形成时间申请司法鉴定。

二审中，冯某陈述，平时系由张某、沈某、朱某对其进行工作安排，亦是张某对其实施了解除劳动合同行为；除诉请款项外，在职期间的正常报酬已发放；冯某另申请对后厨承包协议签章形成时间申请司法鉴定。法庭询问，冯某提供的微信聊天记录是否存在朱某直接对其安排工作或者进行管理的内容，冯某表示未找到相关内容，某餐饮公司与张某、沈某均陈述，双方不存在劳动关系，某餐饮公司未为其二人缴纳社会保险费等。

【案件焦点】

冯某与某餐饮公司之间是否存在劳动关系。

【法院裁判要旨】^①

上海市松江区人民法院经审理认为：判断冯某、某餐饮公司之间是否存在劳动关系关键在于双方是否符合劳动关系中用工的从属性特征。本案中，某餐饮公司称其将后厨发包给了张某、沈某并提供了后厨承包协议、委托书及银行明细等证据，张某、沈某对此予以认可，冯某虽对此不予认可，但未提供相反的证据予以推翻，故法院采信某餐饮公司的意见。冯某虽提供了考勤表、收入证明、微信聊天记录、对话视频等证据，但某餐饮公司对此均不予认可，且根

^①本书【法院裁判要旨】适用的法律法规等条文均为案件裁判当时有效，下文不再对此进行提示。

据冯某的陈述，收入证明系由案外人盖章，冯某未能证明系由某餐饮公司出具，其余证据均难以显示冯某、某餐饮公司之间存在从属性，故均不予采纳。结合冯某系由张某、沈某招聘、安排工作及考勤管理，冯某的工资大部分系由张某、沈某发放的事实，难称冯某、某餐饮公司之间存在劳动关系，故对于冯某基于劳动关系所主张的二倍工资差额、加班工资、违法解除劳动关系赔偿金，均不予支持。

上海市松江区人民法院依照《中华人民共和国劳动法》第七十八条规定，判决如下：

驳回冯某的全部诉讼请求。

冯某不服一审判决，提起上诉。上海市第一中级人民法院经审理认为：根据法律规定，劳动关系自用工之日起建立。用人单位是否对劳动者进行过用工，应从经济从属性以及管理从属性上进行判断。本案中，冯某的报酬主要由张某、沈某支付。虽然朱某曾于2020年12月以及案外人“华先生”曾于2021年5月向冯某转账两笔款项，但就转账原因，某餐饮公司以及张某、沈某均进行了解释，上述解释亦能与朱某未在2020年12月向两人转账以及2021年5月向两人转账金额明显低于其他月份的事实相印证，更具盖然性，法院予以采纳。综上，难称冯某之于某餐饮公司存在经济从属性。另外，冯某的招录、管理、解聘均由张某、沈某具体实施，在案证据难以显示相关行为系该二人的职务行为或受托行为，冯某亦未提供证据证明朱某或某餐饮公司其他员工对其进行过用工管理，故亦难认定冯某之于某餐饮公司存在管理从属性。综上，冯某工作的场所虽然位于某餐饮公司经营的饭店，但难以认定某餐饮公司对其进行了用工。冯某主张双方存在劳动关系，缺乏依据，法院难以采纳。

冯某否认某餐饮公司与张某、沈某存在承包关系，于二审中对后厨承包协议签章形成时间申请司法鉴定。关于该协议真实性的争点在一审中已经形成，冯某申请司法鉴定，应根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第一百二十一条第一款的规定，在举证期限届满前提出。另外，根据法院另查明的朱某与张某、沈某的转账明细，就款项的金额、频率、

部分明细而言,更符合承包结算而非工资代发的特征。故而,无论上述协议是
否倒签,均难以推翻承包关系的事实。综上,法院对冯某的鉴定申请不予准许。
关于本案的其他争执,一审法院已详尽阐述并据以认定,二审法院予以认同,
不再赘述。综上所述,冯某基于劳动关系而主张的各项上诉请求缺乏依据,难
以支持;一审判决并无不当,应予维持。

上海市第一中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十
七条第一款第一项规定,判决如下:

驳回上诉,维持原判。

【法官后语】^①

实践中,关于餐饮企业与后厨工作人员之间的用工形态,通常呈现出直接
用工与劳务外包两种。后厨工作人员的流动性较大,通常不与餐饮企业签订书
面合同,该类人员离职后与餐饮企业产生的劳动合同纠纷,通常以双方是否存
在劳动关系为主要争议焦点。本文将用工事实与用工合意二要素阐述该类案
件中认定劳动关系的思路。

一、餐饮企业直接用工与劳务外包两种用工形态

餐饮企业的后厨普遍存在两种用工形态。一是直接用工,即餐饮企业直接
聘用后厨工作人员。本案中,冯某主张即如是。冯某主张,某餐饮公司与张
某、沈某之间系劳动关系,张某、沈某与冯某之间系上下级关系,冯某与某
餐饮公司之间系劳动关系,张某、沈某招用并管理冯某系职务行为。二是劳
务外包,即餐饮企业将经营后厨事宜全部或部分发包给第三方,由第三方招
用并管理后厨工作人员。本案中,某餐饮公司主张即如是。某餐饮公司主张,
某餐饮公司与张某、沈某之间系承包关系,张某、沈某与冯某之间系劳务关系,
冯某与某餐饮公司之间无直接的法律关系,某餐饮公司向冯某转账款项系代发
工资。

^①本书【法官后语】对此类法律问题涉及的法律法规等内容进行了时效性更新,下文不再对此进行提示。

二、用工事实与用工合意二要素的适用规则

《中华人民共和国劳动合同法》第七条规定：“用人单位自用工之日起即与劳动者建立劳动关系。用人单位应当建立职工名册备查。”对于《中华人民共和国劳动合同法》第七条第一句完整的解读应当是：“囿于劳动者举证能力弱，只要其能证明存在用工的事实，法律就推定其与用人单位存在建立劳动关系的意思表示并就此达成合意，而无需其就此举证证明。”^①笔者认为，餐饮企业，尤其是一些小微餐饮企业，基于经营策略或成本的考量，人员流动较其他类型企业更为频繁。对于餐饮企业后厨工作人员劳动关系的认定，应从用工事实与用工合意两方面综合考量。一方面，若根据后厨工作人员的举证，能够明确是否存在用工事实，则可直接得出后厨工作人员与餐饮企业是否存在劳动关系。另一方面，法院应充分审查形成用工时各方当事人的真实意思，从而认定后厨工作人员究竟是和餐饮企业形成劳动关系还是与第三方形成劳务关系。

首先，从用工事实的角度判断。判断是否存在用工事实的关键在于判断当事人之间是否具有从属性特征。根据各种理论，从属性一般分为人身从属性、经济从属性、管理从属性、组织从属性等。鉴于后厨工作人员的工作职位、工作处所、工资发放、工作管理等必然会与某餐饮公司存在或多或少的联系，而判断此种联系的强弱是判断二者是否具有从属性的关键。本案中，冯某显然与张某、沈某之间的联系更为紧密，故而法院认定冯某之于某餐饮公司不存在从属性。

其次，从用工合意的角度判断。实践中，后厨工作人员通常不与餐饮企业签订书面合同，且关于留存用工合意方面的证据意识较为薄弱。因此，诉讼中后厨工作人员往往缺乏证明用工合意的直接证据。若有其他证据显示后厨工作人员与第三方形成了用工合意，则应按照当事人之间的真实意思认定相关法律关系。本案中，冯某未与某餐饮公司签订劳动合同，而某餐饮公司提供了其与张某、沈某签订的后厨承包合同，法院结合查明的事实认定某餐饮公司与张某、

^①最高人民法院民事审判第一庭编著：《最高人民法院新劳动争议司法解释（一）理解与适用》，人民法院出版社2021年版，第36页。

沈某之间更符合承包关系，再结合冯某由张某、沈某招用并管理的事实，从侧面反映出实际上冯某与张某、沈某之间存在用工合意，而非与某餐饮公司之间存在用工合意。

编写人：上海市松江区人民法院 蔡丽萍

跨境用工中劳动关系及工资标准的司法认定

—— 某科技公司诉杨某劳动争议案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

广东省珠海市中级人民法院(2023)粤04民终2115号民事判决书

2. 案由：劳动争议

3. 当事人

原告(上诉人): 某科技公司

被告(上诉人): 杨某

【基本案情】

杨某于2017年4月10日与某科技公司签订了劳动合同，约定劳动合同期限为1年。同年6月13日，杨某与我国澳门特别行政区雇主“某鱼栏—黄某”签订了劳动合同。杨某与某科技公司之间的劳动合同期满后，双方未续签合同，但某科技公司自2017年4月至2021年4月以人民币、澳门币或人民币+澳门币的形式向其发放工资并为其缴纳社保。杨某大部分时间在某科技公司上班，有时前往某鱼栏对其员工使用管理系统进行调研。2021年4月22日，某科技公司向杨某发出移交工作日志、软件开发日志的通知；杨某自同年5月18日后未

再回某科技公司或某鱼栏上班。某科技公司与某鱼栏系在内地及澳门分别注册成立的独立商事主体，二者在人员管理、经营业务上存在高度重合，属于关联企业。杨某、某科技公司之间的劳动争议经劳动仲裁后，某科技公司以双方之间自2017年6月13日起不存在劳动关系为由，起诉至人民法院判令其无须向杨某支付2021年2月1日至5月18日的工资和违法解除劳动合同赔偿金。杨某对劳动仲裁认定的工资标准有异议，随后亦起诉至同一法院。

【案件焦点】

1. 杨某是与某科技公司还是与某鱼栏之间成立劳动关系；2. 用人单位采用不同币种单独或合并向劳动者支付工资的，违法解除劳动合同的赔偿金基数如何确定。

【法院裁判要旨】

横琴粤澳深度合作区人民法院经审理认为：本案杨某的工作地点涉及我国澳门特别行政区，根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉若干问题的解释（一）》第一条第四项、第十七条规定，应参照涉外民事关系确定法律适用。鉴于本案为劳动争议纠纷，杨某的劳动工作地主要在内地，故依照《中华人民共和国民事诉讼法》第四十三条规定，本案适用我国内地法律。

第一，关于2017年6月13日至2021年5月18日某科技公司与杨某之间是否存在劳动关系的问题。尽管某科技公司与杨某在劳动合同期满后未续签，但杨某在此期间受某科技公司管理并从事某科技公司安排的有酬劳动，且接受社保的缴纳，符合原劳动和社会保障部《关于确立劳动关系有关事项的通知》第一条关于劳动关系成立的规定。内地现行法律未禁止劳动者与两家企业主体同时成立劳动关系，亦未对企业的归属作出限定，故即使杨某与某鱼栏雇主成立劳动关系也不妨碍其内地劳动关系成立的认定。因此，在某科技公司与杨某所签合同期满后，双方符合事实劳动关系的法律特征，存在劳动关系。

第二，关于工资差额的问题。2021年2月至5月，双方之间劳动关系存

续，杨某仅收到澳门币工资，某科技公司未举证证实已向杨某支付了人民币工资，故存在工资差额，某科技公司对此应予补足。杨某的工资自2020年9月开始以澳门币和人民币两种形式发放，故其工资差额应参照杨某2020年9月至2021年1月人民币工资的平均数计算。

第三，关于劳动合同的解除问题。某科技公司管理人员于2021年5月18日告知杨某工作地点无法再办公，庭审中亦承认以杨某不服从管理为由将其“退回”某鱼栏，应当认定某科技公司确有作出解除劳动合同的意思表示，且其未举证证实解除劳动合同决定的合法性，故应认定其违法解除劳动合同，应向杨某支付赔偿金。某科技公司法定代表人、股东或者监事向杨某支付的全部劳动报酬应视为杨某的全部工资收入。从杨某实际领取的劳动报酬来看，工资分人民币与澳门币两部分发放是从2020年9月开始执行，杨某对此享有信赖利益，故法院确定应按杨某离职前十二个月澳门币和人民币工资的总和折算赔偿金计算基数。

横琴粤澳深度合作区人民法院依照《中华人民共和国劳动合同法》第三十条、第三十九条第四项、第四十七条、第八十七条的规定，判决如下：

一、驳回某科技公司的诉讼请求；

二、某科技公司于判决发生法律效力之日起十日内支付杨某2021年2月1日至2021年5月18日工资20750.2元；

三、某科技公司于判决发生法律效力之日起十日内支付杨某2017年4月10日至2021年5月18日违法解除劳动合同赔偿金人民币61999.38元、澳门币55692.75元；

四、驳回杨某的其他诉讼请求。

某科技公司、杨某不服一审判决，提起上诉。广东省珠海市中级人民法院经审理认为：认可一审法院的事实认定与裁判理由。某鱼栏与杨某之间是否存在劳动关系不适用内地劳动法的规定，而内地现行法律未明确禁止成立双重劳动关系。

广东省珠海市中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项的规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

我国企业跨境用工或劳动者跨境就业发生纠纷时，确定法律适用是解决争议的先决条件。在审理跨境用工劳动争议时，对跨境性质的司法识别及涉外多重劳动关系的独立认定，是平衡劳动者与用人单位利益关系的关键要点。

第一，跨境性质的识别是适用法律的首要逻辑。根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉若干问题的解释（一）》第十七条，涉及香港特别行政区、澳门特别行政区的民事关系的法律适用问题，参照适用本规定。该司法解释第一条即明确涉外性的认定规则：属人涉外、属地涉外、标的物涉外、法律事实涉外及其他涉外情形，满足其中之一的情形即当然地符合本条规定。本案杨某的工作地点涉及我国澳门特别行政区，应当参照适用涉外民事关系法律适用法的规定。

第二，对涉外多重劳动关系认定的独立性：坚持分别审查制。对于劳动争议案件，为了实现对劳动者的特殊保护，《中华人民共和国民事诉讼法》第四十三条对冲突法规范作出特别规定，“劳动合同，适用劳动者工作地法律”，但实践中劳动者往往在多个工作地提供劳动，尤其是跨境用工，对此，对“劳动者工作地”的司法认定应以主要工作地为标准。理由在于：劳动者的权利义务是在劳动关系建立时、劳动过程中产生，而劳动关系通常在劳动者工作地或用人单位主要营业地发生。其中，劳动者工作地的法律相较其他地区的法律最为劳动者知悉。同理，当存在多个工作地时，从常理来看劳动者与主要工作地的联系更为紧密，以主要工作地为确定标准更为契合。本案杨某虽有赴我国澳门特别行政区工作的情况，但其主要工作地在横琴粤澳深度合作区，冲突规范应适用我国内地的劳动法。

对于含有涉外性质的多重劳动关系成立与否的认定，应当进行分别审查。一方面，《中华人民共和国劳动法》未禁止劳动者与用人单位成立多重劳动关系，亦未对用人单位的属地予以限定。也就是说，劳动者既可以与境内用人单位成立劳动关系，也可以与境外用人单位成立劳动关系；既可以与境内多家用人单位成立劳动关系，也可以在与境内用人单位成立劳动关系的同时与境外用

人单位成立劳动关系。另一方面，在对境内或境外企业与劳动者之间是否成立劳动关系进行司法认定时，根据冲突规范指引应分别依劳动者工作地适用域外法律或域内法律审查判定。

第三，劳动关系的认定：程序方面与实体方面双途径并行。在程序法层面，法律并未规定人民法院对劳动关系的成立负有审查义务，因此，劳动者是否与境内还是境外企业存在劳动关系应依当事人申请进行审查。在实体法层面，人民法院审查劳动关系成立与否，需要从形式要件与实质特征两方面入手：第一步，先审查双方是否签订书面劳动合同，若已签订则劳动关系成立；第二步，双方未签订书面劳动合同的，根据原劳动和社会保障部《关于确立劳动关系有关事项的通知》第一条进行综合判定：(1)双方是否符合法律、法规规定的主体资格；(2)用人单位的劳动规章制度是否适用于劳动者、劳动者是否受用人单位的管理、从事用人单位安排的有酬劳动；(3)劳动者提供的劳动是否属于用人单位业务的组成部分。

第四，跨境用工中劳动者劳动报酬的认定规则：以劳动者为导向。一方面，从法律解释方法而言，根据《中华人民共和国劳动合同法》第四十六条、第四十七条的规定，赔偿金计算以劳动合同解除前十二个月的平均工资为基数。对“平均工资”的含义应作文义解释与体系解释，原劳动部《关于〈劳动法〉若干条文的说明》第三条第三款明确劳动报酬是指“劳动者从用人单位得到的全部工资收入”，鉴于该条文未明确将全部工资收入限于境内，故“全部工资收入”应界定为用人单位发放的境内工资与境外工资的总和。另一方面，从裁判的价值取向而言，人民法院需对用人单位、劳动者的利益予以衡平。在劳动关系中，劳动者相较于用人单位而言，处于相对弱势地位，而劳动报酬的获取和支付是劳动双方最基础的权利义务关系。因此，对于跨境用工纠纷中劳动报酬的认定，应以境内工资与境外工资的总和进行计算。况且在实践层面，不同币种合并计算时可以采用实时汇率或平均汇率的方式加以确定，也可以由当事人双方约定固定汇率进行计算，不存在实际阻碍。

编写人：横琴粤澳深度合作区人民法院 郑恒 唐昱

新业态用工模式下劳动关系的认定标准

—— 王某诉某货运公司劳动争议案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

北京市第三中级人民法院(2023)京03民终4371号民事判决书

2. 案由：劳动争议

3. 当事人

原告(上诉人):王某

被告(被上诉人):某货运公司

【基本案情】

2018年6月,王某开始从事外卖骑手工作,接受李某日常管理,站长李某每天都会开晨会,王某的工作时间为7点至22点,请假需要由站长审批。工资由某人力公司、某信息技术公司、某外包公司接替支付。

2019年11月,某货运公司与某外包公司签订《配送业务外包服务合同》,某货运公司将承接的配送业务外包给了某外包公司。同月,某外包公司与劳务公司签订《配送业务外包服务合同》,某外包公司将该业务再次外包给劳务公司。王某签署的《承揽服务协议》显示王某注册成为个体工商户并与劳务公司签订承揽服务协议。

王某工作期间,某货运公司一直给王某购买雇主责任险。外卖平台软件显示王某自2018年6月至2019年1月为某传媒公司的全职骑手,自2019年6月至2020年6月为某货运公司全职骑手。经查,某传媒公司和某货运公司系关联

公司。此外，每月均有外卖平台官方电话号码向王某发短信，内容为王某在某货运公司的某月薪资信息已上传至平台应用程序。在平台应用程序中的薪资界面显示的内容为某货运公司每月工资金额，该金额均与王某提交的银行流水金额一致。

王某起诉请求：确认2018年6月7日至2020年8月17日王某与某货运公司之间存在劳动关系。

【案件焦点】

王某与某货运公司在2018年6月7日至2020年8月17日是否存在劳动关系。

【法院裁判要旨】

北京市朝阳区人民法院经审理认为：依据现有证据无法认定双方之间存在劳动关系。第一，王某主张受李某管理，但李某否认与某货运公司存在劳动关系。第二，某货运公司提交《配送业务外包服务合同》，且工资由案外公司支付给王某，难以证明王某从事某货运公司安排的有报酬的劳动。

北京市朝阳区人民法院依据《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》第六条之规定，判决如下：

驳回王某的诉讼请求。

王某不服一审判决，提出上诉。北京市第三中级人民法院经审理认为：涉及新就业形态劳动关系认定时，应坚持“事实优先”的劳动关系认定原则，根据用工事实认定企业和劳动者的关系。判断双方是否存在劳动关系，应从“主观合意”和“客观从属性”两个角度分析。

所谓“主观合意”，是指劳动者和用人单位知晓并同意与特定对象建立劳动关系，本案中，外卖平台应用程序显示王某自入职后先后为某货运公司关联公司和某货运公司的全职骑手，其收到的短信载明薪资的发放主体是某货运公司，某货运公司为王某购买雇主责任险，因此王某有理由相信其实际是与某货运公司建立了劳动关系。用人单位开展经营活动，应依法保障劳动者的合法权

益，不得诱导、强迫劳动者登记为个体工商户。本案中，虽然王某签订了承揽服务协议，但是双方没有作为法律地位平等的市场主体开展经营活动，也未实际履行承揽服务协议，实质上以承揽的方式开展用工管理，不能以此抗辩劳动关系的建立和存续。另外，从时间顺序上看，某货运公司与王某建立劳动关系后才将业务外包给某外包公司和劳务公司，考虑到王某的工作地点、工作内容均无变化，某货运公司也未提供证据主动告知王某变更了用人单位，故二审法院对其关于不存在劳动关系的主张不予采信。

所谓“客观从属性”，是指用人单位和劳动者之间具有人格从属性、经济从属性和组织从属性。第一，王某接受系统自动派单，无权拒绝接单，同时存在开晨会等集体管理的情形，存在人格从属性；第二，王某的从业行为具有较强的持续性和稳定性，收入源于某货运公司与平台结算的费用，存在经济从属性；第三，王某提供的配送服务属于某货运公司的业务组成部分，收益和风险归于公司，体现了组织从属性。综上，法院认为王某与某货运公司建立了劳动关系。从劳动关系的存续期间而言，考虑到某传媒公司和某货运公司系关联关系，王某的工作内容未发生重大变化，故法院认定王某入职时间为2018年6月7日。

北京市第三中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第二项规定，判决如下：

- 一、撤销北京市朝阳区人民法院(2021)京0105民初36680号民事判决；
- 二、王某与某货运公司自2018年6月7日至2020年8月17日存在劳动关系。

【法官后语】

外卖配送行业作为新业态平台经济的典型代表，就业形态较为复杂。本案中，王某根据平台派单配送商品，虽然工作时间、工作地点、工作内容均未发生变化，但作为劳动关系另一端的用人单位却迷雾重重。《最高人民法院工作报告——2024年3月8日在第十四届全国人民代表大会第二次会议上》指出：“维护新就业形态劳动者权益……根据实际用工，判断外卖小哥等与平台企业是否存在劳动关系，破除以劳务连环外包、诱导注册个体户等方式规避用工责

任的‘障眼法’。”^①《最高人民法院工作报告——2025年3月8日在第十四届全国人民代表大会第三次会议上》中指出：“发布新就业形态劳动争议指导性案例，对平台企业要求劳动者注册为个体户再签订所谓合作合同的，明确依用工事实认定劳动关系，切实保护劳动者合法权益。”^②本案在典型案件事实中凝练出一般抽象原则，从主观合意和客观从属性双重维度审查劳动关系的建立，对于新业态用工的劳动关系主体认定进行有益探索，推动保障平台经济业务健康发展有序发展。

一、现状：新就业形态用工模式多样

新业态平台经济在优化服务业结构、推动消费转型、创造就业岗位和挖潜劳动力资源等方面发挥了积极作用。与之相对，传统劳动关系中通常用来判断劳动关系存在的某些参考性标准如工作制服、任务分配机制、考勤管理等被消解，存在雇佣主体多元化、工作地点去中心化和从属性削弱化等特征，给劳动关系的认定和劳动者合法权益的维护造成一定障碍。

以外卖配送行业为例，实践中通常采用以下模式：

一是传统用工模式。此类用工模式劳动关系清晰，用人单位受到劳动法的全面规制。包括：（1）餐馆自行雇佣骑手；（2）外卖平台自行雇佣骑手；（3）外卖平台劳务派遣。

二是众包模式。不特定的大众通过平台关联的应用注册成为骑手，即可抢单配送。包括：（1）外卖平台直接招募众包骑手；（2）外卖平台与众包服务公司合作。

三是专送模式。此类用工模式下配送商将骑手所带来的人力成本和用工风险进一步向外剥离和区隔。包括：（1）外卖平台与配送商合作，配送商招募骑

^①《最高人民法院工作报告——2024年3月8日在第十四届全国人民代表大会第二次会议上》，载最高人民法院网站，<http://gongbao.court.gov.cn/Details/91879661d9288abc72798a23blecec.html>，2025年2月25日访问。

^②《最高人民法院工作报告——2025年3月8日在第十四届全国人民代表大会第三次会议上》，载最高人民法院网站，<https://www.court.gov.cn/zixun/xiangqing/457991.html>，2025年2月25日访问。

手；(2)配送商转包或分包给其他多个公司甚至个人；(3)配送商与灵活用工平台合作，专送骑手注册为个体工商户。

二、难题：用工模式“多角化”趋势突出，传统劳动关系认定标准面临新挑战

在平台经济模式下，为适应市场变化和应对用工合规风险，越来越多的互联网平台逐渐从传统的自营模式或劳务派遣模式转变为引入代理商、分包商乃至多层劳务外包的多角用工模式，用工链条更为复杂，涉及主体更为多元，“平台+从业人员+多家公司（如代理商、合作商、某外包公司等）”的长链条模式成为新常态；用工平台、代理商及劳务外包商等各自独立的主体对从业人员分别施以线上或线下不同程度的管理，并通过与从业人员签订服务协议、承包协议、合作协议等方式避免产生劳动关系；部分从业人员可能也会打破单一用人单位形式，同时为多家用工平台或企业提供服务，导致用工平台或企业对从业人员的劳动管理职能日趋分散。

本案中，劳动者接收订单的外卖平台、日常管理的外卖站点、薪资发放主体均为不同的公司。公司通过连环外包的方式架设防火墙，并企图让劳动者注册个体工商户，将劳动关系模糊为承揽关系。这种多主体的复杂用工模式，不仅使从业人员的权益保障和权利救济面临困境，也给审判实践中人民法院对各方法律关系的厘清，特别是对从业人员与用工平台和企业之间法律关系的定性带来了极大挑战。

三、思路：坚持事实优先原则，穿透识别新就业形态劳动者的劳动关系

新业态用工模式的非典型劳动关系为“伞型劳动关系”，一端是劳动者，另一端链接参与新业态商业模式的诸多公司，劳动关系在算法的外衣下更加隐蔽，从属性的适用场域从有形的物理空间转向无形的数码空间，因此需要通过揭开面纱发现实质从属性，在二要件式认定标准项下设立开放式的认定要素，以主观合意和客观从属性为标准，穿透识别真正的用人单位主体。

从主观合意而言，劳动关系作为民事关系的一环，自然也离不开意思自治原则的约束，建立劳动关系时双方需存在主观合意，劳动者知晓劳动付出的对

象，并有选择用人单位的权利。同时，考虑信息不对称因素及维权能力强弱，不能苛求劳动者穷尽一切方式挖掘背后真实的用工主体，如现有的证据足以产生外观表征信赖，则可以认定劳动者在主观上与该对象建立了劳动合意。本案中，不论是外卖平台还是短信通知均显示用人单位为某货运公司，且该公司还实际为王某购买了雇主责任险，从理性第三人角度来说，这些足以使王某产生其已实际与该公司建立劳动关系的信赖。

从客观从属性而言，非典型劳动关系的人格从属性与经济从属性的认定方式与以往不同，应参考用工时长、最终获利、管理惩戒等事实因素确定劳动关系。首先，在判断人格从属性方面，平台企业对劳动者缺少了直接的指挥命令，但是以算法为代言人间接地发出指令，从控制角度可以通过判断用工单位是否通过设定规则引导劳动成果，例如本案中用人单位对每一单的送达时间作出规定、每天的在线时长及请假制度均加以限制。在经济从属性的判断方面，虽然新业态用工常见按单结算模式，但用工单位通常具有强势的定价权，因此在与用工单位建立法律关系时，劳动者是否具有“讨价还价”的权利，可以作为甄别经济从属性的因素，结合审查劳动者收入来源情况，判断劳动者是否具有经济上的弱势地位。

编写人：北京市第三中级人民法院 龚勇超 林鑫 郭妍子

在校学生假期实习期间担任“网络主播”劳动关系的认定

—— 张某诉某传媒公司劳务合同案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

重庆市第三中级人民法院(2023)渝03民终2141号民事判决书

2. 案由：劳务合同纠纷

3. 当事人

原告(被上诉人): 张某

被告(上诉人): 某传媒公司

【基本案情】

张某系某职业学院在校学生, 2023年5月, 张某与某传媒公司联系主播事宜, 意在做暑假工获取报酬和实习证明。张某接受公司7天的培训后, 开始在某传媒公司做主播工作, 并签订了《主播独家合作经济协议书》, 合同约定由某传媒公司担任张某的演艺经纪公司, 并充分利用其资源对张某进行形象设计、包装及宣传推广和协调平台关系, 以提升张某的人气、粉丝量、流量变现的能力, 负责安排张某全部直播工作及直播之外的商业活动, 全权代理张某所涉直播、出版、演出、录音、录像等商业活动, 可在征得张某授权后签订有关合同, 某传媒公司根据张某的演艺风格、才艺情况, 与张某洽谈, 安排适合张某的商务经济活动。每个自然月, 张某在某传媒公司指定的互联网直播演艺平台直播有效天数不少于156小时, 不少于26天(每6个小时为一个有效天数), 某传媒公司每月结算张某工资。双方并对张某在平台直播获得的收益分成进行了约定。2023年7月, 某传媒公司以张某违约为由停止其工作。后张某提起仲裁申请, 要求补发工资、提成、违约赔偿金, 仲裁委员会作出不予受理决定后, 张某不服向法院提起诉讼, 请求人民法院确认张某与某传媒公司存在劳动合同关系, 由某传媒公司补发张某工资及提成3097元, 赔偿张某3000元。

【案件焦点】

在校学生利用假期实习担任“网络主播”, 其与企业之间是否存在劳动关系。

【法院裁判要旨】

重庆市涪陵区人民法院经审理认为: 张某利用暑期打工以获取劳动报酬和

18 中国法院2025年度案例 · 劳动纠纷(含社会保险纠纷)

实习证明为目的,到某传媒公司工作,某传媒公司也知晓张某为在校学生,到公司工作是为了打暑假工,双方无主播合作经纪之意向。虽双方签订《主播独家合作经纪协议书》约定某传媒公司为张某提供演艺经纪事宜,但根据现有证据只能证明张某按约定履行了直播等劳务,张某自主决定直播的内容、形式、场所、时间点,某传媒公司对张某的管理和控制明显较弱,双方未在人格上和经济上形成从属性的劳动关系特征,双方属于劳务合同关系。张某向某传媒公司提供劳务,应当获得相应报酬。

重庆市涪陵区人民法院依据《中华人民共和国民法典》第一百四十六条第一款、第一百五十七条,《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条第一款之规定,判决如下:

某传媒公司支付张某劳务报酬2413.38元。

某传媒公司不服一审判决,提起上诉。重庆市第三中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项规定,判决如下:

驳回上诉,维持原判。

【法官后语】

与传统演艺相比,网络主播行业凸显出灵活性、互动性、可及性等特征,相应地,网络直播行业就业形态和利益分配方式也日趋多样化,网络主播和所在的公司企业双方之间是劳动关系抑或其他关系,应根据个案情况加以认定,不能一概而论。

一、传统用工模式下劳动关系的认定与“网络主播”用工关系的类型分析

劳动关系是指用人单位与劳动者运用劳动能力实现劳动过程中形成的一种社会关系。原劳动和社会保障部《关于确立劳动关系有关事项的通知》第一条规定:“用人单位招用劳动者未订立书面劳动合同,但同时具备下列情形的,劳动关系成立。(一)用人单位和劳动者符合法律、法规规定的主体资格;(二)用人单位依法制定的各项劳动规章制度适用于劳动者,劳动者受用人单位的劳动管理,从事用人单位安排的有报酬的劳动;(三)劳动者提供的劳动是用人单位业务的组成部分。”可见,劳动关系的双方主体除存在劳动关系即

经济关系外，还存在人身关系，即行政隶属关系。劳动者除提供劳动之外，还要接受用人单位的管理，服从用人单位的安排，遵守用人单位的规章制度，成为用人单位的成员。

作为一种新型就业形态，目前网络主播主要涉及的用工模式有以下三种。一是网络主播利用商家或自己的账号直播卖货，此种类型涉及主播与卖货商家之间关系的认定；二是网络主播以签约或者获得授权的方式在直播平台进行直播，此种类型涉及主播与直播平台关系的认定；三是网络主播与经纪公司签订经纪协议，经纪公司对主播提供服务和管理，此种类型涉及主播与经纪公司之间关系的认定，本案即属于此种类型。对于上述三种主要的网络主播用工模式，因其用工模式、特点均有较大差异，对于劳动者与用人单位之间的关系，应根据个案情况具体分析。

二、在校学生担任“网络主播”用工形态中劳动关系的认定要点

由于现行法律并未将在校学生排除在劳动法适用主体之外，在校学生的身份不能成为其作为劳动主体资格的限制。因此，对于在校学生担任网络主播类人员用工关系的认定，应当运用“穿透式”审判思维，重点考虑当事人合意、隶属关系、用工单位对主播的管理程度等因素，结合互联网用工特性，正确厘定由学生担任的网络主播与用工单位之间的关系。

第一，从用工合意角度来看，用工合意是指劳动者和用人单位在平等自愿、协商一致的基础上就是否建立劳动关系及条件、内容达成合意。本案中，虽张某与某传媒公司签订了《主播独家合作经济协议书》，但该协议的实质系为规范双方在合作过程中的具体权利义务，根据案件查明，张某与该传媒公司合作的本意系为获取实习证明，附带获取一定的劳动报酬，这也符合在校学生假期工作实习的特征。第二，从隶属关系来看，隶属性是劳动关系的本质属性，包括人身隶属性、经济隶属性及组织隶属性，即包含劳动者是否必须接受用人单位的管理、遵守用人单位的规章制度并完全服从其安排，用人单位是否要对劳动者支付相应报酬及劳动者是否为用人单位内部稳定的成员三个维度。本案中，张某尚未毕业，仍受学校的教育管理，其与某传媒公司并未形成新的人身隶属

关系，其亦非该传媒公司内部稳定的成员。第三，从用工单位对主播的管理程度来看，本案中，张某自主决定直播的内容、形式、场所、时间点，某传媒公司对张某的管理和控制明显较弱，双方未在人格上和经济上形成从属性的劳动关系特征。而根据张某与某传媒公司平等协商后，签订协议书，约定由张某提供劳务，某传媒公司向其支付报酬的合作模式来看，双方之间应为劳务合同关系，而非劳动关系。

编写人：重庆市第三中级人民法院 伍柯聿

投资人与企业之间劳动关系的认定

——某科技公司诉宋某劳动争议案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

北京市第二中级人民法院(2023)京02民终489号民事判决书

2. 案由：劳动争议

3. 当事人

原告(上诉人): 某科技公司

被告(被上诉人): 宋某

【基本案情】

宋某主张于2018年11月27日入职某科技公司，担任项目总监，任职期间主要从事市场销售等工作。某科技公司成立于2018年11月27日，石某系该企业大股东。2019年7月17日，某管理中心成立，执行事务合伙人为石某且为无限责任合伙人，杜某、于某、宋某均为有限合伙人。此后，某管理中心

(有限合伙)成为某科技公司股东,认缴出资日期为2019年8月30日。2019年8月7日,石某、杜某、宋某、于某四人约定:“……甲、乙、丙、丁以创始股东身份持有企业股权,丙方(即宋某)以现金外加2018—2019年度12个月工资折算,拥有某科技公司26万元的出资额,通过有限合伙企业,实际持有某科技公司3.47%股权。”2019年8月7日,石某、杜某、宋某、于某四人约定:“由于石某、杜某、宋某、于某为企业创始股东,在销售市场享有特别的权限,特作如下规定……创始股东享有企业销售提成的最高权限,即毛利润45%”。2019年6月12日,宋某与石某约定石某将某科技公司3.47%的股权转让给宋某,宋某以人民币20万元,外加2018—2019年度12月工资折算为6万元,总计26万元的价格受让。2019年6月13日、7月11日宋某分别向石某转账10万元,摘要均记录为认购股份。某科技公司在备案公示的股东信息中并无宋某的任何记录。2020年9月24日,石某与宋某约定宋某将其持有的某管理中心的股权以20万元的价格转让给石某。

2020年8月,宋某开始向石某索要工资。2020年10月30日,宋某向北京市西城区劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁,请求确认双方自2018年11月27日至2020年8月31日存在劳动关系、支付违法解除劳动关系赔偿金40000元、支付2018年11月27日至2020年8月31日工资151839.08元、支付2018年12月27日至2019年11月26日未签劳动合同二倍工资差额11万元、支付2019年1月1日至2020年8月31日未休年假工资7356.32元并出具离职证明。2021年4月28日,该委作出裁决书,裁决确认某科技公司与宋某在2018年11月27日至2020年8月31日存在劳动关系、某科技公司支付该期间工资151839.08元、2019年10月31日至2019年11月26日未签劳动合同二倍工资差额8735.63元,驳回宋某的其他仲裁请求。某科技公司不服该裁决,于法定期限内起诉至北京市西城区人民法院。

【案件焦点】

某科技公司与宋某是否存在劳动关系。

【法院裁判要旨】

北京市西城区人民法院经审理认为：第一，宋某出具的会议纪要及钉钉审批截图等证据显示其作为劳动者已为某科技公司提供了劳动并接受其劳动管理，其提供的劳动属某科技公司的业务组成部分，某科技公司提供的打卡记录显示宋某存在持续出勤记录，符合建立劳动关系的人格从属性及组织从属性标准。第二，宋某与石某的微信记录显示其多次提出工资主张，双方就工资标准亦进行过协商，案涉股权转让协议涉及宋某工资折算问题，符合建立劳动关系的经济从属性标准。第三，2019年1月至2020年8月，某科技公司为宋某缴纳了社会保险，符合建立劳动关系的外观特征。宋某于2019年6月12日与石某签订涉及某科技公司的股权转让协议，2019年7月16日宋某签订涉及某科技公司的股东企业的合伙协议，上述协议签订日期均晚于宋某开始在某科技公司工作的时间；宋某虽签订了股权转让协议，但某科技公司并未在登记机关办理变更登记，从逻辑上来讲，宋某也不因是股东而不具有劳动者的身份。

北京市西城区人民法院依照《中华人民共和国合同法》第七条、第三十条、第八十二条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条、第九十一条之规定，判决如下：

一、某科技公司与宋某在2018年11月27日至2020年8月31日存在劳动关系；

二、判决生效后七日内，某科技公司支付宋某2018年11月27日至2020年8月31日工资151839.08元；

三、判决生效后七日内，某科技公司支付宋某2019年10月31日至2019年11月26日未签订劳动合同二倍工资差额8735.63元；

四、驳回某科技公司之诉讼请求。

某科技公司不服一审判决，提起上诉。北京市第二中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

投资人身份与劳动者身份不是互相对立的，一个自然人可以基于出资而成为投资人以获取资产收益，也可以基于提供职业性劳动而成为劳动者以获取劳动报酬。股东与企业之间劳动关系的认定要坚持以“事实优先”为原则，以“从属性+要素式”的认定思路，着重考察投资人与企业之间的用工事实，以各项要素为抓手判断投资人与企业之间是否具有人格、经济及组织三方面的从属性。

《中华人民共和国劳动合同法》第七条“用人单位自用工之日起即与劳动者建立劳动关系”即体现了这一原则。劳动关系的建立应当以提供劳动事实为基础，有无劳动合同不是必要条件。实践中往往存在先签劳动合同然后推迟入职时间或者先入职提供劳动后续补签劳动合同的情形，但无论是何种情况，劳动关系的成立时间均以实际用工之日为准，股东与公司之间劳动关系的成立时间同样适用该条的规定。

当然，仅以“事实优先”为原则作为判定规则在股东与公司认定劳动关系类案件中存在“先天性不足”。股东行为与劳动者行为在外观上难以区分，据此直接从提供劳动事实方面推断劳动关系是否成立便行不通。不过，实践中分析股东实施行为的来源是一个很好的解决办法，即以“事实来源优先”为原则。例如，劳动者因担任法定代表人而从事除董事职权以外的公司其他具体业务，该事实来源为劳动者担任法定代表人，且具体事实属于董事职权之外，最终法院在该案中认定劳动关系存在；再如，股东从事某些行为基于与公司之间的合作协议，最终法院在该案中认定劳动关系不存在；以及，股东虽然担任公司总经理，但系基于公司章程和股东之间的约定，其实施的行为来源于股东之间的分工，而非公司的安排，最终法院在该案中认定劳动关系不存在。故此，在股东与公司认定劳动关系类案件中，不妨着重考察股东实施的行为的来源是什么，若该来源系基于合伙协议、股东间的约定，且该协议或约定不能体现“公司的安排”，则可以认定劳动关系不存在；若个案中没有相关协议作为参考，则可结合其他表征加以判断。

24 中国法院2025年度案例·劳动纠纷(含社会保险纠纷)

人格从属性主要体现在公司的工作规则、劳动纪律、奖惩办法等可以适用于劳动者，劳动者无法自主决定工作时间、工作方式以及工作量。人格从属性虽然是劳动关系的核心标准，但在股东与公司之间的劳动关系认定这一议题中，其作用有限，其原因有二：首先，一般的股东与公司之间的人格从属性很弱，因为公司股东一般不受公司规章制度的约束，其能够自主决定是否参与公司经营，自主决定参与公司经营的具体范围以及内容，若股东自由支配工作时间，不参与公司的考勤管理，不受公司奖惩制度约束，那么股东与公司之间的劳动关系很难认定；其次，若股东决定参与公司经营，且为公司经营付出了实际“劳动”，那么需要区分股东为公司经营所实施行为的性质，若是投资经营行为，则双方人格从属性弱，若是劳动行为，则人格从属性强，应当认定劳动关系存在。本案中，宋某采买物资、向银行借贷资金、向劳动者发工资、进行项目推进等事项与公司财务部门、市场部门的工作内容高度混同，因此单从劳动内容来看不容易判断股东与公司之间的劳动关系。但从接受管理的角度来看，宋某采买物资需要经过审批，并且某科技公司提交的打卡记录显示其有持续出勤的记录，这表明宋某接受某科技公司的业务管理与考勤管理，具有一定的人格从属性。

经济从属性指的是劳动者为企业提供劳动以换取报酬，企业向劳动者支付的劳动行为的对价是劳动者主要或唯一的收入来源。在经济从属性中，劳动关系下的劳动者不具备与普通雇佣关系下的劳动提供者一样的议价能力，其只能被动接受或在很有限的范围内决定自己的报酬。如上所述，股东既可以基于股东身份获得出资收益，也可以基于劳动者身份获得劳动报酬，前者与公司经营状况息息相关，而后者除部分名目的报酬与公司经营状况有关外，其余则属于固定收入或依据劳动者自身劳动成果而定。劳动报酬的获得有很强的周期性，劳动者与用人单位往往会在劳动合同中约定或依惯例遵循相对固定的发薪周期及发薪日期。当认定股东与公司之间的劳动关系时，可以考察股东是否在一定期间内周期性地获得收益，并且这种周期性收益是基于其周期性地实施了劳动行为。本案中，某科技公司由于经营不善，并没有向宋某周期性地支付款项，

因此并不能直接根据支付凭证认定双方之间存在经济从属性。但从宋某与石某的微信聊天记录来看，宋某曾向石某索要工资，而石某承认支付部分款项并承诺支付剩余部分，此系对经济从属性的补强。

组织从属性主要体现在劳动者是否被纳入企业的组织体系当中，成为企业生产经营的有机部分，并以企业的名义对外提供服务等。一般情况下，股东若直接参与公司经营活动或仅临时性提供帮助，其不会被纳入公司组织架构当中。本案中，宋某在某科技公司主要从事市场销售工作，其打卡记录显示所属部门为市场部，再结合宋某提交的各会议记录以及钉钉审批截图，宋某隶属于市场部能够达到高度盖然性标准，因此其与某科技公司具有组织从属性。

进行要素式的判断主要是为弥补单纯理论认定的不足，原劳动和社会保障部《关于确立劳动关系有关事项的通知》第二条列举了工资支付凭证或记录、缴纳各项社会保险费的记录，用人单位向劳动者发放的“工作证”“服务证”等能够证明身份的证件，招工招聘“登记表”“报名表”等招用记录，考勤记录，其他劳动者的证言等要素，虽然这些劳动要素对认定新用工形态下的劳动关系可能不够充分，但于股东与公司认定劳动关系类案件而言还可发挥作用。本案中，某科技公司为宋某缴纳了社会保险，宋某存在持续性打卡记录，这些能够在一定程度上说明宋某与某科技公司存在劳动关系。当然除了上述这些实物要素，还有其他非实物要素，如逻辑要素。本案中宋某与某科技公司虽签订有股权协议、合伙协议，但签订时间均晚于宋某开始在某科技公司工作的时间，即宋某在获得股东身份之前早已开始为某科技公司提供劳动。宋某虽签订了股权转让协议，但某科技公司并未在公司登记机关办理变更登记。

综上，劳动法并未禁止股东与其投资的公司建立劳动关系，但应注意区分股东的投资经营行为和劳动行为。当股东请求确认其与公司存在劳动关系时，应抓住用工事实以及从属性特征这个主要矛盾，做到具体问题具体分析。

编写人：北京市西城区人民法院 邱少鹏

企业与投资人之妻订立劳务外包协议， 劳务提供者与企业是否成立劳动关系的认定

—— 陈某诉某清洁服务部劳动争议案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

重庆市第三中级人民法院(2023)渝03民终2200号民事判决书

2. 案由：劳动争议

3. 当事人

原告(被上诉人): 陈某

被告(上诉人): 某清洁服务部

【基本案情】

某清洁服务部系个人独资企业，黎某为投资人，企业的经营范围为干洗、水洗服装、床上用品。2022年1月1日，某清洁服务部与黎某之妻宋某签订《劳务承包协议》，协议主要约定：某清洁服务部将劳务发包给宋某，某清洁服务部与宋某所安排的具体从事劳务服务的人员之间不存在劳动关系或者劳务关系，不需为其购买社会保险支付任何费用、补偿、赔偿等。对于宋某提供的劳务人员，某清洁服务部对其工作不认可时可要求更换；在承包期内，宋某所聘人员所发生的劳务纠纷、工伤、病残和安全事故等应由宋某自行负责处理并承担赔偿责任，赔偿之后不得向某清洁服务部追偿等。

2022年5月18日至2023年2月20日，某清洁服务部多次向宋某转账支付款项，用途为“劳务费”“其他”等。2022年6月8日，陈某通过招聘信息与

宋某电话联系后到某清洁服务部处从事水洗工工作，由宋某与陈某协商确定了工资待遇，但未订立书面劳动合同。2023年1月30日，宋某告知陈某其被解雇。

陈某工作期间，宋某通过微信转账支付陈某工资合计26627元，陈某提供记载其工资的《收款收据》载明的客户名称为“某清洁服务部”。2023年6月12日，陈某向劳动争议仲裁机构申请仲裁，请求裁决某清洁服务部支付未订立书面劳动合同期间的双倍工资差额24500元和违法解除劳动合同赔偿金7000元。劳动争议仲裁机构经审理后作出仲裁裁决，驳回陈某的仲裁申请。陈某不服，提起本案诉讼，诉请与其仲裁请求一致。

另查明，陈某上班报到时间不固定，早至三四点，晚至八九点，其每月休息时间仅有一天。某清洁服务部处的员工均由宋某雇佣。

再查明，黎某与宋某之间系夫妻关系。

某清洁服务部辩称，案涉《劳务承包协议》系双方的真实意思表示，合法有效，应予采信。某清洁服务部不参与宋某的选人用人，只对宋某进行考核，宋某的行为并不属于代表某清洁服务部进行管理的职务行为，故某清洁服务部与陈某之间并无劳动关系。

【案件焦点】

企业与特殊关系人签订劳务外包协议后，劳务提供者与企业之间是否仍可构成劳动关系。

【法院裁判要旨】

重庆市南川区人民法院经审理认为：某清洁服务部与宋某签订的《劳务承包协议》明确约定，由宋某个人自行对聘请人员进行处理并承担责任，而宋某与某清洁服务部的投资人黎某系夫妻关系，故双方旨在通过所谓的劳务外包，将某清洁服务部应承担的用工风险转嫁给宋某。某清洁服务部在诉讼中未证明宋某招聘陈某时已明确告知其系宋某个人聘请，并且陈某提供的记载自己工资金额的《收款收据》上，载明的客户名称为“某清洁服务部”。因此，宋某聘

28 中国法院2025年度案例·劳动纠纷(含社会保险纠纷)

请陈某入职、管理、按月发放工资等行为，均系代表某清洁服务部进行管理的职务行为。同时，陈某在工作中从事水洗工作，该业务是某清洁服务部所经营的主营业务之一。故，确认陈某与某清洁服务部在2022年6月8日至2023年1月30日存在事实劳动关系。由于双方未签订书面劳动合同，某清洁服务部应当支付陈某二倍工资差额。某清洁服务部违法解除与陈某之间的劳动合同，其依法应承担违法解除劳动合同赔偿金。

重庆市南川区人民法院依据《中华人民共和国劳动合同法》第十条、第四十七条、第四十八条、第八十二条第一款、第八十七条和《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条之规定，判决如下：

一、某清洁服务部在判决生效后五日内支付陈某未签订书面劳动合同的二倍工资差额24227元和赔偿金6656.75元；

二、驳回陈某的其他诉讼请求。

某清洁服务部不服一审判决，提起上诉。重庆市第三中级人民法院经审理认为：案涉《劳务承包协议》系黎某与宋某的内部协议，对陈某不具有法律约束力。黎某与宋某系夫妻关系，陈某有充分理由相信宋某对其的安排工作、日常管理、发放工资等行为系代表某清洁服务部的职务行为，其法律后果应由某清洁服务部承担。

重庆市第三中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项之规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

实践中，部分企业有意识地针对劳动关系从属性的判断标准，采取了一系列包含隐蔽权力、转变权威、变更外部标志在内的操作，如通过发包转包等方式，将其用工内容，拆解后分包给第三方，再由第三方招聘劳动者。此举意在将企业与劳动者之间的劳动关系，混淆为承揽、提供劳务等其他法律关系，以减轻企业责任。司法实践中，此类纠纷呈现出纷繁复杂的特点，如何正确认定用工主体，揭开发包转包等“面纱”，显得尤为重要。

首先，从核心因素——人格从属性方面判断。劳动关系的本质在于对劳动者的管理和控制，且此种管理、控制主要体现为人格从属性。人格从属性系劳动关系的本质特征，是判断劳动关系有无、强弱的核心因素。而人格从属性的核心，是用人单位对劳动者的指挥管理和监督控制，应结合用工企业对员工的控制方法、程度、奖惩措施等外部标志来对人格从属性进行认定。具体而言包括：企业是否对员工的工作时间、工作地点及内容有要求；企业是否对员工进行监督；企业是否拥有对员工进行奖惩的权力；员工是否享有自主工作时间选择权；等等。具体个案分析中，可结合案件实际情况，对上述要素进行全面综合分析，根据企业对员工是否享有管理权、管理权的强度上判断双方是否具有人格从属性。本案中，陈某工作的地点系某清洁服务部，工作的内容为水洗工作；除每月一天的休息日外，其余时间均需到岗上班，其工作时间较为固定；某清洁服务部对包括陈某在内的，由宋某招聘的工作人员可随时更换，体现出该企业对员工具有包括解雇在内的惩罚权力。从人格从属性的角度看，陈某与某清洁服务部之间符合劳动关系的特征。

其次，从关键因素——经济从属性方面判断。因人格从属性强弱的判断具有一定的主观性、抽象性，而员工取得的收入是具体、可量化、易举证的，故经济从属性的强弱程度是区分劳动关系成立与否的关键。具体而言包括：员工获取报酬的方式及发放主体，是否具有持续稳定的特点；企业是否规定了员工的报酬标准；生产资料是否由企业提供等。本案中，虽然陈某的劳动报酬系由宋某通过微信转账支付，但综观该款项的来源，是由某清洁服务部转给宋某，且陈某的工资《收款收据》载明的客户名称为“某清洁服务部”，足以证明宋某为“二传手”，实际向陈某发放劳动报酬的是某清洁服务部；陈某获取劳动报酬系按月获取，具有持续稳定性；陈某仅提供劳动，劳动过程中的生产资料为某清洁服务部提供。从经济从属性上看，陈某与某清洁服务部之间亦属劳动关系。

最后，从辅助因素——组织从属性方面判断。组织从属性主要包括：企业是否通过具体业务在消费者面前营造了一种组织从属的外观；员工是否单独完

成相关工作内容；员工从事的工作是否属于企业的主营业务；等等。本案中，陈某的工作地点、工作内容足以使陈某认为其系某清洁服务部员工。从组织从属性上看，陈某与某清洁服务部之间符合劳动关系从属性特征。

此外，对于此类纠纷，还需审查企业与签订协议方的关系、订立协议的内容等，以此研判企业的真实目的。如本案中，从协议订立主体上看，某清洁服务部的实际投资人黎某与宋某系夫妻关系，双方实际为利益共同体；从协议内容上看，宋某所聘人员所发生的劳务纠纷、工伤、病残和安全事故等应由宋某自行负责处理，而该清洁服务部的从业人员均由宋某招聘。该企业的真实目的显然是通过所谓的劳务外包将企业应承担的用工风险转嫁给宋某，以达到规避和免除该企业作为用人单位应当对劳动者承担相应法律责任的不法目的。

编写人：重庆市第三中级人民法院 伍柯聿

公司高级管理人员劳动关系的认定

—— 李甲诉某投资公司劳动合同案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

上海市第一中级人民法院(2023)沪01民终6121号民事判决书

2. 案由：劳动合同纠纷

3. 当事人

原告(被上诉人): 李甲

被告(上诉人): 某投资公司

【基本案情】

2018年7月17日，李甲被任命为某投资公司的执行董事、法定代表人；2021年4月7日，李甲不再担任该公司法定代表人。某投资公司系案外A公司占股99%的股东，李乙系某投资公司的实际控制人。2018年11月至2019年5月，李乙以某投资公司的名义将李甲派往案外A公司担任董事一职。李甲与李乙、牛某就工资事宜有过沟通。

李甲提出如下诉讼请求：1. 确认李甲、某投资公司从2018年6月20日至2021年4月7日存在劳动关系；2. 某投资公司支付李甲2018年7月1日至2019年4月30日50%未支付的工资40万元；3. 某投资公司支付李甲2019年5月1日至2021年4月7日的未发工资1791938.65元；4. 某投资公司支付李甲解除劳动关系的经济补偿金34188元。

某投资公司则认为，双方没有建立劳动关系的合意；不具有人身、经济从属性，李甲不在某投资公司处实际工作，无须遵守某投资公司的各项规章制度，不接受某投资公司的管理。李甲由李乙安排工作，与李乙产生雇佣或委托的法律关系，与某投资公司无关。

【案件焦点】

1. 李甲与某投资公司是否存在劳动关系；2. 在劳动者与用人单位未签订书面劳动合同的情况下，劳动者的工资应如何认定；3. 在劳动者与用人单位都未作出解除劳动合同的意思表示时，经济补偿金是否需要支付。

【法院裁判要旨】

上海市浦东新区人民法院经审理认为：第一，李甲与某投资公司是否存在劳动关系。首先，李甲、某投资公司均符合法律、法规规定的建立劳动关系的主体资格。其次，李乙作为某投资公司的实际控制人，将李甲安排至某投资公司持股99%的案外A公司开展业务，处理某投资公司与案外A公司的借款事宜，李甲与某投资公司存在人身从属性。再次，某投资公司虽否认牛某的身份，但从李甲提供的微信聊天记录可知，牛某负责李乙持股公司的财务处理事宜，

牛某与李甲沟通过工资和报销款的支付事宜；在李甲与牛某微信确认两个月的工资稍后转账后，某投资公司于当日向李甲转账；在李甲与牛某微信确认8个月的工资通过案外B公司转账支付后，李甲随即收到案外B公司的付款，可见，李甲与某投资公司存在经济从属性。最后，某投资公司认为李甲的社保由其他单位缴纳，但未能提供证据予以证明，即使李甲的社保确系其他公司缴纳，也不能基于此否认双方的劳动关系。综上，确认李甲、某投资公司存在劳动关系。

第二，在劳动者与用人单位未签订书面劳动合同的情况下，劳动者的工资应如何认定。李甲主张其每月的工资标准为8万元，但未能提供相应的证据予以证明，结合李甲与牛某的微信聊天记录，牛某称案外B公司将向李甲转账8个月的工资，李甲收到32万元；牛某称向李甲转账2个月的工资，某投资公司向李甲转账8万元，确认李甲每月的工资标准应为4万元。故，李甲要求某投资公司支付2018年7月1日至2019年4月30日50%的工资差额的诉请，法院不予支持。至于李甲主张的2019年5月1日至2021年4月7日的工资，虽李甲2020年2月曾主动提出降低工资标准，但李甲降低工资的条件为取得某投资公司的部分股权，且未有证据表明李甲、某投资公司对工资的调整达成一致，故某投资公司仍需按照每月4万元的标准向李甲支付2019年5月1日之后的工资。但自2020年4月1日之后，李甲实际未向某投资公司提供劳动，故李甲要求某投资公司支付2020年4月1日至2021年4月7日工资的诉请，法院不予支持。综上，确认某投资公司需向李甲支付2019年5月1日至2020年3月31日的工资373334元。

第三，在劳动者与用人单位都未作出解除劳动合同的意思表示时，经济补偿金是否需要支付。某投资公司确认没有作出解除劳动合同的意思表示，李甲未能提供证据证明庭前曾提出解除双方之间的劳动关系的意思表示，亦未能提供证据证明某投资公司存在需支付经济补偿金的情形，李甲庭审中陈述因其法定代表人身份变更了，双方之间的劳动关系在其不知情的情况下解除，也不符合支付经济补偿金的情形，故对李甲要求某投资公司支付经济补偿金的诉请，法院不予支持。

上海市浦东新区人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条

的规定，判决如下：

一、确认李甲与某投资公司自2018年6月20日至2021年4月7日存在劳动关系；

二、某投资公司于判决生效之日起五日内支付李甲2019年5月1日至2020年3月31日的工资373334元；

三、驳回李甲其余诉讼请求。

某投资公司不服一审判决，提出上诉。上海市第一中级人民法院经审理认为：与劳动争议事项有关的证据属于用人单位掌握管理的，用人单位应当提供；用人单位不提供的，应当承担不利后果。根据本案查证的事实，李甲于2018年7月至2021年4月担任某投资公司的法定代表人，受某投资公司实际控制人李乙委派工作并约定和支付了部分薪酬。一审判决认定李甲与某投资公司存在劳动关系，某投资公司应支付李甲2019年5月1日至2020年3月31日的工资373334元，认定的事实和适用的法律，并无不当。某投资公司未向法院提供证据证明其上诉主张。某投资公司主张本案超过仲裁时效，缺乏事实和法律依据。故对某投资公司的上诉请求，法院不予支持。李甲请求驳回上诉，维持原判的答辩意见，法院予以采纳。

上海市第一中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项、第一百八十二条规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

公司高级管理人员(以下简称高管)的劳动争议纠纷是劳动案件处理的难点，由于他们多为领导岗位，通常掌握用人单位日常运营过程中的经营管理权、人事权、财务权，权利、义务与普通劳动者相比存在一定差异，受到劳动法律规范和公司法律规范的双重调整。公司高管的议价能力往往更强，能够在更为平等的地位上与用人单位进行谈判，这使得他们不同于一般意义上处于弱势地位的劳动者。但在某些情况下，公司高管在与用人单位的相对关系中可能处于弱势地位。此时，对公司高管与用人单位之间是否存在劳动关系不能一概而论，

而应当结合实质要件和形式要件，穿透公司高管职位的表象，探寻其与用人单位之间真实的法律关系状况。本案的核心争议焦点为：李甲作为公司高管，是否与公司之间构成劳动关系？

一、高管相较于普通劳动者的特殊性

1. 权利义务具有特殊性。高管雇员享有广泛的权力，可在一定程度上代表“雇主”。虽然具备雇员的身份，但作为公司高管，其负责公司的日常事务，享有广泛的权力和影响。

2. 薪资待遇丰厚，与公司利益具有较强的趋同性。薪酬体系作为公司内部治理的重要组成部分，对员工兼具激励和约束功能。与普通劳动者每月固定的工资不同，高管的薪酬大多为年薪制，除了固定的薪资外，一些高管的经济收益可能还包含公司的股份分红以及奖金激励等额外报酬。

3. 资质要求高，且聘任和解聘方式具有法定性。由于高管承担着公司的重要职责，担负着《中华人民共和国公司法》明确规定的权利和义务，故对其职务的聘任和解聘有着严格的法律规定。

二、现有立法框架下涉高管劳动问题解决路径探究

在判断管理人员是否具备高级管理人员身份时，应首先合理划定高管的范围，并从实质角度考察公司高管是否与公司之间具有人身从属性和经济从属性。

1. 合理划定高管的范围。在司法实践中判断当事人是否属于高管时，应当采取以实质性标准为主、以职务名称为辅的认定方式。第一，从高级管理职务的特征、职能角度入手，判断管理者是否对公司的经营管理活动和风险控制具有决策权或重大影响。第二，从管理人员所提供的劳务特征入手，考察高管的工作自主性程度和创新性要求的高低。第三，结合管理人员的职务名称、工资水平、工作考核方式、工作时间要求等因素来综合判断管理人员层级的高低。

2. 从实质性要素判断是否构成劳动关系。对劳动关系的判断，应当回归人身从属性和经济从属性两大根本特征：（1）人身从属性。在考察公司高管和用人单位之间是否构成劳动关系时，首先应当明确，不应囿于头衔，而应从工作职责、薪资待遇、公司权限等实质性内容方面进行考察。如公司高管实际在用

人单位工作、从事用人单位安排的劳动、适用用人单位制定的各项劳动规章制度、接受用人单位的劳动管理、提供的劳动是用人单位业务的组成部分等以确定公司高管对用人单位存在人身依附性。(2)经济从属性。经济上的从属性是指受雇人员被纳入雇主经济组织与生产结构之内，但与受雇人员和雇主之间的经济或财政状况无关，且从属于雇主。即使公司高管薪酬较高，在公司具有较重的权重，相对于劳动者来说，具有相关的管理职能，与雇主关联度较高，但毕竟是受雇于董事会，为公司提供劳动，才得以享受公司的相应待遇，所以需要在司法实践中仔细甄别。

3. 明确《中华人民共和国公司法》上的解聘不当然影响劳动关系的解除。公司高管与公司之间的委托关系和劳动关系并不是非此即彼的，可以同时兼存。董事会通过决议解除其职务应视为对其岗位的变更，并不必然导致劳动关系的解除。在审查劳动关系时，需要根据高管职务解聘的具体事由确定公司与高管之间的劳动合同是否最终解除。

编写人：上海市浦东新区人民法院 钱燕

用人单位与超龄劳动者之间的 用工关系及工伤保险责任的认定

—— 杨某甲等诉某劳务公司劳动争议案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

北京市第二中级人民法院(2023)京02民终9699号民事判决书

2. 案由：劳动争议

3. 当事人

原告(被上诉人): 杨某甲、文某乙、杨某乙、杨某丙

被告(上诉人): 某劳务公司

【基本案情】

文某乙系文某甲之父, 杨某甲系文某甲之夫。杨某甲和文某甲育有一子杨某乙, 一女杨某丙。

2008年10月, 文某甲入职某劳务公司, 被派遣至地铁分公司的食堂工作。2019年10月11日, 文某甲达到退休年龄。某劳务公司为文某甲缴纳社会保险费至2019年10月。

2019年11月11日, 文某甲与某劳务公司(用人单位)、地铁分公司(用工单位)签订《劳务聘用协议》, 约定: 根据用工单位的工作需要, 派文某甲到用工单位食堂工作, 从事劳务服务期间的劳务费用与用工单位协商, 在该单位从事劳务服务期间, 因意外情况发生, 导致本人受到伤害, 只享受企业统一参保的平安意外保险待遇。

2020年6月11日6时40分, 文某甲在上班途中发生交通事故, 造成文某甲死亡。2020年7月23日, 交通支队出具《道路交通事故认定书》, 认定文某甲在此次交通事故中无责任。自入职某劳务公司至交通事故发生, 文某甲一直被某劳务公司派遣至地铁分公司食堂工作, 其未办理退休手续且未依法享受城镇职工基本养老保险待遇。

2021年9月22日, 北京市大兴区人民法院作出(2021)京0115民初12988号民事判决书, 判决: 确认2020年6月11日交通事故发生时文某甲与某劳务公司存在劳务合同关系。该判决记载某劳务公司认可《劳务聘用协议》签订后文某甲的工资发放方式亦与此前保持一致, 该判决已生效。

2021年11月24日, 某事业局作出工伤决定书, 认定文某甲为工伤。某劳务公司不同意上述决定, 向北京市大兴区人民法院提起行政诉讼, 要求撤销上述决定书。2022年7月19日, 北京市大兴区人民法院作出(2022)京0115行初146号行政判决书, 判决: 驳回某劳务公司的诉讼请求。

2022年9月3日，某村村民委员会出具证明，记载文某乙与文某甲系父女关系，文某乙已完全丧失劳动能力且无收入，文某甲生前为其提供主要生活来源。文某乙共有一子二女。

2022年9月13日，杨某甲等申请仲裁，要求某劳务公司支付一次性工亡补助金等。2022年10月8日，仲裁委出具不予受理通知书。杨某甲等不同意上述决定，诉至北京市大兴区人民法院。

【案件焦点】

某劳务公司是否应当承担工伤保险责任。

【法院裁判要旨】

北京市大兴区人民法院经审理认为：《人力资源社会保障部关于执行〈工伤保险条例〉若干问题的意见（二）》第二条第一款规定，达到或超过法定退休年龄，但未办理退休手续或者未依法享受城镇职工基本养老保险待遇，继续在原用人单位工作期间受到事故伤害或患职业病的，用人单位依法承担工伤保险责任。本案中，文某甲虽达到退休年龄，但未办理退休及依法享受城镇职工基本养老保险待遇，而某劳务公司及用工单位仍与文某甲持续原用工方式，且文某甲因交通事故死亡已经劳动行政部门认定为工伤，故某劳务公司应承担工伤保险责任，并按照《工伤保险条例》规定项目和标准给付工亡赔偿。某劳务公司提出文某甲已过退休年龄、未办理退休手续与其公司无关、已与文某甲约定从事劳务期间发生意外情况享受企业统一参保的商业保险，以及应由交通事故责任方对文某甲承担赔偿责任等理由，作为其公司不应承担工伤赔偿责任的辩解，理由不充分。

北京市大兴区人民法院依照《工伤保险条例》第三十九条第一款、第六十二条第二款、第六十四条之规定，判决如下：

一、某劳务公司于判决生效之日起十日内支付杨某甲、文某乙、杨某乙、杨某丙一次性工亡补助金847180元；

二、某劳务公司于判决生效之日起十日内支付杨某甲、文某乙、杨某乙、

杨某丙丧葬补助金70290.5元；

三、某劳务公司于判决生效之日起十日内支付文某乙供养亲属抚恤金57600元；

四、驳回杨某甲、文某乙、杨某乙、杨某丙的其他诉讼请求。

某劳务公司不服一审判决，提起上诉。二审法院同意一审法院关于某劳务公司应承担工伤保险责任的意见，但认为丧葬补助金和供养亲属抚恤金的计算标准有误。

北京市第二中级人民法院依照《工伤保险条例》第三十九条第一款、第六十二条第二款、第六十四条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第二项规定，判决如下：

一、维持北京市大兴区人民法院(2022)京0115民初20873号民事判决第一项；

二、撤销北京市大兴区人民法院(2022)京0115民初20873号民事判决第四项；

三、变更北京市大兴区人民法院(2022)京0115民初20873号民事判决第二项为：某劳务公司于本判决生效之日起十日内向文某乙、杨某甲、杨某乙、杨某丙支付文某甲的丧葬补助金59460元；

四、变更北京市大兴区人民法院(2022)京0115民初20873号民事判决第三项为：某劳务公司于本判决生效之日起十日内支付文某乙2020年7月至2023年2月供养亲属抚恤金57081.6元；

五、驳回文某乙、杨某甲、杨某乙、杨某丙的其他诉讼请求。

【法官后语】

本案涉及劳动者超过退休年龄后继续在原用人单位工作期间，因第三人侵权受到工伤而引发的劳动争议案件。通常涉及超龄劳动者的工伤案件中，用人单位的抗辩意见主要有三：双方之间并非劳动关系；用人单位不应承担工伤保险责任；工伤保险责任存在减免情节。

一、用工关系的认定

用工关系的认定需要考量以下四个要素：一是建立用工关系时间；二是享

受养老保险待遇或领取退休金情况；三是未享受是否系用人单位所致；四是意思自治原则。具体而言是指：(1)用人单位与新招用的已享受养老保险待遇或领取退休金的超龄劳动者之间的用工关系，应认定为劳务关系。(2)用人单位与新招用的未享受养老保险待遇或领取退休金的超龄劳动者之间的用工关系，原则上应认定为劳务关系，但尊重当事人意思自治，如签订劳动合同则应认定为特殊劳动关系，但对劳动者请求签订无固定期限劳动合同、支付二倍工资、经济补偿、社会保险待遇等不予支持。(3)用人单位与劳动合同期间内达到法定退休年龄且已享受养老保险待遇或领取退休金的劳动者之间的用工关系，应认定为劳务关系。(4)用人单位与劳动合同期间内达到法定退休年龄且未享受养老保险待遇或领取退休金的劳动者之间的用工关系，需实质审查未享受原因后进行认定，非用人单位原因导致，应认定为劳务关系，如果系用人单位原因导致，双方之间仍应为劳动关系，直至劳动者符合享受基本养老保险待遇时终止。

二、用人单位的工伤保险责任

通常情况下，如双方之间系劳务关系，超龄劳动者无权依据《工伤保险条例》要求用人单位承担工伤保险责任。但对于达到或超过法定退休年龄，未办理退休手续或者未依法享受城镇职工基本养老保险待遇，继续在原用人单位工作期间受到事故伤害或患职业病的劳动者，用人单位应依法承担工伤保险责任，如本案中，文某甲的家属可据此要求某劳务公司承担工伤保险责任。

三、免除或减轻责任的理由是否成立

用人单位主张的工伤保险责任减免情节主要为以下两种：(1)商业保险理赔款。常见的情形是用人单位未为劳动者缴纳工伤保险，但为劳动者购买了商业性意外伤害保险。为劳动者缴纳工伤保险是用人单位的法定义务，该法定义务不得通过任何形式予以免除或变相免除。商业性意外伤害保险性质上是用人单位提供的一种福利待遇，不能免除用人单位负有的法定的支付工伤保险待遇的义务。(2)第三人侵权责任与工伤保险责任的竞合。二者虽然基于同一损害事实，但存在于两个不同的法律关系之中，即劳动者作为工伤事故中的受伤职

工与用人单位之间形成的工伤保险赔偿关系,以及劳动者作为人身侵权的被侵权人与侵权人之间形成的侵权之债的法律关系,劳动者有权向用人单位主张工伤保险赔偿,同时还有权向侵权人主张人身损害赔偿。在这种情形下,用人单位和侵权人应当依法承担各自所负的赔偿责任,不因受伤职工(被侵权人)先行获得一方赔偿、实际损失已得到全部或部分补偿而免除或减轻另一方的责任。

编写人:北京市大兴区人民法院 孙青

逐月领取退役金的退役军人是否符合劳动者身份的认定^①

——孙某诉某装饰公司劳动争议案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

辽宁省大连市中级人民法院(2023)辽02民终2394号民事判决书

2. 案由:劳动争议

3. 当事人

原告(上诉人):孙某

被告(上诉人):某装饰公司

【基本案情】

孙某系自主择业退役军人,于2021年3月底入职某装饰公司工作。2021年5月17日,该公司法定代表人通过微信转账方式向孙某支付4月工资加报销款5175.5元。该公司分别于2021年6月16日、7月15日、8月17日、9月15

^①入库案例,参见人民法院案例库2023-07-2-490-004。

日、10月15日、11月15日、12月15日，2022年1月16日、2月21日、3月15日向孙某转账支付6540元、6761元、6000元、6000元、6580元、6000元、7020元、7410元、3290元、3000元。2021年1月至2022年7月，大连市退役军人事务局为孙某缴纳了医疗保险。孙某退役后，每月可领取9300元退役金。孙某于2022年3月初向该公司提出离职，根据公司的考勤表载明孙某3月出勤天数为17.5天。

2022年5月31日，孙某向大连市旅顺口区劳动人事争议仲裁委员会申请劳动仲裁，仲裁事项：某装饰公司支付其2022年3月工资4883元、未签订劳动合同二倍工资48000元（6000元/月×8个月）。同年9月30日，该委员会作出仲裁裁决书，裁决：驳回孙某的仲裁请求。孙某不服，就相同仲裁事项诉至辽宁省大连市旅顺口区人民法院。

【案件焦点】

1. 孙某是否具有建立劳动关系的主体资格，孙某与某装饰公司之间是否存在事实劳动关系；2. 如双方存在事实劳动关系，能否免除某装饰公司因未签订书面劳动合同而需支付孙某二倍工资差额的法律責任。

【法院裁判要旨】

辽宁省大连市旅顺口区人民法院经审理认为：孙某虽然在2022年3月去其他单位工作，但仍按照某装饰公司要求完成相应的工作内容，某装饰公司应当支付该月工资。孙某主张其工资为每月6000元，并以此计算3月工资，但未提交证据证明其工资标准。某装饰公司自认孙某报酬为每天200元，故按照此标准支持孙某2022年3月的工资为3500元（200元/天×17.5天）。

某装饰公司称，孙某系部队退役军人，已经领取退役金，属于部队退休人员，无法再与其形成劳动关系，双方之间为劳务关系。根据《退役士兵安置条例》第十九条规定，孙某作为自主就业退役士兵，由人民政府扶持自主就业。某装饰公司将孙某等同于部队退休人员，属于概念混淆，其主张无法与孙某形成劳动关系不成立。从法律性质上来说，二倍工资属于惩罚性赔偿，其立法目

的在于惩罚用人单位应当签订而故意不签订劳动合同的违法行为。某装饰公司因对孙某身份存在认知混淆，认为双方之间存在劳务关系而未签订劳动合同，不存在主观恶意或者故意，对孙某二倍工资差额的诉讼请求不予支持。

辽宁省大连市旅顺口区人民法院依据《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条，《中华人民共和国劳动合同法》第八十二条，《退役士兵安置条例》第十九条之规定，判决如下：

一、某装饰公司于判决生效之日起十日内支付孙某2022年3月工资3500元；

二、驳回孙某的其他诉讼请求。

孙某和某装饰公司均不服一审判决，提出上诉。辽宁省大连市中级人民法院经审理认为：孙某是自主择业退役军人，尚未达到法定退休年龄，也尚未享受养老保险待遇。根据《中华人民共和国退役军人保障法》相关规定，自主择业退役军人具有建立劳动关系的主体资格，亦能参加当地社会保险。某装饰公司以孙某已享受退休待遇以及用人单位不能为其缴纳社会保险为由，主张孙某不具有建立劳动关系的主体资格于法无据。孙某入职后接受某装饰公司的考勤、工作管理，工作内容属于某装饰公司的业务组成部分，某装饰公司每月向孙某支付工资，双方成立事实劳动关系。

因双方未签订书面劳动合同，双方对于约定工资标准各执一词。鉴于某装饰公司作为用人单位未能提供其应掌握管理的员工工资清单和考勤记录，对于每月支付孙某款项的具体组成无法作出解释说明，应承担举证不能的诉讼不利后果。结合工资转账记录体现部分月份转款性质为“工资和报销”，部分月份仅体现转款性质为“工资”的转款数额为6000元，法院采纳孙某的相关事实陈述，认定双方约定月工资为6000元，每月支付超出工资的部分为报销款项。某装饰公司应支付孙某2022年3月工资4828元（6000元÷21.75天×17.5天），孙某上诉主张4565.22元是对其权利的合法处分，法院予以支持。

在有法律明确规定鼓励和扶持退役军人就业的情况下，某装饰公司作为用

人单位在与孙某建立用工关系时应依法履行签订书面劳动合同的法定义务，该义务不因其对孙某身份的认知混淆而免除。另，某装饰公司二审自认同期也未与其他员工签订过劳动合同。某装饰公司未能举证证明是因孙某的个人原因造成双方未能签订书面劳动合同，孙某诉请未签劳动合同二倍工资差额于法有据。某装饰公司应当按照《中华人民共和国劳动合同法》第八十二条规定，向孙某支付自2021年5月至2022年3月的二倍工资差额合计58855.22元（6000元×8个月+3290元+3000元+4565.22元）。

辽宁省大连市中级人民法院依照《中华人民共和国劳动合同法》第七条、第十条、第三十条、第八十二条，《中华人民共和国退役军人保障法》第二十二条、第三十九条、第四十七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第二项规定，判决如下：

一、撤销大连市旅顺口区人民法院（2022）辽0212民初3706号民事判决；

二、上诉人某装饰公司于本判决生效之日起十日内支付上诉人孙某2022年3月工资4565.22元；

三、上诉人某装饰公司于本判决生效之日起十日内支付上诉人孙某未签劳动合同二倍工资差额58855.22元；

四、驳回上诉人孙某的其他诉讼请求；

五、驳回上诉人某装饰公司的上诉请求。

【法官后语】

劳动法律关系项下的两方主体即“劳动者”和“用人单位”都要具备法律、法规规定的主体资格，双方才能形成劳动关系。原劳动和社会保障部《关于确立劳动关系有关事项的通知》第一条明确规定：“用人单位招用劳动者未订立书面劳动合同，但同时具备下列情形的，劳动关系成立。（一）用人单位和劳动者符合法律、法规规定的主体资格；（二）用人单位依法制定的各项劳动规章制度适用于劳动者，劳动者受用人单位的劳动管理，从事用人单位安排的有报酬的劳动；（三）劳动者提供的劳动是用人单位业务的组成部分。”

对于我国公民取得劳动者资格的法定条件，根据现行相关规定是以公民的

年龄以及是否享受基本养老保险待遇作为限定条件。《中华人民共和国劳动法》第十五条规定：“禁止用人单位招用未满十六周岁的未成年人。文艺、体育和特种工艺单位招用未满十六周岁的未成年人，必须遵守国家有关规定，并保障其接受义务教育的权利。”《中华人民共和国劳动合同法》第四十四条规定，劳动者开始依法享受基本养老保险待遇的，劳动合同终止。《中华人民共和国劳动合同法实施条例》第二十一条规定：“劳动者达到法定退休年龄的，劳动合同终止。”

对于退役军人是否符合劳动者身份的认定。根据《中华人民共和国劳动法》第十四条的规定，退出现役的军人的就业，法律、法规有特别规定的，从其规定。《中华人民共和国退役军人保障法》第二十二条第一款规定：“对退役的军士，国家采取逐月领取退役金、自主就业、安排工作、退休、供养等方式妥善安置。”其第二款至第六款进一步明确了五种安置方式：(1)服现役满规定年限，以逐月领取退役金方式安置的，按照国家有关规定逐月领取退役金。(2)服现役不满规定年限，以自主就业方式安置的，领取一次性退役金。(3)以安排工作方式安置的，由安置地人民政府根据其服现役期间所做贡献、专长等安排工作岗位。(4)以退休方式安置的，由安置地人民政府按照国家保障与社会化服务相结合的方式，做好服务管理工作，保障其待遇。(5)以供养方式安置的，由国家供养终身。

另外，《中华人民共和国退役军人保障法》第三十九条“各级人民政府应当加强对退役军人就业创业的指导和服务。县级以上地方人民政府退役军人工作主管部门应当加强对退役军人就业创业的宣传、组织、协调等工作，会同有关部门采取退役军人专场招聘会等形式，开展就业推荐、职业指导，帮助退役军人就业”、第四十七条“用人单位招用退役军人符合国家规定的，依法享受税收优惠等政策”等规定亦体现了国家鼓励、支持和保障符合劳动者主体资格的退役军人再就业。

根据上述规定，除了以退休方式和以供养方式安置的退役军人应视为已享受退休待遇外，对于未达到法定退休年龄的自主择业退役军人所领取的退役金从其设立目的上看在于辅助其再就业，而不是让其“提前享受退休待遇”。因

此，像本案孙某这种尚未达到法定退休年龄、未享受养老保险待遇的自主择业退役军人，符合成立劳动关系的法定主体资格。

用人单位自用工之日起即与劳动者建立劳动关系，应当自用工之日起一个月内订立书面劳动合同。用人单位与劳动者签订书面劳动合同，是用人单位的法定义务。根据《中华人民共和国劳动合同法》第八十二条第一款规定：“用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，应当向劳动者每月支付二倍的工资。”该规定中的二倍工资具有惩罚性赔偿性质。因此，非因用人单位的过错（如不可抗力、劳动者本人的原因等）造成其未在法定期限内与劳动者订立书面劳动合同，应当免除用人单位的赔偿责任。在有法律明确规定鼓励和扶持退役军人就业的情况下，本案中的用人单位在与孙某建立用工关系时应依法履行签订书面劳动合同的法定义务，该义务不因其对孙某身份的认知混淆而免除，应承担未签劳动合同二倍工资差额的给付责任。

编写人：辽宁省大连市中级人民法院 刘婷娜

确认劳动关系应以“事实优先”为原则， 且兵团职工可以建立双重劳动关系

——乔某诉某物资公司劳动争议案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

新疆维吾尔自治区高级人民法院伊犁哈萨克自治州分院(2023)新40民终645号民事判决书

2. 案由：劳动争议

3. 当事人

原告(上诉人): 乔某

被告(被上诉人): 某物资公司

【基本案情】

乔某之夫苟某经人介绍于2011年6月入职某物资公司,某物资公司为苟某提供车辆,苟某负责驾驶货车去B地拉运粉煤灰。2022年4月23日,苟某驾驶货车从混凝土公司卸完货后返回A地途中,突发疾病身亡。2022年3月10日,某物资公司(甲方)与苟某(乙方)签订了一份《劳务合同书》,合同主要内容有:第一条本合同期限自2022年3月10日起至2022年10月31日止,合同期满,双方不持异议继续顺延。第二条甲方安排乙方从事车辆驾驶工作,甲方因经营需要并根据乙方工作表现,可调整乙方工作。乙方不同意甲方调整内容的,即视为甲乙双方解除劳务合同关系。第三条乙方提供劳务,甲方按实际毛利提成发放劳务费。第五条甲方按现行运输劳务标准提成向乙方支付劳务费,甲方支付劳务费为每月20日。乙方劳务费数额以甲方当月结算为准,乙方对此有异议可在收到劳务费三日内向甲方提出。合同履行期间若甲方对乙方工作进行调整或实行新的劳务费提成标准时,乙方的劳务费待遇作相应调整。第六条凭劳务发票到甲方处结算劳务费,甲方依法代扣代缴个人所得税。某物资公司在苟某提供劳动期间按照其工作量为其发放了报酬,但存在间断、未连续发放满一年的情况。苟某生前系兵团职工,享有职工身份,兵团为其缴纳了各项社会保险。苟某死亡后,其妻子乔某申请仲裁要求确认苟某与某物资公司之间存在劳动关系,仲裁委裁决双方之间不存在劳动关系。乔某遂提起诉讼。

【案件焦点】

1. 苟某与某物资公司之间是劳务关系还是劳动关系; 2. 苟某系兵团职工是
否能够阻却双方劳动关系的建立。

【法院裁判要旨】

新疆维吾尔自治区奎屯市人民法院经审理认为：劳动关系是指机关、企业、事业、社会团体、个体经济组织和劳动者之间，依照劳动法的规定签订劳动合同，使劳动者成为用人单位的成员，接受用人单位的管理，从事用人单位指定的工作，并获取劳动报酬和劳动保护所产生的法律关系。劳务关系是指劳动者为被服务对象提供特定的劳动服务，被服务方依约支付报酬所产生的法律关系。劳务关系的特点是双方为平等主体，提供的劳动内容具有特定性，双方均按照约定行使权利承担义务，双方主体之间只存在财产关系，彼此之间无从属性，不存在行政隶属关系。本案中，从《劳务合同书》内容来看，该合同中明确约定了按照实际毛利提成发放劳务费，劳务费数额以某物资公司当月结算为准，每月20日支付劳务费。双方对工作时间、基本工资、福利待遇等未作约定。从乔某提供的银行卡交易明细清单及收入纳税明细来看，也可以证明苟某领取劳动报酬是按照运输劳务标准提成发放，每月领取的数额不等，没有提供劳务，当月则没有收入，由此可以说明双方在现实中也是按照劳务合同的约定履行的，故从上述事实及合同的内容可确定双方属于劳务关系。至于乔某提出的某物资公司将苟某纳入职工核酸检测名单、公司通讯录及工作微信群，并为其提供了出入证、宿舍、工服等，系某物资公司为履行劳务合同提供的保障方式，上述情况及证据不能证明其与某物资公司存在劳动管理关系，亦不能推翻双方已按照劳务合同内容实际履行的事实。

新疆维吾尔自治区奎屯市人民法院依照《中华人民共和国民法典》第一百七十六条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条第一款、第一百四十五条之规定，判决如下：

一、驳回乔某的诉讼请求；

二、确认苟某与某物资公司之间自2011年6月至2022年4月23日不存在劳动关系。

乔某不服一审判决，提出上诉。新疆维吾尔自治区高级人民法院伊犁哈萨克自治州分院经审理认为：针对焦点一，苟某与某物资公司应当被认定为劳动

关系,理由如下:虽然某物资公司提供了与苟某之间签订的劳务合同,但是认定双方之间是劳动关系还是劳务关系应当通过双方的行为所产生的权利义务来确认。根据原劳动和社会保障部《关于确立劳动关系有关事项的通知》第一条的规定,第一,双方之间符合建立劳动关系的主体资格。第二,苟某自2011年6月至2022年4月其去世一直在某物资公司从事驾驶员工作,持续时间近11年,虽然每年从事的劳动时间有长有短,但结合银行交易明细可以看出,其领取报酬具有一定的规律性和持续性,还是区别于劳务关系一次性、临时性、短期性特点的,苟某负责运输粉煤灰,该工作也属于某物资公司业务的重要组成部分,某物资公司以苟某完成的工作量为其支付劳动报酬,属于按劳分配的范畴,且苟某的相关待遇与签订劳动合同的员工并无区别。苟某领取工资、维稳费、高温补贴,报销差旅费,进入公司微信工作群,公司为苟某提供宿舍等事宜均是公司对其工作具有一定安排、指示和管理的体现,且苟某在所谓劳务合同期限内并不能随意决定其是否提供劳动,不具有劳务关系中自由支配劳动力的特点,因此可以认定苟某与某物资公司之间已具有人身隶属性的特点。第三,苟某系以某物资公司名义对外提供劳动,并且苟某还领取了某物资公司的工作服、工作证等,其劳动所产生的风险也由某物资公司负担。从上述三点可以看出,双方之间符合建立劳动关系的构成要件,应当认定双方存在劳动关系。针对焦点二,首先,根据查明的事实,苟某系某兵团职工,享有职工身份,某兵团为其缴纳了各项社会保险,其与某兵团之间属全日制劳动关系,并在其为某物资公司提供劳动期间一直存续。苟某虽然不属于《最高人民法院关于审理劳动争议案件适用法律问题的解释(一)》第三十二条第二款规定的“企业停薪留职人员、未达到法定退休年龄的内退人员、下岗待岗人员以及企业经营性停产放长假人员”,但目前我国劳动法律、法规并未禁止双重劳动关系的建立,因此苟某系某兵团职工的事实并不能影响本案中苟某与某物资公司之间建立劳动关系。其次,因苟某系兵团职工,某物资公司无法为其缴纳社会保险及办理退休养老手续,故其与某物资公司的劳动关系具有不稳定性,其只能享有获得报酬、劳动保护及工伤保险等有限劳动者权利,是权利限制性劳动关系,不能完全等同

于劳动合同法规定的全日制劳动关系，应当认定为与非全日制用工相类似的特殊形态的劳动关系。最后，某物资公司不能为苟某缴纳社保不影响双方之间建立劳动关系，且人力资源和社会保障部《实施〈中华人民共和国社会保险法〉若干规定》第九条规定：“职工(包括非全日制从业人员)在两个或者两个以上用人单位同时就业的，各用人单位应当分别为职工缴纳工伤保险费。职工发生工伤，由职工受到伤害时工作的单位依法承担工伤保险责任。”由此可见，工伤保险是两个用人单位可以分别缴纳的，此在法律上并不存在冲突，故某物资公司认为无法缴纳社保就不存在劳动关系的理由缺乏法律依据，不予采信。

新疆维吾尔自治区高级人民法院伊犁哈萨克自治州分院依照原劳动和社会保障部《关于确立劳动关系有关事项的通知》第一条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第二项规定，判决如下：

一、撤销新疆维吾尔自治区奎屯市人民法院(2022)新4003民初2218号民事判决；

二、确认乔某的丈夫苟某与某物资公司自2011年6月至2022年4月23日存在劳动关系。

【法官后语】

在司法实践中，劳动关系与劳务关系如何区分、认定是解决劳动关系纠纷中极具争议、复杂的问题。劳动关系和劳务关系的认定结果，会直接影响到劳动者发生工伤事故后的赔偿问题，尤其是工亡事故中的“突发疾病死亡”，认定劳动关系家属会得到相应赔偿，认定劳务关系则可能面临无法得到赔偿的法律后果，因此如何在审判中准确把握劳动关系和劳务关系的相关认定标准至关重要，本案即涉及此问题。另外，在劳动者已经与其他用人单位存在一个全日制劳动关系的前提下，能否阻却另一个劳动关系的建立，尤其是新疆生产建设兵团职工能否建立双重劳动关系，也是值得研究探讨的重点问题。

一、劳动关系与劳务关系的区别问题

要准确区分劳动关系与劳务关系，必须首先明确这两种法律关系各自的特点。

1. 劳动关系的特点。劳动关系，就是劳动力的所有者一方(劳动者)将自

50 中国法院2025年度案例·劳动纠纷(含社会保险纠纷)

己的劳动力有偿交给另一方(用人单位)使用,劳动者人身在一定程度上受到用人单位的控制,劳动关系呈现人身关系的特征,进而成为一种隶属主体间的以指挥和服从为特征的管理关系。用人单位对于劳动者的管理与支配的权力体现在“从属性”上,此也是劳动关系与一般的民事关系最基本的区别,该从属性主要分为人格上的从属性及经济上的从属性。人格上的从属性主要指劳动者对用人单位的指示服从的义务,表现为:(1)用人单位对劳动者的工作时间、地点和业务内容具有广泛的指示权;(2)劳动者成为用人单位组织中的一员,必须服从用人单位组织中的内部劳动规则,即必须遵守本单位的规章制度;(3)劳动者有接受用人单位的检查以及接受合理制裁的义务。经济从属性主要表现为:(1)生产工具或器械由用人单位所有,原料由用人单位供给;(2)劳动者的工作是作为用人单位所经营的事业整体的、不可分割的一部分,劳动者是为用人单位的事业提供劳动而不是为自己提供劳动;(3)责任与危险负担由雇主负责。因此“事实优先”原则对于判断劳动关系是否存在有至关重要的作用,即不管双方当事人是否订立合同,或以何种名义订立合同,主要考察的应是双方之间的权利义务关系是否具有劳动关系的特点,而不能拘泥于各方或双方如何描述这种关系。

2. 劳务关系的特点。所谓劳务关系是劳动者与用工者根据口头或书面约定,由劳动者向用工者提供一次性的或特定的服务,用工者依约向劳动者支付劳务报酬的一种有偿服务的法律关系。它是两个或两个以上的平等主体之间就劳务事项进行等价交换过程中形成的一种经济关系,各方之间没有隶属性,没有管理与被管理的隶属关系,劳务的提供者自主管理、自由支配劳动力,提供劳务的一方自行承担风险。

3. 劳务关系与劳动关系的区别。劳务关系与劳动关系的区别主要有四点:第一,当事人地位不同。前者当事人之间无组织、隶属关系,地位平等。后者当事人之间存在隶属关系,劳动提供方是接受方的组织成员。第二,标的不同。前者的标的是物化或非物化的劳动成果,后者的标的是劳动力的使用过程。第三,风险责任不同。前者由劳务提供方自担风险,后者由劳动接受方承担劳动

过程中的风险。第四，劳动报酬性质不同。前者的劳务报酬与商品交换中的价款具有同样性质，遵循等价有偿规则，通常由劳务接受方一次性支付或分多次支付。后者的劳动报酬是生活消费品的一种分配形式，遵循按劳分配原则，由劳动接受方持续、定期支付。

在审判实践中结合前述劳动关系、劳务关系各自的特点以及区别，与查明的案件事实进行一一对应和分析，再结合原劳动和社会保障部《关于确立劳动关系有关事项的通知》第一条规定的构成事实劳动关系的三个要件，以及第二条中的相关参照性证据，如考勤表、工资表、工作服、工作证及其他劳动者的证言等，即可判断争议双方是劳动关系还是劳务关系。

二、建立双重劳动关系的相关法律依据

双重劳动关系是指同一个劳动者同时与两个以上的用人单位建立或形成均符合劳动关系构成要件的用工关系，该劳动关系既可能是劳动合同关系，也可能是事实劳动关系。在我国，对于双重劳动关系有以下法律及司法解释的规定：

一是非全日制劳动关系可以存在双重或者多重劳动关系。《中华人民共和国劳动合同法》第六十九条第二款规定：“从事非全日制用工的劳动者可以与一个或者一个以上用人单位订立劳动合同；但是，后订立的劳动合同不得影响先订立的劳动合同的履行。”可以看出，非全日制用工可以有双重或者多重劳动关系，即从事非全日制用工的劳动者可以兼职，这是非全日制用工不同于全日制用工的显著区别之一。但是，允许非全日制用工中有双重或者多重劳动关系，这里的劳动关系均是指非全日制劳动关系，劳动者不能从事一项非全日制工作，同时兼另一项全日制工作。

二是特殊身份的人员可以存在双重或者多重劳动关系。《最高人民法院关于审理劳动争议案件适用法律问题的解释（一）》第三十二条第二款规定：“企业停薪留职人员、未达到法定退休年龄的内退人员、下岗待岗人员以及企业经营性停产放长假人员，因与新的用人单位发生用工争议而提起诉讼的，人民法院应当按劳动关系处理。”

在我国，除去前述关于非全日制双重劳动关系及特殊身份人员可以建立双

重劳动关系的规定外,现行法律对双重劳动关系并没有从正面予以规定,但是也并未明确禁止双重劳动关系的存在,尤其是一些特殊主体因市场因素主动形成的双重劳动关系,也应当类推特殊身份人员规定的情形,如因用人单位原因停产停业只领取生活费的劳动者,季节性、周期性产业的劳动者,不定时工作制劳动者等。

三、新疆生产建设兵团职工能否建立双重劳动关系

在前述明确可以建立双重劳动关系的范围之外,能否允许兵团职工建立双重劳动关系是当下审判中急需解决的问题。

根据《兵团连队职工管理办法(试行)》第三条的规定,兵团连队职工是指办理了录用手续,户籍在师市或团场(镇),在连队承包定额地(身份地),签订了国有农用地承包合同,履行民兵义务,依法按时足额缴纳社会保险费的劳动者。可见兵团职工与兵团之间属于全日制的劳动关系。但现阶段部分兵团职工到地方或者兵团企业提供劳动,在此情况下人民法院必须对兵团职工与另一企业之间能否建立劳动关系进行明确的认定,以保障兵团职工在另一用工关系中的合法权益。

因我国对双重劳动关系的建立并未禁止,兵团这一特殊的建制使得兵团职工也属于特殊身份的人员,其可以参照前述司法解释中的人员进行双重劳动关系的认定。但是,劳动者同时建立一个以上劳动合同法意义上的完整全日制劳动关系没有可操作性的法律依据。原劳动部《关于实行劳动合同制度若干问题的通知》第十七条规定:“用人单位招用职工时应查验终止、解除劳动合同证明,以及其他能证明该职工与任何用人单位不存在劳动关系的凭证,方可与其签订劳动合同。”由此可见,劳动者与两个用人单位建立全日制劳动法律关系,在法律上有一定阻碍。《中华人民共和国劳动合同法》第三十九条第四项“劳动者同时与其他用人单位建立劳动关系,对完成本单位的工作任务造成严重影响,或者经用人单位提出,拒不改正的”,用人单位可以随时解除劳动合同这一规定也恰恰反证了同一劳动者只能与一个用人单位建立全日制劳动关系。因兵团已为其职工缴纳了各项社会保险,另一新的劳动关系与原劳动关系存在较

大区别，在原劳动关系未解除或终止的情形下，新的用人单位无法为其缴纳社会保险及办理退休养老手续。且若兵团有需要职工必须履行的职责时，可随时通知职工上岗。上述因素导致第二份工作形成的劳动关系随时可能解除或终止，具有不稳定性，故尽管兵团职工与新的用人单位之间可以认定形成劳动关系，但其只能享有获得报酬、劳动保护及工伤保险等有限劳动者权利，是权利限制性劳动关系，不能完全等同于劳动合同法规定的全日制劳动关系，应当认定为与非全日制用工相类似的特殊形态的劳动关系。

不少用人单位存在一个误区，即无法为兵团职工缴纳社会保险即表示双方无法建立劳动关系，但是双重劳动关系前提下，不能免除新用人单位参加社会保险的义务，其应当履行缴纳社会保险费用的义务，尤其是工伤保险。人力资源和社会保障部《实施〈中华人民共和国社会保险法〉若干规定》第九条规定：“职工(包括非全日制从业人员)在两个或者两个以上用人单位同时就业的，各用人单位应当分别为职工缴纳工伤保险费。职工发生工伤，由职工受到伤害时工作的单位依法承担工伤保险责任。”可见，工伤保险是两个用人单位可以分别缴纳的，若新用人单位未为职工缴纳工伤保险，劳动者在新用人单位工作期间发生工伤事故的，应当由新用人单位支付工伤待遇。

编写人：新疆维吾尔自治区高级人民法院伊犁哈萨克自治州分院 李霞

共享用工三方法律关系认定标准及司法适用

—— 胡某诉某服务公司确认劳动关系案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

上海市第二中级人民法院(2023)沪02民终7863号民事判决书

2. 案由：确认劳动关系纠纷

3. 当事人

原告(上诉人)：胡某

被告(被上诉人)：某服务公司

【基本案情】

2022年3月，胡某进入某速递公司所属某站点从事快递员工作。之后，甲科技公司与某速递公司达成临时用工协议，由某速递公司安排员工至甲科技公司仓库提供临时服务。经站长询问，胡某同意从事上述临时工作，并与某速递公司若干人员于2022年4月5日共同至某仓库提供劳动。该仓库拣货、打包等业务由某服务公司实际承包，临时用工期间，某服务公司与甲科技公司共同对包括胡某在内的临时用工人员进行用工管理，胡某、某服务公司的总公司、乙科技公司签订《灵活用工协议》，约定由乙科技公司代发工资。某服务公司为胡某购买了商业保险。2022年5月，胡某在工作中受伤，某服务公司通过商业保险为其理赔了医疗费29305.56元。

2022年9月21日，胡某申请劳动仲裁，要求确认其与某服务公司于2022年4月5日至2022年9月20日存在劳动关系。仲裁委对胡某的请求不予支持。胡某不服，诉至法院。

【案件焦点】

1. 本案各方主体是否构成共享用工关系；2. 胡某与某服务公司是否构成劳动关系。

【法院裁判要旨】

上海市宝山区人民法院经审理认为：除从属性外，合意亦是确认双方是否存在劳动关系的核心标准。胡某入职某速递公司站点从事快递员工作，后经其同意被某速递公司安排至某服务公司管理的仓库从事服务，胡某清楚地知晓服务结束后将返回原单位工作。故难以体现胡某系长期稳定地为某服务公司提供劳动，也难以体现双方在临时工作中存在建立劳动关系的合意，无法认定双方

存在劳动关系。

上海市宝山区人民法院根据《中华人民共和国劳动法》第七十八条之规定，判决如下：

驳回胡某要求确认与某服务公司自2022年4月5日至2022年9月20日存在劳动关系的诉讼请求。

胡某不服一审判决，提起上诉。上海市第二中级人民法院经审理认为：共享用工以员工的临时流动方式，实现了人力资源的灵活调配与企业间的互助协作，对解决用工余缺矛盾，提升人力资源配置效率和稳就业发挥了积极作用。共享用工期间，原则上借出单位与劳动者之间存在单一劳动关系，借入单位与劳动者不存在劳动关系。胡某对于其系先人职某速递公司站点，后以“志愿者”身份进入涉案仓库从事临时服务及费用结算方式等事实清楚知晓；对服务结束时间及返回原单位亦有预期，在受伤的情况下也是以某速递公司员工身份寻求解决。难以体现胡某系长期稳定地在某服务公司提供劳动以及双方具有建立劳动关系的合意，结合本案用工形态及涉案背景，各方主体符合共享用工情形，无法认定借入单位某服务公司与被借用劳动者胡某之间存在劳动关系。

上海市第二中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项之规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

共享用工作为灵活用工的重要形式之一，因契合经济形势、就业形势及用工需求而获得发展空间。在审判实践中准确把握共享用工三方法律关系认定标准及适用要点，应厘清共享用工的法律内涵、法理依据、认定标准等，以助推共享用工模式有序发展。

一、共享用工的法律内涵界定

共享用工涉及借出单位（用人单位）、借入单位（缺工单位）和共享员工（劳动者）三方主体。对于共享用工，我国尚未制定法律，目前通过规范性文件形式予以初步规制。根据2020年施行的《人力资源社会保障部办公厅关于做

好共享用工指导和服务的通知》(以下简称《关于共享用工指导服务通知》),可得出共享用工如下特征:共享用工目的是解决用工余缺矛盾、提升人力资源配置效率和稳就业;开展共享用工的企业之间应签订合作协议,明确双方的权利义务关系;原企业应与劳动者协商一致,不改变原企业与劳动者之间的劳动关系等。根据上述通知,可归纳出共享用工之概念,即共享用工是用人单位与缺工单位通过合同约定,将员工由原单位暂时安排至缺工单位工作,员工在此期间维持与原单位的劳动关系,但接受缺工单位的管理,合同约定的工作期限届满后,员工返回原单位工作的用工形式。①

从用工形态看,当前我国共享用工模式采取保持隶属关系不变的情况下将员工派至第三方单位工作一定时间,期满返回原单位的模式。当前,我国共享用工模式基本集中在企业之间,领域多为劳动密集型产业等。随着平台经济崛起,用工形态不断演化,劳动力流动性增强,共享用工将在更广泛的领域发挥更大作用。

二、共享用工的法理依据选择

审判实践中,从明确三方主体权利义务,更好地保护劳动者权益角度出发,共享用工的认定应以《关于共享用工指导服务通知》“原企业与劳动者协商一致,将劳动者安排到缺工企业工作,不改变原企业与劳动者之间的劳动关系”规定为准,即借出单位与劳动者建立一重劳动关系,借出单位与借入单位系委托合同关系,本质是借出单位将指挥管理权或劳动给付请求权转让给借入单位,但借入单位应对雇主责任承担相应连带责任。②

在三方法律关系中,借出单位与共享员工之间系劳动关系,借出单位与借入单位之间系民事合同关系。关于借入单位的法律属性及其与共享员工之间的关系,应突破传统双边用工理论,站在三方关系视角加以审视。借入单位属于

①范围:《从“一重劳动关系”到“双重劳动关系”:共享用工规制路径的重构》,载《环球法律评论》2022年第4期。

②李帛霖:《共享员工视角下企业借调用工的本质及效力认定》,载《中国人力资源开发》2021年第9期。

“利益第三方”，^①共享员工与其具有一定从属性，但此处突破了劳动的人身专属性，仅凭从属性不应推导出两者存在劳动关系。原因在于，共享员工对借入单位系“不完全的从属性”，该“不完全的从属性”来源于借出单位通过民事合同在双方合意范围内对劳动管理权的部分让渡，借入单位对共享员工享有工作指挥管理权，但原则上不具有人事管理权。故相较传统用工关系中完整的从属性，共享员工对借入单位的“不完全从属性”不足以成为双方成立劳动关系之基础，此让渡并非用人单位责任的全部转移。同时，两家单位通过共享协议让渡的工作指挥管理权本质系劳动力使用权，须以劳动者同意为前提，皆因共享用工系劳动合同履行过程中的特殊情况，劳动者与用人单位签订劳动合同时并没有至缺工单位临时工作的预先假设及预见可能性，这也是共享用工与劳务派遣的本质区别。虽借入单位不具有用人单位法律地位，但毕竟行使了工作指挥管理权，亦应在职业伤害等劳动基准层面承担一定连带责任。

三、共享用工的司法认定标准及适用要点

依据《关于共享用工指导服务通知》的规定，对于共享用工三方主体的法律关系，在审判实践中应遵循如下认定标准。

1. 借出单位、借入单位、劳动者三方就共享用工达成合意，或者借出单位与借入单位两方就共享用工达成合意，经劳动者同意的，应认定三方主体之间构成共享用工关系。

2. 共享用工期间，原则上不宜认定劳动者与借出单位、借入单位形成双重劳动关系。借出单位与劳动者之间存在单一劳动关系，若双方未就变更劳动合同内容协议一致，双方劳动权利义务保持不变。借入单位与劳动者不存在劳动关系，但对劳动者享有借出单位让渡的以指挥管理权为主要内容的部分劳动管理权，基于不完全的从属性，应在职业伤害、劳动安全卫生、工作时间和休息休假等方面承担一定程度的雇主连带责任。

本案中，胡某进入某速递公司所属某站点工作。为应对用工短缺问题，甲

^①田思璐：《共享用工：“狭义借调”中的三方合同构成》，载《法学》2022年第1期。

科技公司与某速递公司达成临时用工协议,经胡某同意,将其与某速递公司其他人员派至甲科技公司所属的某仓库提供临时服务,某服务公司负责某仓库的日常管理。临时用工期间,甲科技公司与某服务公司共同对临时服务人员进行管理。对于本案临时用工,各方已达成合意,构成共享用工法律关系。胡某应与借出单位(站点所属公司)存在劳动关系。胡某在诉讼中主张与某服务公司具有从属性,不存在合意无法否定双方成立劳动关系。然,共享用工三方关系中,借出单位仅向借入单位让渡了部分劳动管理权,胡某对借入单位系“不完全的从属性”,不足以成为双方成立劳动关系之基础。加之胡某亦清楚期满将返回原单位等事实,故对其主张与某服务公司存在劳动关系之诉请不予支持。另,某服务公司通过商业保险形式为胡某理赔了近3万元医药费,结合服务期限、薪酬水平等因素,已承担了与借入单位管理权能相对应程度的雇主连带责任,符合权利义务衡平原则。

共享用工的主要目的是站在企业用工管理角度提升人力资源配置效率,其本质是劳动关系实际履行过程中的特殊情形,超出了劳动者预见可能性,具有临时性特征。助推共享用工规范发展,应在实现三方关系中劳动权利义务整体平衡之基础上对共享员工进行特别保护。具体至司法实践中,应注意以下要点:

1. 共享用工的成立须以劳动者同意为前提。劳动关系是具有权利义务专属性的以劳动双方信赖基础为核心的继续性法律关系。《中华人民共和国劳动合同法》规定了劳动合同内容的变更需经劳动双方协商一致,而共享用工中;劳动者的劳动管理主体、工作场所、工作地点以及工作内容等必然或可能发生变化,上述变化属于劳动合同内容的变更,应遵循协商变更的原则,以劳动者同意为前提。

2. 共享用工应通过协议等方式明确劳动者在借入单位的劳动条件、劳动保护、薪资待遇等劳动基准内容以及回归期限。为平衡共享用工模式下劳动管理主体、劳动条件变化对劳动者可能造成的不利影响,应明确劳动者在借入单位工作期间的基本权利义务,借入单位应承担与其指挥管理权相匹配的用工主体责任,为共享员工创设良好、无歧视的就业环境,进行职业技能、安全生产培训,提供必要的劳动条件、履行工作保障及协助义务等,三方亦应明确回归期

限，为劳动者返回原单位提供条件。

3. 应避免共享用工模式被不当滥用。鉴于共享用工对劳动者岗位稳定等影响较大，当前经济形势下，共享用工模式的适用应以满足企业生产经营客观需求为原则，主要应用于因经营困难而稳岗压力大、受季节性及市场供求等临时性因素影响而用工规模波动大的企业，以实现稳岗和用工余缺调剂合作目标。若非基于生产经营客观需求，原则上企业不能开展共享用工，避免企业通过共享用工模式实施替代劳务派遣及其他规避用工主体责任的行为。同时，亦应对共享用工的期限予以适当规制，避免这一临时性的用工模式被长期化。

综上，伴随着平台经济发展，共享用工作为灵活用工的重要形式，还将继续发挥优化人力资源配置、稳定就业及复苏经济的重要作用。故，司法应对共享用工予以规范，以充分发挥其活跃用工市场的制度优势，服务好“稳就业、促经济”的社会发展大局。

编写人：上海市第二中级人民法院 陈樱 张曦

关联公司混同用工模式下劳动关系的确认

——郑某诉甲科技公司劳动争议案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

北京市第二中级人民法院(2023)京02民终9597号民事判决书

2. 案由：劳动争议

3. 当事人

原告(被上诉人): 郑某

被告(上诉人): 甲科技公司

【基本案情】

2021年5月12日,郑某驾驶涉案重型厢式货车与案外人发生交通事故后受伤,此后未再提供劳动。甲科技公司股东兼监事张某1为郑某垫付医药费107500元。

郑某称经人介绍于2021年3月1日入职甲科技公司,岗位为运输司机,双方未签订劳动合同,未缴纳社保,丁科技公司和丙科技公司代发工资,入职系与队长王某商谈,从王某处接手涉案车辆,平时接受王某管理,王某系某供应链公司调度,某供应链公司的现法定代表人与甲科技公司前法定代表人均为张某。甲科技公司否认与郑某存在劳动关系,表示其只是涉案车辆的登记车主,该车辆已于2020年出租给乙科技公司,乙科技公司与丁科技公司、丙科技公司分别签订了《外包项目平台综合服务协议》《服务合同》,通过两公司运营的平台招聘司机,由两公司承揽业务,郑某与丁科技公司、丙科技公司签订协议,从平台注册后接单。

2020年8月7日至2021年11月3日张某为甲科技公司股东兼法定代表人,2020年8月7日至今张某1为甲科技公司股东、监事;乙科技公司成立于2019年3月20日,2019年3月20日至2022年8月25日张某担任法定代表人。乙科技公司自2021年3月10日起为郑某投保雇主责任险。

【案件焦点】

甲科技公司与郑某是否存在劳动关系。

【法院裁判要旨】

北京市房山区人民法院经审理认为:判断用人单位与劳动者是否存在劳动关系,应以实质要件为判断标准,核心要素是用人单位对劳动者形成实际控制,双方形成财产上、人身上的从属性关系。根据各方当事人提交的证据及陈述可知,郑某驾驶甲科技公司车辆从事运输工作,根据平台派单情况显示郑某驾驶车辆运输的承运商名称为甲科技公司,虽甲科技公司主张将车辆出租给乙科技公司,但甲科技公司与乙科技公司系关联公司,郑某从事的工作实际为甲科技

公司业务的一部分；根据微信群聊天记录，显示王某向郑某发送定位、安排工作等内容能够认定郑某接受王某管理，王某自称系某供应链公司员工，能够认定郑某接受某供应链公司调度，某供应链公司对郑某进行管理，而某供应链公司与甲科技公司为关联公司；郑某的工资虽名义上由丁科技公司、丙科技公司代发，但实际上支付主体为甲科技公司的关联公司乙科技公司。以上特征均显示甲科技公司与郑某之间形成财产上、人身上的从属性关系，符合成立劳动关系的法律特征。综上，甲科技公司虽然主张与郑某不存在劳动关系，但与查明事实相悖，故法院不予采信。法院认定甲科技公司与郑某之间存在劳动关系。甲科技公司作为劳动关系中负有管理责任的一方，应对劳动者入职时间、工作年限承担举证义务，其公司未能举证证明，应承担不利后果。结合在案证据，法院对于郑某主张的劳动关系存续期间予以采信，确认双方2021年3月1日至2021年11月30日存在劳动关系。

北京市房山区人民法院依照《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》第六条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十七条之规定，判决如下：

确认郑某与甲科技公司自2021年3月1日至2021年11月30日存在劳动关系。

甲科技公司不服一审判决，提起上诉。北京市第二中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

关联公司，作为一种更具规模性和竞争性的企业组织形态，已成为一种普遍存在的经济现象。实践中，部分关联公司为创新业务模式或规避用工风险往往将劳动关系诸要素打散，劳动者分别与多家公司存在一定关联，但又找不到确定、完整的用工主体，出现纠纷后关联公司之间相互推诿责任。人民法院在审理此类混同用工案件时，面临用工主体多元、用工结构复杂、劳动关系认定困难等现实挑战。

司法实践中，关联公司混同用工案件，主要有以下几种类型。

62 中国法院2025年度案例·劳动纠纷(含社会保险纠纷)

一是“一套人马，多块牌子”，混淆用工。实践中多家关联公司的法定代表人、控股股东或实际控制人等为同一人或具有亲属关系，办公场所、人事财务、业务内容等高度混同，往往不与劳动者签订劳动合同，故意混淆用工，劳动者亦无法知晓自己到底属于哪一家单位。

二是采用出租合同、承包合同等形式，隐蔽用工。实践中部分关联公司在发生劳动纠纷时，往往主张相应场地、设备、业务等已出租、承包给第三人经营，劳动者与第三人存在劳动关系等。用人单位表面上与关联公司之间签订出租合同、承包合同等普通民事合同，但对劳动者的招录聘用工作时间、工作内容、工作过程等进行实际管理，导致劳动关系认定、劳动者工龄计算、社会保险缴纳等均存在不同隐患。

三是不断变换主体，交替用工。实践中部分集团公司通过变换不同的签约主体和劳动者签署劳动合同，劳动者的工作内容、管理隶属等没有发生明显变化，但劳动合同、工资发放、社保缴纳等可能分布在不同的子公司或分公司。关联公司交替轮流用工，以此规避支付经济补偿、签订无固定期限劳动合同等法律义务。

关联公司混同用工情形下，相关用工事实查明困难，劳动关系扑朔迷离。保护劳动者的合法权益，是劳动法的立法宗旨，而确认劳动关系是各项劳动权益保障的起点。实践中应当坚持事实优先原则，无论存在多少主体，都应根据劳动合同签订、用工管理事实等作出综合判断，必要时可以尊重劳动者的选择权。

从程序上而言，人民法院可以依据劳动者申请或者依职权追加其他关联公司参加诉讼，以查清用工事实，减少劳动者诉累。本案中，郑某驾驶甲科技公司车辆发生交通事故，为认定工伤无奈寻求确认劳动关系。甲科技公司辩称已将车辆出租给乙科技公司，而从在案证据来看，两公司之间存在关联关系。乙科技公司则辩称属于平台用工，和郑某不存在劳动关系，用工链条进一步拉长。一审法院依法通知某供应链公司、丁科技公司、丙科技公司作为第三人参加诉讼，进一步查清事实。

从实体上而言，多家关联公司混同用工，劳动关系诸要素分散、交叉的情形下，可以将招录聘用、日常管理、绩效考核、工资支付、保险缴纳等综合作为判断劳动关系的因素。一般而言，(1)订立劳动合同的，可以按照劳动合同确立劳动关系；(2)未订立劳动合同的，以有关联关系的用人单位发放工资、缴纳社会保险、工作地点、工作内容、日常管理等与劳动合同履行相关的要素综合进行判断；(3)难以厘清与哪家用人单位存在劳动关系的，因为造成劳动关系混同的过错在于多家关联公司，从诉讼经济角度考虑，也可以依据劳动者的选择进行确认。本案中，甲科技公司系车辆所有人，为郑某垫付医药费，某供应链公司对郑某进行日常管理，乙科技公司为郑某投保了雇主责任险，三家公司存在关联关系，均未与郑某签订劳动合同，法院依据郑某的选择确认与甲科技公司存在劳动关系。此外，本案中乙科技公司与丁科技公司、丙科技公司签订相关协议，由后者与郑某签订相关协议、代发工资。用人单位招录劳动者后，要求劳动者在互联网平台注册为自由职业者、独立承包商等，并通过互联网平台代发工资等方式规避与劳动者建立劳动关系的，人民法院应依据实际用工情况进行认定，以维护劳动者合法权益。

编写人：北京市第二中级人民法院 马卫丰

承包人与实际施工人招用的工人之间劳动关系的认定

——黄某甲诉某电力建设公司、吴某劳动合同案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

广西壮族自治区南宁市中级人民法院(2023)桂01民终8196号民事判决书

2. 案由：劳动合同纠纷

3. 当事人

原告(被上诉人): 黄某甲

被告(上诉人): 某电力建设公司

被告: 吴某

【基本案情】

2014年7月18日, 某电力建设公司与案外人供电局签订《S 线路工程、T 线路工程施工合同》, 由某电力建设公司承包线路工程施工任务。吴某系挂靠某电力建设公司对案涉工程进行施工。为了方便发放领取工程款, 某电力建设公司与第三人某劳务公司于2015年8月25日签订《建筑施工分包合同》, 第三人某劳务公司通过该公司账户把工程款转给吴某, 但是第三人某劳务公司没有对案涉工程进行实际施工。

2016年, 黄某甲经吴某介绍在该线路工程担任项目总工, 工作期间某电力建设公司未与黄某甲签订劳动合同。吴某请求某电力建设公司在工作期间为黄某甲缴纳社会保险, 某电力建设公司遂于2016年4月至2018年12月为黄某甲缴纳了企业养老保险、工伤保险、失业保险。

2019年1月16日, 吴某向黄某甲出具《欠款凭证》, 内容主要是“本人吴某因至2018年2月前期工资款未能全部完结以及至2018年12月未能给付工资, 长期累积共欠黄某甲人民币贰拾壹万元整(¥210000元), 经双方协商, 吴某已无能力给予支付, 将由某电力建设公司在G 线路工程的工程款到账时由某电力建设公司财务直接扣款付给黄某甲, 经某电力建设公司黄某乙现场确认并证明。另和某电力建设公司证明人一起, 经三方协商黄某甲从2019年1月起在G 线路工程所工作的所有费用(包含工资、车辆费用、旅差费等)经吴某确认签字后, 由某电力建设公司财务先按月给予垫付, 所垫费用在日后工程款到账后, 由某电力建设公司直接扣除。债权人可以任意以任何方式收取逾期欠款, 或人民法院依法解决, 本欠款有无限追诉时效, 以此凭证为据”, 在落款处有欠款人吴某签字, 债权人黄某甲签字, 某电力建设公司盖章, 证明人黄某乙签字, 法定代表人肖某于2020年1月19日签字。黄某甲在收到《欠款凭证》

后即离开不再在该项目工作。

此后黄某甲向隆安县劳动人事争议仲裁委员会提出仲裁申请，2023年3月15日仲裁机构作出裁决驳回黄某甲的请求，黄某甲收到仲裁裁决书后不服并向法院起诉，形成本案。

【案件焦点】

1. 黄某甲与某电力建设公司在2016年4月至2018年12月31日是否存在事实劳动关系；2. 本案是否超过诉讼时效。

【法院裁判要旨】

广西壮族自治区隆安县人民法院经审理认为：原告黄某甲主张与某电力建设公司形成事实劳动关系，某电力建设公司则反驳认为把工程交给吴某去做，然后是吴某叫黄某甲来工作，是由吴某雇请黄某甲。第三人则主张实际施工人是吴某，第三人没有实际施工。法院认为，黄某甲承认是吴某介绍来工作的，并且从《欠款凭证》的内容来看，吴某拖欠了黄某甲工资，因吴某无力支付，由某电力建设公司从到账工程款中直接扣款付给黄某甲。该凭证内容与某电力建设公司的主张相一致，吴某既然负有向黄某甲支付工资的义务，那么吴某与黄某甲之间必然存在事实上的法律关系，故法院采纳某电力建设公司的意见。根据原劳动和社会保障部《关于确立劳动关系有关事项的通知》规定，“建筑施工、矿山企业等用人单位将工程(业务)或经营权发包给不具备用工主体资格的组织或自然人，对该组织或自然人招用的劳动者，由具备用工主体资格的发包方承担用工主体责任”，据此，吴某招用黄某甲，某电力建设公司应该承担用工主体责任。又根据最高人民法院《对最高人民法院〈全国民事审判工作会议纪要〉第59条作出进一步释明的答复》中对实际施工人招用的劳动者与承包人之间是否存在劳动关系的答复意见，是“同意第一种观点”，即“不认定实际施工人的前一手具有用工主体资格的承包人、分包人或转包人与劳动者之间存在劳动关系”，据此，某电力建设公司从供电局处承包本案工程，某电力建设公司是承包人，劳动者黄某甲请求确认其与具有用工主体资格的某电力

建设公司之间存在劳动关系，法院不予支持，同时对黄某甲要求支付经济补偿金的请求亦不予支持。

既然不能认定为劳动关系，则不适用劳动仲裁的1年时效规定。《欠款凭证》落款签字时间是2019年1月16日，而某电力建设公司法定代表人肖某最后的签字时间是2020年1月19日。黄某甲于2021年11月向法院第一次起诉，所以不论是从2019年1月16日还是从2020年1月19日起算，均没有超过诉讼时效。并且《欠款凭证》第一段中未能明确具体履行日期，所以某电力建设公司主张超过诉讼时效的请求，法院不予采纳。

从《欠款凭证》的内容来看，吴某存在拖欠黄某甲工资的事实，根据《中华人民共和国民法典》第五百七十九条“当事人一方未支付价款、报酬、租金、利息，或者不履行其他金钱债务的，对方可以请求其支付”的规定，据此，黄某甲要求吴某支付拖欠工资有法律和合同依据，法院予以支持。而且，从《欠款凭证》第一段内容来看，因吴某无力支付，故由某电力建设公司从到账工程款中直接扣款付给黄某甲。所以《欠款凭证》约定某电力建设公司承担的是附条件的扣款义务，如果工程款到账，则某电力建设公司负有支付该款项给黄某甲的义务。某电力建设公司当庭表示工程款已到账，故《欠款凭证》约定的条件成立，附生效条件的民事法律行为，自条件成就时生效。据此，黄某甲要求某电力建设公司支付210000元款项有法律和合同依据，法院予以支持。

广西壮族自治区隆安县人民法院依照《中华人民共和国民法典》第一百五十八条、第五百七十九条，《中华人民共和国劳动合同法》第七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十七条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第五十四条之规定，判决如下：

- 一、吴某、某电力建设公司支付黄某甲款项210000元；
- 二、驳回黄某甲的其他诉讼请求。

某电力建设公司不服一审判决，提起上诉。广西壮族自治区南宁市中级人民法院经审理认为：根据原劳动和社会保障部《关于确立劳动关系有关事项的通知》第四条“建筑施工、矿山企业等用人单位将工程(业务)或经营权发包

给不具备用工主体资格的组织或自然人，对该组织或自然人招用的劳动者，由具备用工主体资格的发包方承担用工主体责任”之规定，某电力建设公司从供电局处承包涉案工程，吴某系挂靠某电力建设公司对案涉工程进行施工。吴某招用黄某甲，某电力建设公司应该对黄某甲承担用工主体责任，某电力建设公司与黄某甲建立的是劳务关系而不是劳动关系，因此，涉案诉讼应适用诉讼时效而非仲裁时效。涉案诉讼实际上是基于《欠款凭证》而引发的纠纷，《欠款凭证》中某电力建设公司的签字时间是2020年1月19日，黄某甲于2021年11月向法院提起诉讼，未超过诉讼时效。

广西壮族自治区南宁市中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项和第一百八十二条的规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

在建筑施工领域，对于实际施工人招用的劳动者与发包人、承包人之间关系的界定，审判工作中认识不一，当前审判实务中主要有三种观点。

1. 不存在劳动关系说。此为主流观点。最高人民法院《对最高人民法院〈全国民事审判工作会议纪要〉第59条作出进一步释明的答复》中对实际施工人招用的劳动者与承包人之间是否存在劳动关系的答复意见，是“同意第一种观点”，即“不认定实际施工人的前一手具有用工主体资格的承包人、分包人或转包人与劳动者之间存在劳动关系”。因为实际施工人的前一手具有用工主体资格的承包人、分包人或转包人与劳动者之间丝毫没有建立劳动关系的意思表示，更没有建立劳动关系的合意。如果强行认定为劳动关系，那么实际雇佣劳动者并承担管理职能的实际施工人反而不需要承担任何法律责任了，这种处理方式显然不符合公平原则。

2. 事实劳动关系说。此种观点认为，虽然案涉工程层层转包、分包给不具备用工主体资格的实际施工人，但是实际施工人招用的劳动者在具体提供劳务的过程中，受承包人、分包人、转包人管理，工资由其发放，劳动关系的特征符合原劳动和社会保障部《关于确立劳动关系有关事项的通知》规定的构成要

件,此时应当认定双方存在劳动关系。

3. 用工主体责任说。原劳动和社会保障部《关于确立劳动关系有关事项的通知》第四条规定:“建筑施工、矿山企业等用人单位将工程(业务)或经营权发包给不具备用工主体资格的组织或自然人,对该组织或自然人招用的劳动者,由具备用工主体资格的发包方承担用工主体责任。”这是用工主体责任说的具体体现。

笔者赞同第一种观点,同时认为,在确认或不确认劳动关系的背后,如果牵连工伤责任的承担问题,可以采用两分法,即将劳动关系的确认与工伤责任问题分开而论。

首先,根据当前建设工程施工领域的实践情况,绝大部分被实际施工人招用的劳动者与发包人、承包人、转包人不宜认定存在劳动关系,这是主流观点。但是也要具体情况具体分析,对于工程被层层分包而劳动者又被劳动部门认定为工伤的,要求用人单位参照工伤进行赔偿的,应予支持赔偿工伤为宜。理由是此种情形符合劳动合同法的规定,《中华人民共和国劳动合同法》第九十四条“个人承包经营违反本法规定招用劳动者,给劳动者造成损害的,发包的组织与个人承包经营者承担连带赔偿责任”的规定,为承担民事赔偿责任的条款,而非确认劳动关系的依据。即使不确认为劳动关系,劳动者的权益也得到了保护。

其次,有观点认为,用工单位承担“用工主体责任”或“工伤保险责任”并不意味着与职工存在劳动关系。^①此时承包人对劳动者承担的是一种替代责任,因为承包人将工程业务转包给没有用工资格的实际施工人,主观上存在过错,让其承担工伤保险责任,作为不具有劳动关系的替代责任,逻辑上合理。

最后,将劳动关系的确认与工伤责任问题分开而论也符合司法解释的规定。《最高人民法院关于审理工伤保险行政案件若干问题的规定》第三条第一款第

^①参见最高人民法院中国应用法学研究所编:《人民法院案例选分类重排本(2016-2020)·行政与国家赔偿卷》第六章“劳动与社会保障”第二节“工伤”,人民法院出版社2022年版,第321、322页。

四项规定,“用工单位违反法律、法规规定将承包业务转包给不具备用工主体资格的组织或者自然人,该组织或者自然人聘用的职工从事承包业务时因工伤亡的,用工单位为承担工伤保险责任的单位”,通过解读上述规定,可以知道不论违法转包是否构成劳动关系,用人单位都应该承担工伤保险责任。也即把确认劳动关系与承担工伤责任问题区分开来,目的在于更好地保护劳动者的合法权益。

编写人:广西壮族自治区隆安县人民法院 凌全民

未签订劳动合同情况下, 挂靠经营模式中的劳动关系主体认定

—— 某体育发展公司诉董某、某体育文化中心劳动争议案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

北京市第二中级人民法院(2023)京02民终8732号民事判决书

2. 案由: 劳动争议

3. 当事人

原告(上诉人): 某体育发展公司

被告(被上诉人): 董某、某体育文化中心

【基本案情】

2021年7月12日,王某与某体育文化中心签订《游泳健身俱乐部承租管理合作协议》,约定:2021年7月15日至2024年7月15日由王某管理案涉健身房,负责健身房销售人员的招聘、培训、管理等,某体育文化中心配合提供

营业执照、泳池高危许可证、消防验收许可、公章、财务章等材料，王某向某体育文化中心支付房租，健身房的盈利收入归王某所有。

2021年9月9日，王某与周某签订《公司托管经营协议书》，约定：从2021年9月2日起至2022年3月12日止，王某委托周某经营管理案涉健身房，向周某支付经营管理费用，经营活动相关的各项成本、人员工资等均由王某承担。

某体育发展公司于2021年10月9日注册成立，王某为该公司的法定代表人。

董某于2021年9月28日至2021年12月31日在案涉健身房工作，担任私教经理一职。该健身房的经营地点与某体育文化中心的工商注册地一致。董某的工资每月由王某通过微信转账形式支付；钉钉打卡记录截图显示的部门为某体育发展公司，打卡地点为某体育发展公司(某体育文化中心的工商注册地)。

董某与某体育发展公司、某体育文化中心均未签订书面劳动合同。

某体育发展公司主张某体育文化中心委托王某管理案涉健身房，王某又委托周某进行经营管理，董某是周某招聘录用的，王某是代某体育文化中心向董某发放工资，故董某与其不存在劳动关系，与某体育文化中心存在劳动关系，不同意由其支付未签订劳动合同二倍工资差额。董某表示从未被告知过某体育文化中心的情况，否认与某体育文化中心存在劳动关系。

【案件焦点】

1. 某体育发展公司、董某是否形成劳动关系；2. 劳动关系的形成时间如何确定；3. 未签订书面劳动合同的二倍工资的计算方式。

【法院裁判要旨】

北京市丰台区人民法院经审理认为：本案的争议焦点有三：一是某体育发展公司、董某是否形成劳动关系；二是某体育发展公司、董某劳动关系形成的时间；三是某体育发展公司应支付董某未签订书面劳动合同的二倍工资的计算方式。

针对第一个焦点，法院认为某体育发展公司、董某之间形成劳动关系。原

劳动和社会保障部《关于确立劳动关系有关事项的通知》第一条规定：“用人单位招用劳动者未订立书面劳动合同，但同时具备下列情形的，劳动关系成立。

（一）用人单位和劳动者符合法律、法规规定的主体资格；（二）用人单位依法制定的各项劳动规章制度适用于劳动者，劳动者受用人单位的劳动管理，从事用人单位安排的有报酬的劳动；（三）劳动者提供的劳动是用人单位业务的组成部分。”本案中，董某在案涉健身房担任私教经理，根据本案查明之事实，租赁该地址经营的公司系某体育发展公司，实际经营管理案涉健身房并向董某支付工资的均系某体育发展公司法定代表人王某，且董某提交的钉钉打卡记录截图显示打卡部门和地点均为某体育发展公司。综合上述情况，董某接受某体育发展公司的管理，从事其安排的有报酬的劳动，某体育发展公司、董某之间的关系完全符合上述特征，应当认定某体育发展公司与董某之间存在劳动关系。

针对第二个焦点，双方当事人均认可董某在2021年9月28日至2021年12月31日在案涉健身房工作，但经法院查明，某体育发展公司于2021年10月9日注册成立，此前某体育发展公司不具备法律规定的用工主体资格，故法院认定某体育发展公司与董某的劳动关系始于2021年10月9日，解除于2021年12月31日。

针对第三个焦点，某体育发展公司于2021年10月9日注册成立，在此之前，某体育发展公司虽已聘用董某，因某体育发展公司主体不合格，某体育发展公司、董某不具备订立劳动合同的客观条件，某体育发展公司注册成立后，未在一个月内与董某订立劳动合同，故某体育发展公司应向董某支付自2021年11月9日至2021年12月31日双方实际解除劳动关系期间未签订劳动合同的二倍工资差额。仲裁裁决某体育发展公司支付董某自2021年10月28日至2021年12月31日未签订劳动合同的二倍工资差额，期间错误，法院依法予以调整。此外，庭审中某体育发展公司与董某均一致认可仲裁裁决计算方法中对工资标准的认定，法院依法核算未签订劳动合同的二倍工资差额为12149.43元。

结合案涉健身房内录像、《游泳健身俱乐部承租管理合作协议》、《丰台区职能部门安全生产督查检查通知单》等证据，某体育发展公司自某体育文化中

心处承租案涉健身房，该店对外经营主体为某体育文化中心，但王某与某体育文化中心签订上述《游泳健身俱乐部承租管理合作协议》的目的就是从事某体育文化中心拥有经营权的游泳等业务，并由此获得利润。因此，店内摆放某体育文化中心的营业执照、卫生证和高危证只是为了应对有关部门的检查，并不能证明某体育文化中心与董某之间存在事实劳动关系。同时，某体育文化中心为案涉健身房提供上述证件是基于该公司与王某之间的合作协议所约定的合同义务，而不是基于该公司与董某形成事实劳动关系才为之。此外，董某表示从未被告知过某体育文化中心的情况，否认与某体育文化中心存在劳动关系。综上，某体育发展公司主张董某与某体育文化中心之间存在事实劳动关系既无事实基础，亦缺乏法律依据，法院不予采信。

北京市丰台区人民法院依照《中华人民共和国劳动合同法》第八十二条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十七条之规定，判决如下：

一、某体育发展公司于判决生效后七日内支付董某2021年11月9日至2021年12月31日未签订劳动合同二倍工资差额12149.43元；

二、某体育发展公司无须支付董某2021年10月28日至2021年11月8日未签订劳动合同二倍工资差额2494.25元；

三、驳回某体育发展公司的其他诉讼请求。

某体育发展公司不服一审判决，提出上诉。北京市第二中级人民法院经审理认为：董某主张其于2021年9月28日入职某体育发展公司，在案涉健身房工作，双方未订立书面劳动合同，并提交钉钉打卡记录截图、工作群微信聊天记录、企业微信记录、微信电子支付凭证截屏等证据。某体育发展公司认可其公司法定代表人王某实际管理案涉健身房，亦认可微信电子支付凭证截屏显示的王某规律性地向董某支付工资的事实。某体育发展公司虽辩称系王某个人接受某体育文化中心委托管理案涉健身房，亦系代某体育文化中心发放董某工资，但是其公司提交的《游泳健身俱乐部承租管理合作协议》《公司托管经营协议书》《丰台区职能部门安全生产督查检查通知单》等证据不足以证明上述事实，亦无法体现某体育文化中心依法制定的各项劳动规章制度适用于董某，董某受

某体育文化中心的实际管理，从事某体育文化中心安排的有报酬的劳动。董某表示并不知晓某体育文化中心情况，结合其提交的证据内容，现仅凭其在某体育文化中心的注册地提供劳动的情况，不足以认定其系与某体育文化中心存在劳动关系。故，某体育发展公司关于某体育文化中心实际经营健身房并与董某存在劳动关系的主张，事实依据不足。此外，其他公司缴纳董某诉争期间社保的情况，不影响本案劳动关系的认定。据此，一审法院综合考虑在案证据情况，认定董某与某体育发展公司存在劳动关系，并判决其公司支付董某2021年11月9日至2021年12月31日未签订劳动合同二倍工资差额12149.43元，并无不当。某体育发展公司坚持上诉请求，事实依据不足，法院不予支持。综上所述，某体育发展公司的上诉请求不能成立，应予驳回；一审判决应予维持。

北京市第二中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

本案涉及多方主体：某体育发展公司、某体育文化中心、王某及周某，劳动者董某未与任何一方签订书面劳动合同，因此首先需要判断董某与哪一方主体形成劳动关系。

王某与某体育文化中心签订了《游泳健身俱乐部承租管理合作协议》，但合同的性质不能仅凭合同的名称认定，而应当根据双方约定的合同内容及合同实际履行过程中体现出来的双方的权利义务关系综合认定。

首先，从合同目的来看，王某签订合同的目的是从事某体育文化中心拥有经营权的游泳等业务，并由此获得利润；其次，从合同内容来看，王某向某体育文化中心支付费用以使用某体育文化中心的工商注册地及营业执照、泳池高危许可证、消防验收许可、公章、财务章等，自主经营案涉健身房并承担风险、获得收益；最后，从合同履行来看，案涉健身房内录像显示店内摆放某体育文化中心的证照、《丰台区职能部门安全生产督查检查通知单》载明被督查检查单位为某体育文化中心等，可以看出案涉健身房对外经营主体为某体育文

化中心。综上，王某与某体育文化中心之间名为“承租管理合作”，实为挂靠经营合同关系。

在挂靠经营模式下，对于适格主体之间，劳动者与谁形成劳动关系，具体需根据用工行为的“三性”特征——人格从属性、经济从属性、组织从属性进行实质判断。

司法实践中，原劳动和社会保障部《关于确立劳动关系有关事项的通知》是认定劳动关系的主要依据。根据该通知规定，未签订劳动合同情况下，认定劳动关系需同时符合以下条件。

1. 用人单位和劳动者符合法律、法规规定的主体资格。《中华人民共和国劳动法》第二条规定：“在中华人民共和国境内的企业、个体经济组织(以下统称用人单位)和与之形成劳动关系的劳动者，适用本法。国家机关、事业组织、社会团体和与之建立劳动合同关系的劳动者，依照本法执行。”可见，用人单位必须是一个依法成立的组织，包括但不限于企业法人、事业单位法人、社会团体法人、个体工商户等。王某作为个人显然不具备法律规定的用工主体资格，而王某作为法定代表人的某体育发展公司在注册成立后虽然具备了建立劳动关系的主体资格，但此时案涉健身房的挂靠方仍是王某还是变更为某体育发展公司呢？这就涉及该公司注册成立前王某以个人名义与某体育文化中心签订的合同是否对公司有效这一问题。

法定代表人在公司成立前以个人名义对外签订的合同，原则上是属于其个人行为，对成立后的公司并不当然有效，主要考虑以下因素：(1) 合同内容：合同是否与成立后的公司业务直接相关，是否旨在为公司成立后的运营做准备。(2) 公司追认：公司成立后，可以对法定代表人在公司成立前签订的合同进行追认或通过合同转让等方式，从而使得合同对公司产生效力。(3) 实际履行：合同是否已经开始履行，公司成立后是否继续履行该合同。

可见，如果法定代表人在公司成立前签订的合同是为了公司的设立行为，合同内容与成立后的公司业务相关，并且公司成立后也接受了该合同的权利义务继续履行，那么在此种条件下，该合同对公司有效。本案中，某体育发展公

司的经营范围包括健身休闲活动、体育运动项目经营(不含高危险性体育项目)等,与合同内容直接密切相关,钉钉打卡记录截图显示的部门和打卡地点均为某体育发展公司,可见该公司已经参与了案涉健身房的运营,合同对某体育发展公司产生了效力,该公司转变为了挂靠方,且具备用工主体资格,而法定代表人王某在职权范围内代表公司所作出的行为,其法律后果直接归属于公司。

2. 用人单位依法制定的各项劳动规章制度适用于劳动者,劳动者受用人单位的劳动管理,从事用人单位安排的有报酬的劳动。即用工行为具有人格从属性与经济从属性。人格从属性指的是劳动者在用人单位的指挥和监督下工作,用人单位对劳动者的工作时间、地点、内容和方式等有决定权。经济从属性指的是劳动者为用人单位提供劳动并获得报酬,劳动者的经济来源依赖于用人单位支付的工资。本案中,董某需要遵守王某自己制定或基于与周某之间的合作关系由周某制定的各项规章制度,并由王某规律性地向其支付工资,可见,董某接受某体育发展公司的各项规章制度管理,从事该公司安排的有报酬的劳动,符合构成劳动关系的条件。

3. 劳动者提供的劳动是用人单位业务的组成部分。即用工行为具有组织从属性。组织从属性指的是劳动者的工作是用人单位业务不可分割的一部分,劳动者的工作成果归用人单位所有,并且劳动者参与用人单位的生产或服务过程。本案中,董某由王某授权周某进行招聘,在案涉健身房担任私教经理,其提供的劳动是某体育发展公司业务的组成部分,体现了组织从属性。

通过以上分析可知,某体育发展公司自注册成立成为适格主体之日起,与董某之间的关系即具备了劳动关系的实质特征。根据《中华人民共和国劳动合同法》第八十二条第一款规定:“用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的,应当向劳动者每月支付二倍的工资。”因此,某体育发展公司于2021年10月9日注册成立后,未在一个月内在董某订立劳动合同,应支付自2021年11月9日至2021年12月31日双方实际解除劳动关系期间未签订劳动合同的二倍工资差额。在劳动关系建立之前,董某与王某之间属于劳务关系,2021年9月28日至2021年10月8日的劳务费可另案向王某

或某体育发展公司主张。

从根本上来说,建立劳动关系需要用人单位与劳动者之间具有合意,即双方就建立劳动关系达成一致的意思表示,对工作内容、工作条件、劳动报酬、工作时间、休息休假、社会保险等劳动条件达成共识,而合意通常通过签订书面劳动合同来体现,合同中明确双方的权利和义务。而在没有签订书面劳动合同的情况下,某些在认定劳动关系时可供参照的凭证,反而容易成为判断的迷惑项。如工作地点、社保缴纳单位等一般应与用人单位信息一致,但在劳动者没有建立劳动关系意向的情况下,仅凭在某公司的工商注册地提供劳动不足以认定与该公司存在劳动关系,由其他公司缴纳社保也不影响真实劳动关系的认定。本案中,董某表示并不知晓某体育文化中心情况,且现有证据不足以证明王某系代某体育文化中心发放工资、依据某体育文化中心制定的各项劳动规章制度管理员工并明确告知董某,某体育文化中心为案涉健身房提供营业执照、卫生证和高危证等证件是基于其与王某之间的合作协议所约定的合同义务,无法体现其具有与董某建立劳动关系的意愿,因此仅凭工作地点等信息,难以认定双方具有建立劳动关系的合意。

本案明确了未签订书面劳动合同情况下,挂靠经营模式中由挂靠方直接招聘、管理并支付工资的劳动者通常与挂靠方形成实际的劳动关系,并具体阐明了判断实际用工主体的方法,有助于统一司法实践中的裁判标准,充分保护劳动者的合法权益;同时也对用人单位和劳动者起到了警示和教育作用,增强了二者法律意识,促使双方更加重视劳动合同的签订和履行,推动用人单位更加规范用工,构建规范和谐的用工环境。

编写人:北京市丰台区人民法院 商丽颖

超过仲裁时效后义务人同意履行，诉讼时效重新计算

——廖某诉某塑料机械厂劳动争议案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

浙江省台州市中级人民法院(2023)浙10民终406号民事判决书

2. 案由：劳动争议

3. 当事人

原告(被上诉人): 廖某

被告(上诉人): 某塑料机械厂

【基本案情】

原告廖某原系被告某塑料机械厂的员工，双方未签订书面劳动合同。后廖某于2020年4月26日离职，双方劳动关系终止。双方约定2019年至2020年间的薪资由月工资8000元、出差补贴、年底奖金及机器提成组成。某塑料机械厂法定代表人林某甲分别于2020年2月14日、3月27日通过微信转账及同年4月22日通过案外人林某乙(系林某甲女儿)银行账户向廖某转账10000元、10000元、20000元。

廖某诉至法院前，于2022年4月28日向黄岩劳动仲裁委申请劳动仲裁，该委以申请已超过一年仲裁时效为由驳回了廖某的所有仲裁请求。廖某不服该仲裁裁决，遂诉至法院。

另查明，2021年8月2日，廖某与林某甲的微信聊天记录中，廖某称：“2019年工资80600元，2020年1月工资8000元，加出差费，3月13000元，

长沙出差6天900元，4月13000元，厦门出差17天2550元，住宿车费我也忘记是多少了，两台旧机你答应的提成是20000元”，“以前在你家里谈好一年给我15万~18万元，我每月拿8000元，拿12个月也只有9万元，按最低15万元你也要给我6万元啊”等。林某甲称：“你把账单列出来，合理的我会给”，“我们该怎么算就怎么算，不会因为别的原因卡你工资”以及“这两台，第一台你出了，给你1万元”，“年底都是4万元”“2020年这二个月，有你出差补助，也有你请假没有上班，总共按实际工资算，共26000元”等。

再查明，廖某仲裁请求中的2019年11月、12月工资及出差补贴20600元，某塑料机械厂已支付，廖某亦予以确认。

【案件焦点】

双方间的微信聊天记录能否认定某塑料机械厂同意履行案涉款项以及同意履行的款项金额。

【法院裁判要旨】

浙江省台州市黄岩区人民法院经审理认为：双方确定于2020年4月26日终止劳动关系，廖某于2022年4月28日提起劳动争议仲裁时已超过一年的申请期间，且未提供时效中止、中断的相关证据，应认定廖某的诉请已超过仲裁时效。本案的争执焦点为双方间的微信聊天记录能否认定某塑料机械厂同意履行案涉款项以及同意履行的款项金额。某塑料机械厂法定代表人林某甲在仲裁时效届满后与廖某的微信聊天记录能够证明林某甲系作为某塑料机械厂法定代表人履行职务行为且同意向廖某履行尚未支付的2019年年底奖金40000元，2020年工资、出差补贴等26000元及机器提成10000元，共计76000元款项的事实。

浙江省台州市黄岩区人民法院根据《中华人民共和国劳动法》第五十条，《中华人民共和国劳动合同法》第七条，《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》第二十七条，《最高人民法院关于审理民事案件适用诉讼时效制度若干问题的规定》第十九条和《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条之规定，判

决如下:

- 一、某塑料机械厂于判决生效之日起十日内支付廖某36000元;
- 二、驳回廖某的其他诉讼请求。

某塑料机械厂不服一审判决,提起上诉,浙江省台州市中级人民法院经审理认为:本案二审的争议焦点为:一是一审审理程序是否合法;二是某塑料机械厂是否应向廖某支付工资款项。

关于争议焦点一,本案黄岩劳动仲裁委作出的仲裁裁决为终局裁决。劳动者对终局裁决不服的,可以自收到仲裁裁决书之日起十五日内向人民法院提起诉讼。《最高人民法院关于审理劳动争议案件适用法律问题的解释(一)》第十六条规定,劳动争议仲裁机构作出仲裁裁决后,当事人对裁决中的部分事项不服,依法提起诉讼的,劳动争议仲裁裁决不发生法律效力。故,一审法院就仲裁时效以及双方争议的实体问题进行处理,符合劳动争议相关法律规定。

关于争议焦点二,根据《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》第二十七条第四款,劳动关系存续期间因拖欠劳动报酬发生争议的,劳动者申请仲裁不受本条第一款规定的仲裁时效期间的限制;但是,劳动关系终止的,应当自劳动关系终止之日起一年内提出。本案中,双方的劳动关系于2020年4月26日终止。在双方劳动关系终止一年后,某塑料机械厂的法定代表人林某甲于2021年8月2日通过微信向廖某表示同意履行尚未支付的2019年年底奖金40000元,2020年工资、出差补贴等26000元及机器提成10000元,共计76000元款项。某塑料机械厂的法定代表人林某甲在时效届满后同意向廖某支付工资报酬,故双方已经达成新的协议,本案诉讼时效应从2021年8月2日起重新计算。廖某通过申请劳动仲裁以及起诉等方式主张权利,均构成诉讼时效中断,故本案未过诉讼时效期间。某塑料机械厂主张廖某在向一审法院起诉时并无要求支付奖金,故奖金不在本案诉讼请求范围内。法院认为,该奖金已经包含在廖某起诉的工资总额内,故对某塑料机械厂的这一主张不予采纳。因双方在一审中同意对某塑料机械厂法定代表人林某甲及案外人林某乙转账给廖某的40000元在本案中进行抵扣,故一审法院判决某塑料机械厂需支付廖某36000

元，并无不当。

浙江省台州市中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项之规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

一、仲裁时效与诉讼时效的衔接问题

仲裁时效、诉讼时效同属于民事法律体系，目的在于督促当事人及时行使权利。法律意义上的时效是指法律规定的某种事实状态经过法定时间而产生一定法律后果的法律制度。它是民事法律关系产生、变更、消灭的根据。民法中的时效通常指诉讼时效，即民事权利受到侵害的权利人在法定的时效期间内不行使权利，当时效期间届满时，人民法院对权利人的权利不再进行保护的制度。与其他民事案件相比，劳动争议案件则是一种特殊的民事案件。因为我国对劳动争议案件的处理采取的是仲裁前置模式，即劳动仲裁是劳动争议诉讼的前置程序。而法律对于劳动仲裁则规定了仲裁时效。劳动仲裁时效是指劳动者在法定期间内不行使权利即丧失请求劳动争议仲裁机构依法保护其权利并同时承担相应的法律后果的法律制度。劳动争议案件属于一种特殊的民事案件，其依法适用劳动仲裁时效，但其在进入民事诉讼程序后应否再适用民事诉讼时效，也即两者的衔接问题，关键在于正确把握民事诉讼时效和劳动仲裁时效二者的关系。

《中华人民共和国民法典》第一百九十八条规定：“法律对仲裁时效有规定的，依照其规定；没有规定的，适用诉讼时效的规定。”《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》第二十七条规定，劳动争议申请仲裁的时效期间为一年。

《中华人民共和国民法典》第一百八十八条第一款规定：“向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。法律另有规定的，依照其规定。”根据“特别法优于一般法”的法律适用基本原则，劳动争议案件应当适用劳动法领域中的劳动仲裁时效，而不应再适用一般法的民事诉讼时效。这与劳动争议纠纷在处理程序上的“仲裁前置”在原理上是一致的。劳动争议案件不适用仲裁时

效，而直接适用诉讼时效的例外：劳动者以用人单位的工资欠条为证据直接提起诉讼，诉讼请求不涉及劳动关系其他争议的，视为拖欠劳动报酬争议，按照普通民事纠纷受理。

对于劳动争议案件而言，其应当适用劳动仲裁时效，而无须再适用诉讼时效。尽管劳动争议案件中的追索劳动报酬和经济补偿金等纠纷均属于债权请求权范畴，理论上讲也属于受诉讼时效限制的范围，但不能因此而对相关劳动争议案件直接适用诉讼时效，毕竟在劳动法作为特别法而有特别规定的情况下应当适用劳动仲裁时效，故劳动争议案件不存在仲裁和法院阶段分别适用不同时效规定的情形。司法实践中，对于劳动争议案件即使是在进入民事诉讼程序后，人民法院也应当就是否超过劳动仲裁时效进行审查，而不应审查是否超过诉讼时效，更不能以诉讼时效而否定劳动仲裁时效。

二、时效抗辩权的行使

时效抗辩权属于民事权利中的抗辩权范畴。以权利的作用为标准，民事权利还包括支配权、请求权和形成权。劳动人事争议仲裁中当事人提出仲裁申请就属于行使请求权的行为，即一方当事人请求对方当事人为特定行为的权利。仲裁案件中抗辩权因仲裁时效经过而发生，以当事人的请求权为客体，直接导致请求权的减损，即申请人依然可以提出仲裁申请，如果被申请人自愿履行相应义务的话，申请人也依然可以得到相应的权利，但是如果被申请人行使抗辩权，申请人则失去了“胜诉权”。

我国实行“一裁二审”劳动争议处理体制，即强制仲裁前置，因此劳动争议案件中行使时效抗辩权必须在仲裁阶段就提出。《最高人民法院第八次全国法院民事商事审判工作会议(民事部分)纪要》也有规定，当事人在仲裁阶段未提出超过仲裁申请期间的抗辩，劳动人事仲裁机构作出实体裁决后，当事人在诉讼阶段又以超过仲裁时效期间为由进行抗辩的，法院不予支持。根据《最高人民法院关于审理民事案件适用诉讼时效制度若干问题的规定》第二条规定，当事人未提出诉讼时效抗辩，人民法院不应对诉讼时效问题进行释明及主动适用诉讼时效的规定进行裁判。这里包含了两层含义，在仲裁程序中首先当

事人必须主动行使时效抗辩权，提出时效抗辩，其次当事人没有提出的话仲裁机构不得主动适用，即不能主动以超过仲裁时效为由对仲裁申请不予受理。

三、义务人同意履行的裁判规则

当事人也有权放弃自己的时效抗辩权，通过明确作出“同意履行义务”的表示或者自动履行义务，而不提出时效抗辩来抛弃时效利益。需注意的是：首先当事人仅承认负有义务，并不构成“同意履行义务”；另外，当事人履行义务以后，又提出时效抗辩，以超过仲裁时效、诉讼时效为由反悔的，不予支持。

根据《最高人民法院关于审理民事案件适用诉讼时效制度若干问题的规定》第十四条的规定，“义务人同意履行义务”的方式包括作出分期履行、部分履行、提供担保、请求延期履行、制定清偿债务计划等承诺或者行为。如果是义务人明确作出了履行的承诺或行为，比如出具延期履行申请，出具还款计划书，当然属于“义务人同意履行”的范畴，但是在实践中，往往会出现义务人承认债务存在，但未做出履行的承诺，或者虽同意履行，但是对履行的内容和时间没有明确答复，这种情况下对于“义务人同意履行”的认定，应判断以下三要件：（1）义务人仅对义务存在事实的承认不构成“义务人同意履行”，义务人必须有同意履行的意思表示；（2）“义务人同意履行”要求能从义务人行为或表述中推定出有愿意履行义务的意思表示，并不要求义务人明确债务具体数额和计划履行的时间；（3）放弃诉讼时效抗辩权应以债务人知道其享有诉讼时效利益为要件，义务人在诉讼时效期间届满的情形下仍明确同意履行该债务，应推定其知道诉讼时效期间届满的事实，但如果债权人在催讨债务时未向债务人告知借款的发生时间、借款期限、具体金额等合同要件，应认为债务人并不明知或者应当知道其享有诉讼时效利益。

编写人：浙江省台州市黄岩区人民法院 章赛红

二、劳动合同的订立

16

《 实习协议 》 内容符合劳动合同法法律特征，
应认定为劳动合同关系

——郭某诉某文化公司、某文化公司分公司劳动争议案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

吉林省高级人民法院(2023)吉民申3687号民事裁定书

2. 案由：劳动争议

3. 当事人

原告(上诉人、再审申请人):郭某

被告(上诉人、再审申请人):某文化公司

被告(上诉人、再审被申请人):某文化公司分公司

【基本案情】

郭某是某文化公司员工，实际工作地点在某文化公司分公司。2018年2月26日，某文化公司(甲方)与郭某(乙方)签订《实习协议》，约定实习期从2018年2月26日始至2020年6月30日终；实习期间每月3000元。同日，郭某填写了《员工档案信息登记表》，并签订了《培训协议》《竞业限制协议》

《保密协议》。在此期间，郭某正常进行考勤，某文化公司未给郭某交纳社会保险费用。实习协议期满后，某文化公司未与郭某签订书面劳动合同，但自2020年7月为郭某依法缴纳了社保费用，直至2022年3月26日郭某离职。诉讼期间，郭某出示了非全日制研究生毕业证。

【案件焦点】

实习协议签订的时间是否应认定为双方建立劳动关系的时间。

【法院裁判要旨】

吉林省吉林市昌邑区人民法院经审理认为：关于超过法定试用期期间的赔偿金问题。郭某于2018年2月26日到某文化公司工作并与该公司签订实习协议至2020年6月30日。该协议内容符合试用期合同特征，因此属于试用合同。郭某工作至2022年3月26日，该合同约定的试用期不得超过6个月，对超期工资，应以郭某试用期满月工资为标准，按已经履行的超过法定试用期的期间向其支付赔偿金。郭某在约定试用期满后，某文化公司未与之签订书面劳动合同，工资无明确约定，故按上述期满之时实发工资标准确定赔偿基数计算，即194252.52元(8829.66元/月×22个月)。

吉林省吉林市昌邑区人民法院依照《中华人民共和国劳动合同法》第十九条第一款、第八十三条等规定，判决如下：

一、某文化公司于判决生效之日起三日内给付郭某超过法定试用期赔偿金194252.52元；

.....

十一、驳回郭某的其他诉讼请求。

郭某、某文化公司、某文化公司分公司均不服一审判决，提出上诉。吉林省吉林市中级人民法院经审理认为：第一，关于郭某与某文化公司签订的《实习协议》的性质。实习协议是指在校学生通过参加实习单位实际工作进行实践学习，明确双方权利义务的协议。实习阶段的主要目的是实践学习，供双方加深了解的机会，并不代表双方未来会建立劳动关系。郭某与某文化公司签订的

《实习协议》，包括单位的名称、住所和法定代表人；郭某的姓名、住址和居民身份证号；合同期限；工作内容和工作地点；工作时间和休息休假；劳动报酬；劳动保护、劳动条件；双方权利义务、协议解除、违约责任事项。上述事项系《中华人民共和国劳动合同法》第十七条规定的劳动合同应当具备的条款。同日，郭某填写了《员工档案信息登记表》，并签订了《培训协议》《竞业限制协议》《保密协议》，根据上述三份协议内容可见，签订的前提为双方之间存在劳动关系。双方签订的协议虽名为《实习协议》，但明显与实习协议的实质不同，《实习协议》内容符合劳动合同性质，故应认定《实习协议》系双方建立劳动关系的意思表示，《实习协议》约定的期限为劳动合同期限。第二，关于某文化公司应否支付郭某超过法定试用期期间赔偿金的问题。劳动合同除《中华人民共和国劳动合同法》第十七条规定的必备条款外，用人单位与劳动者还可以约定试用期、培训、保守秘密、补充保险和福利待遇等其他事项。试用期并非劳动合同的必备条款。本案中，郭某与某文化公司签订的《实习协议》中并无关于试用期的约定，故郭某主张超过法定试用期期间赔偿金无事实依据，一审判决某文化公司支付超过法定试用期期间赔偿金错误，予以纠正。

吉林省吉林市中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项规定，判决如下：

.....

二、撤销吉林省吉林市昌邑区人民法院(2022)吉0202民初888号民事判决第一项、第五项、第八项、第十一项；

.....

四、驳回郭某的其他诉讼请求。

郭某、某文化公司均不服二审判决，提出再审申请。吉林省高级人民法院同意二审法院裁判意见，认为郭某提供的考勤记录证明其基本处于正常工作状态，某文化公司未能提供相反证据证明郭某有长时间请假回学校学习的相关事实，主张仅在郭某无课或周末空闲状态下为郭某安排工作明显与事实不符，且郭某在诉讼期间提供了本人非全日制研究生毕业证。

吉林省高级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百一十五条第一款,《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第三百九十三条第二款规定,裁定如下:

驳回某文化公司、郭某的再审申请。

【法官后语】

一、关于《实习协议》的性质问题

这是本案的焦点问题。实习与试用有着本质区别,实习一般是指学生把学到的理论知识运用到实际工作去应用和检验,以锻炼工作能力,目的是提高自身的综合素质和职业技能,为就业做好准备;试用是指已毕业的劳动者在正式入职或转正前,与用人单位之间,为了相互了解、选择和匹配彼此的预期和需求,双方之间存在劳动关系。区分实习协议与劳动合同应重点从以下几个方面综合判断:一是目的和性质方面。实习协议主要用于规范学生在企业或机构实习期间的权利与义务,通常有带队老师或指导教师,主要是为了让学生获得工作经验,同时为企业提供人力资源;劳动合同是用于确立劳动者与用人单位之间的劳动关系,明确双方的权利义务、合同解除、违约责任等。二是合同期限方面。实习协议通常有明确的开始和结束日期,期限较短,一般与学校的学期或学年相匹配;劳动合同可以是固定期限或无固定期限,根据合同条款和双方的协商确定。三是工作内容和职责方面。实习协议的工作内容通常与实习生的学习领域相关,职责较为有限、单一,侧重于学习和培训;劳动合同的工作内容和职责较为具体、独立,劳动者需要承担完整的工作职责,与其他同岗劳动者工作职责、工作内容、工作量基本相当。四是薪酬福利待遇方面。实习协议一般约定实习生获得较低的津贴,福利待遇基本没有或很少;劳动合同一般约定劳动者应享有的工资标准、工作时间、休息休假、社会保险、竞业限制等方面的权益。

本案中的《实习协议》除双方当事人基本信息外,还包括工作时间和休息休假、劳动报酬、劳动保护、劳动条件及双方权利义务、协议解除、违约责任等事项,明显与实习协议性质不同,更具劳动合同的法律特征。后续签订的

《培训协议》《竞业限制协议》《保密协议》对相关期限的约定均是以双方之间存在劳动关系为前提。且《实习协议》所涉内容与郭某的研究生专业亦无关联性，故认定《实习协议》系双方建立劳动关系的意思表示，实习协议约定的实习期间为劳动合同期间。

二、关于在读研究生建立劳动关系的问题

某文化公司主张郭某2017年9月1日至2020年6月为在读研究生，无法建立劳动关系，郭某工作行为应属勤工俭学。郭某在诉讼期间提供了非全日制研究生毕业证，且考勤记录载明，郭某基本处于正常工作状态，某文化公司未能提供相反证据证明郭某有长时间请假回学校学习的相关事实。我国研究生根据学习方式分为全日制研究生和非全日制研究生，后者档案、户口的管理主体均非学校，双方建立劳动关系亦非劳动合同法所禁止的情形，某文化公司在郭某正常出勤工作的前提下，径行推定其为在读全日制研究生并主张无法建立劳动关系，缺乏事实依据，不能支持。

本案对于非全日制研究生能否与用人单位建立劳动关系的认定具有典型意义，能够进一步明确实习期和劳动合同期限的判断标准。一般情况下，在校学生不能与用人单位建立劳动关系。但我国研究生分为全日制研究生和非全日制研究生，前者档案、户口以及日常生活管理的主体均为学校，其从事兼职劳动在本质上应属勤工俭学性质。而后者则不然，其完全具备劳动法意义上的劳动者主体资格。本案严格把握二者的区别，有利于充分保护非全日制研究生的合法权益，对于非全日制研究生在读期间，也能够建立劳动关系予以确认。同时也督促相关用人主体要依法履行己方法定义务，规范公司用工，对于推动逐步构建和谐劳动关系具有积极意义。

编写人：吉林省高级人民法院 温淑敏

事业单位聘用合同的订立规则

——周某诉某小学人事争议案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

北京市第三中级人民法院(2023)京03民终11835号民事判决书

2. 案由: 人事争议

3. 当事人

原告(被上诉人): 周某

被告(上诉人): 某小学

【基本案情】

周某于1995年参加工作,于2002年2月作为事业编教师从其他学校调入某小学,担任音乐教师。周某与某小学签订期限为2006年7月9日至2008年7月8日的《北京市事业单位聘用合同书》;2008年6月26日续订期限至2010年7月8日;2010年6月20日续订期限至2012年7月8日;2012年3月22日续订期限至2014年7月8日;2014年3月18日续订期限至2016年7月8日;2016年4月8日续订期限至2019年7月8日;2019年4月9日续订期限至2020年7月31日。2015年4月9日,周某与某小学签订《聘用合同变更书》,内容为:“依据2014年7月1日起试行的《事业单位人事管理条例》,对双方之间签订的聘用合同书作如下变更:将聘用合同书中的第二十四条:在续订聘用合同时,乙方在甲方工作已满25年或者连续工龄已满且年龄距国家规定的退休年龄不足10年的,如果乙方提出订立聘用至退休的合同的,甲方应当与其订

立聘用至退休的合同。变更为：乙方在甲方单位连续工作满10年且距法定退休年龄不足10年，如乙方提出订立聘用至退休的合同的，甲方应当与其订立聘用至退休的合同。上述变更的内容自2014年7月1日起执行。聘用合同书未变更部分内容，双方仍继续遵照聘用合同书的约定执行。”

2020年6月30日，某小学向周某通过微信送达《终止聘用合同的通知》，内容为：“周某同志：依据《北京市事业单位聘用合同制试行办法》的规定，我单位与你签订的聘用合同，至2020年7月31日止，期限届满，不再续签。根据《北京市事业单位聘用合同制试行办法》有关规定，特此通知如下：请在2020年7月31日前到人事办公室办理档案转移手续。逾期不办者，依据《北京市事业单位聘用合同制试行办法》的有关规定，单位将向你户籍所在地区县失业保险经办机构移交本人的人事档案。”就终止聘用合同的依据，某小学提交了《某小学与周某终止合同的会议记录》《关于终止聘用合同的决议》。周某对证据的真实性不予认可。

【案件焦点】

周某与某小学是否构成人事关系。

【法院裁判要旨】

北京市朝阳区人民法院经审理认为：《事业单位人事管理条例》第十二条规定：“事业单位与工作人员订立的聘用合同，期限一般不低于3年。”本案中，周某与某小学于2019年4月9日续订期限至2020年7月31日的聘用合同书，期限不满三年。某小学与周某此前签订的聘用合同亦存在多次期限不满三年的情况。某小学未提交证据证明周某存在可签订期限不满三年聘用合同的情况，故某小学与周某签订期限不满三年的聘用合同，不符合规定。

《事业单位人事管理条例》第十四条规定：“事业单位工作人员在本单位连续工作满10年且距法定退休年龄不足10年，提出订立聘用至退休的合同的，事业单位应当与其订立聘用至退休的合同。”本案中，周某于2002年2月作为事业编教师调入某小学，于2031年6月25日达到退休年龄。某小学于2020年

6月30日向周某送达《终止聘用合同的通知》，决定于2020年7月31日与周某终止聘用关系。某小学与周某于2019年4月9日续订的劳动合同期限为2019年7月9日至2020年7月31日，期限不满三年，导致周某不符合《事业单位人事管理条例》第十四条规定的订立聘用合同至退休之日的条件，故法院对周某关于要求与某小学续订聘用合同至退休的诉讼请求予以支持。

北京市朝阳区人民法院依照《事业单位人事管理条例》第十二条、第十四条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条之规定，判决如下：

- 一、某小学于判决生效后七日内与周某订立期限至退休之日的聘用合同；
- 二、驳回周某的其他诉讼请求。

某小学不服一审判决，提起上诉。北京市第三中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

一、人事争议的受理范围

人事关系区别于劳动关系，是指事业单位、社会团体依据人事政策文件规定而建立起来的关于劳动权利义务关系以及非劳动权利义务关系的社会关系。首先，需要明确人事争议纠纷案件的受理范围。《人事争议处理规定》第二条规定：“本规定适用于下列人事争议：……（二）事业单位与工作人员之间因解除人事关系、履行聘用合同发生的争议……”《最高人民法院关于人民法院审理事业单位人事争议案件若干问题的规定》第一条规定：“事业单位与其工作人员之间因辞职、辞退及履行聘用合同所发生的争议，适用《中华人民共和国劳动法》的规定处理。”第三条规定：“本规定所称人事争议是指事业单位与其工作人员之间因辞职、辞退及履行聘用合同所发生的争议。”本案系周某与某小学之间因辞退引发的争议，故本案属于人民法院审理劳动人事争议案件的受理范围。

二、人事聘用合同的订立规则

聘用合同是指聘用单位与受聘人员建立聘用关系，明确双方权利和义务的协议。

1. 事业单位人员也需要订立聘用合同。通过签订合同，事业单位和工作人员可以更加明确各自的权利和义务，使得管理更加规范化。由于聘用合同具有劳动合同及行政合同的双重属性，区别于劳动合同。聘用合同的订立要符合以下特殊规则：《事业单位人事管理条例》第十二条规定：“事业单位与工作人员订立的聘用合同，期限一般不低于3年。”第十三条规定：“初次就业的工作人员与事业单位订立的聘用合同期限3年以上的，试用期为12个月。”第十四条规定：“事业单位工作人员在本单位连续工作满10年且距法定退休年龄不足10年，提出订立聘用至退休的合同的，事业单位应当与其订立聘用至退休的合同。”

2. 事业单位工作人员享有相对稳定的职业地位和收入保障，但是并非不能被解除合同。《事业单位人事管理条例》第十五条规定：“事业单位工作人员连续旷工超过15个工作日，或者1年内累计旷工超过30个工作日的，事业单位可以解除聘用合同。”第十六条规定：“事业单位工作人员年度考核不合格且不同意调整工作岗位，或者连续两年年度考核不合格的，事业单位提前30日书面通知，可以解除聘用合同。”第十七条规定：“事业单位工作人员提前30日书面通知事业单位，可以解除聘用合同。但是，双方对解除聘用合同另有约定的除外。”第十八条规定：“事业单位工作人员受到开除处分的，解除聘用合同。”第十九条规定：“自聘用合同依法解除、终止之日起，事业单位与被解除、终止聘用合同人员的人事关系终止。”

3. 劳动争议与人事争议的区别。审判实践中，事业单位将员工辞退的理由往往多种多样，在保障事业单位相对稳定性的用工关系前提下，如何规范用工需要注意。通过《事业单位人事管理条例》关于解除的规定可见，事业单位可单方解除聘用合同的事由均是法定的，排除了事业单位解除聘用合同的任意性，体现了公权力对双方权利义务的深度介入，有利于维护社会公共服务组织队伍的稳定性，这明显区别于劳动合同法中的劳动双方解除劳动合同。

编写人：北京市朝阳区人民法院 杨晓斌

三、劳动合同的履行和变更

18

出差在途时间占用休息日或法定节假日的加班工资认定

——郑某诉某科技公司劳动争议案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

北京市第三中级人民法院(2022)京03民终9408号民事判决书

2. 案由：劳动争议

3. 当事人

原告(上诉人):郑某

被告(被上诉人):某科技公司

【基本案情】

郑某于2019年12月4日入职某科技公司,担任法务岗位,双方签订了书面劳动合同,约定工作地点为北京,试用期6个月,月工资16000元。郑某正常出勤至2020年5月9日,后双方因劳动关系解除产生争议成诉。郑某起诉要求某科技公司支付2020年3月7日(周六)的休息日加班工资、撤销《解除通知书》、继续履行劳动关系等。关于2020年3月7日(周六)的加班事宜,双方当事人均认可在2020年3月8日(周日),郑某作为某科技公司的代理人

在广州参加另案庭审，郑某主张2020年3月7日（周六）系自北京到广州的出差在途时间，该时间应算作加班时间，某科技公司应支付加班费。

【案件焦点】

某科技公司是否应支付郑某2020年3月7日的休息日加班工资。

【法院裁判要旨】

北京市朝阳区人民法院经审理认为：该日系其出差在途期间，不属于加班，故对其此项诉讼请求，法院不予支持。

北京市朝阳区人民法院依照《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》第六条之规定，判决如下：

驳回郑某的全部诉讼请求。

郑某不服一审判决，提起上诉。北京市第三中级人民法院经审理认为：关于在途日加班费问题，判断在途日是否应当支付加班费应当结合在途时间发生原因、休息日在途必要性、在途距离及对劳动者休息的影响等因素综合予以考虑，本案中郑某的惯常工作生活地点在北京，因代表公司周日在广州仲裁开庭故而周六出差，应当认为郑某在周六从北京前往广州具有必要性，且北京与广州距离较远，在途时间相对较长，且郑某第二天又将面临开庭，应当认为郑某在该休息日与正常工作期间休息日休息效果差异较大，基于对劳动者休息权的保护，某科技公司应当支付2020年3月7日的加班费用。

北京市第三中级人民法院依照《中华人民共和国合同法》第三十九条、第四十八条，《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》第六条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第二项规定，判决如下：

- 一、撤销北京市朝阳区人民法院(2021)京0105民初30626号民事判决；
- 二、某科技公司于本判决生效之日起七日内支付郑某2020年3月7日的休息日加班工资1177元及2020年5月10日出差交通费用656元；

三、驳回郑某的其他诉讼请求。

【法官后语】

随着交通的便捷化，商业网络也逐渐贯通四方，劳动者因公司业务而出差的行为也越来越多，随之而衍生的问题是，若出差在途时间占用了休息日或法定节假日，用人单位是否应支付加班费。

一、在途时间加班费认定的实践争议

此问题在实践中存在争议。不支持休息日或法定节假日出差在途时间加班费的案例往往认为出差在途时间劳动者并未提供实质劳动，且途中亦可休息。例如，上海市第一中级人民法院(2019)沪01民终1507号民事判决^①认为，出差在途时间属于为工作而进行准备的时间，劳动者于该期间并不处于向单位提供劳动之状态。又如，广州市中级人民法院(2017)粤01民终7473号民事判决认为，加班需要以完成特定、具体的工作内容为支撑，而劳动者出差在途时间属于单纯移动时间，与具体完成实际工作任务的加班时间存在差异。再如，沈阳市浑南区人民法院(2018)辽0112民初6678号民事判决认为，在出差途中，劳动者依然可以休息。

支持休息日或法定节假日出差在途时间加班费的案例则侧重认为，出差在途时间与工作有关，且劳动者额外付出了时间。例如，北京市第二中级人民法院(2020)京02民终9518号民事判决认为，劳动者客观上存在频繁出差的情况，且多次出差在途时间均发生在法定工作时间以外亦耗时较长，已经超出了劳动者在工作时间之外为完成工作任务能够或者应当额外付出的合理的时间期间。又如，天津市滨海新区人民法院在(2015)滨功民初字第504号民事判决中认为，虽劳动者主张加班时间属于在途时间，但仍与工作有关。再如，北京市第一中级人民法院(2019)京01民终6867号民事判决认为，出差与日常上下班路程的性质不同，出差系劳动者经用人单位安排为完成工作付出的时间，如该时间超出了劳动者执行的工时标准，一般应属于加班。

^①载中国裁判文书网，<https://wenshu.court.gov.cn>，2025年4月3日访问。以下同一出处案例不再进行特别说明。

二、出差在途时间属于加班的根源探究

根据《中华人民共和国劳动法》第三条的规定，劳动者享有休息休假的权利。虽然有观点认为，劳动者出差在途时也可以休息，但是，并非所有“未处于工作之中”的状态均属于法律所规定的“休息”，“休息权”的内涵和本质应当更加丰富。

一方面，“休息权”不仅包括“消极休息”，还包括“积极休息”。“消极休息”是指劳动者在耗费一定的体力或脑力后，通过脱离工作状态而静养的方式恢复生理机能和精神状况。“积极休息”是指劳动者在耗费一定的体力或脑力后，通过参与家庭活动、休闲娱乐等积极的方式获得心理慰藉、情感支撑和情绪舒缓。相较于“消极休息”，“积极休息”能够更大限度地提升劳动者的工作状态和生产效率。出差在途时间虽然可以让劳动者进行一定程度上的“消极休息”，却阻断了劳动者通过参与家庭活动、社会活动进行“积极休息”的可能性。

另一方面，“休息权”应当具有“自由属性”。劳动者在休息时间之内享有充分的休息权，其有权选择、决定自己在何地点采取何种休息方式。而出差在途时间在一定程度上限制了劳动者的休息选择，劳动者只能在高铁或飞机座位上采用“消极休息”方式，导致劳动者无法享有完整的“休息权”。

回顾出差在途时间加班费的实践争议，不支持加班费的理由在保护劳动者“休息权”的角度下略显牵强。首先，出差途中劳动者的“休息”与劳动者正常的休息相比在性质和效果上均存在差异，劳动者休息权缺乏自由性和完整性。其次，劳动者出差系完成工作内容的一种形式，出差包含劳动者自出发地到达目的地，完成工作任务后又回到出发地的整个过程，不宜将出差途中与出差到达目的地后的工作内容割裂审视，而应将其视为一体，劳动者的整个出差过程为用人单位创造了价值，则出差在途时间便不属于“无经济效益产生的时间”。

因此，休息日或法定”节假日的出差在途时间占用了劳动者的休息时间，侵犯了劳动者的休息权，用人单位应当支付加班费。

三、认定在途时间加班费的考虑要素

在审理实践中，还需要综合考虑如下要素，对加班费予以认定。

第一，在途时间发生原因。着重考虑是否系因工作原因导致劳动者不得不出差，在途时间占用休息日或法定节假日是否具有必要性。如本案中，郑某作为法务担任公司的代理人，应仲裁庭要求线下到外地参加庭审，庭审时间亦被定在周日，其周六出发系因工作原因，周六被在途时间占用具有必要性，某科技公司应支付在途时间的加班费。

第二，在途时间对休息权的影响程度。主要考虑出差的距离及在途时间的长短，如本案中，郑某从北京到广州出差，距离较远，其需花费大量时间在途，对其休息权的影响程度较大，认定周六属于加班时间，具有合理性。

第三，岗位特点。对于销售等具有灵活性、工作时间长短与收入大幅相关的岗位，其出差在途时间是否认定为加班时间，应审慎处理。本案郑某的工作岗位为法务，不属于可以灵活掌握工作时间的岗位。

综合上述因素，因公出差的在途时间占用了郑某的休息日，影响了郑某“休息权”的“自由性”和“完整性”，某科技公司应当支付其加班费。

编写人：北京市第三中级人民法院 郑吉喆 田艳飞

公司因出差给予的补助和调休是否可以代替加班费

——王某诉某机械公司劳动争议案

【案件基本信息】

1. 判决书字号

北京市第一中级人民法院(2023)京01民终35号民事判决书

2. 案由：劳动争议

3. 当事人

原告(上诉人):王某

被告(上诉人):某机械公司

【基本案情】

王某于2012年2月1日入职某机械公司,双方签订了劳动合同,合同约定王某担任制造部调试岗位,执行标准工时制度,每天工作时间不超过8个小时,每周不超过40个小时,每周休息日为星期六、星期日,工作地点位于北京。2018年4月,王某基本工资为6200元;自2014年9月至2022年1月,某机械公司调整王某工资结构,基本工资变更为4000元,除基本工资外,每月固定发放绩效工资、保密工资、工龄工资。

王某提交考勤表照片证明其加班时长。某机械公司制定的《出差管理制度》规定:假日出差,出差时间含4个休息日回来安排1天休息,含8个休息日回来后安排2天休息,以上以此类推,回来后酌情安排倒休;节假日出差,按节假日加班处理。差旅费分为交通费、住宿费、伙食补助费及杂费(市内交通及交际费等),员工在周六、周日、国家法定节假日、国家和公司调休日出差,公司在支付相应出差期间伙食补助的同时,另行支付出差补助,标准为每人每天100元。双方均认可王某出差后已休息38天。

某机械公司提交5年的《工资标准确认表》,上面均写明“以(新)基本工资为基础计算加班费”,每份《工资标准确认表》上均有王某的签名,王某称签字时并未看到“以基本工资为基础计算加班费”。庭审中,某机械公司称其以4000元为计算基数,已足额发放王某出差期间的加班工资。

王某向北京市昌平区劳动人事争议仲裁委员会提出仲裁申请,要求某机械公司支付延时加班工资、休息日加班工资及法定节假日加班工资。2022年6月29日,该委作出裁决书,驳回王某的仲裁请求。王某不服仲裁裁决,于法定期限内诉至北京市昌平区人民法院。

二审期间,某机械公司提交新证据《假日出差补助发放凭证及统计表》和《离职结算单》,《假日出差补助发放凭证及统计表》证明2018年4月1日至

2022年1月31日，王某按照某机械公司报销流程提交出差报销单，公司核对无误后按照100元一天标准向王某实际支付202天的假日出差补助共计20200元，其公司对出差的补偿包括调休和现金补偿两部分。《离职结算单》证明王某在2018年4月至2022年1月共享有38天差后休，在实际调休37天后，王某离职仍有1天差后休未休，某机械公司将该日(第38日)差后休按照双方约定的4000元为基数折合为休息日加班费向其支付。

【案件焦点】

1. 某机械公司是否应支付王某出差期间的各项加班工资；2. 公司因出差给予的补助和调休是否可以代替加班费。

【法院裁判要旨】

北京市昌平区人民法院经审理认为：第一，关于王某主张出差期间的延时加班工资，因王某未就其本人在出差期间工作日延时加班的具体时长提供充分证据证明，故法院不予支持。第二，关于王某主张的出差期间休息日加班工资，因现行法律未禁止企业根据实际情况灵活安排周休息日，某机械公司通过补休的方式实际上保障了王某出差期间的周休息日，王某亦实际进行了补休，故某机械公司并未侵犯王某的休息权。因二审中出现新证据，故法院认定某机械公司实际安排王某补休天数为37天，在计算休息日加班费时长中予以折抵。第三，关于王某主张的出差期间节假日加班工资，王某提交的考勤表照片能够证明其节假日加班，故法院予以支持。

对于加班工资计算基数，某机械公司主张以双方合同约定的4000元为加班费计算基数，但该工资标准低于王某实际工资，应视为双方实际变更了合同约定的工资标准，故法院对某机械公司主张的计算基数不予采信。某机械公司以4000元标准计算第38日休息日加班工资缺乏依据，应予以补足。经核算，某机械公司应支付王某延时加班工资差额17888.83元、休息日加班工资差额76769.85元、节假日加班工资差额1944.83元。

北京市昌平区人民法院依照《中华人民共和国劳动合同法》第三十一条，

《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条之规定，判决如下：

一、某机械公司于判决生效后十日内支付王某2018年4月1日至2022年1月31日延时加班工资差额17888.83元、休息日加班工资差额76350.11元、节假日加班工资差额1944.83元；

二、驳回王某的其他诉讼请求。

某机械公司与王某均不服一审判决，提出上诉。某机械公司在二审中提交了新证据即离职结算单。北京市第一中级人民法院经审理认为：某机械公司实际安排王某补休天数为37天，最终核算休息日加班工资差额为76769.85元。对其他金额认定同意一审法院裁判意见。

北京市第一中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第二项规定，判决如下：

一、撤销北京市昌平区人民法院(2022)京0114民初5951号民事判决第二项；

二、变更北京市昌平区人民法院(2022)京0114民初5951号民事判决第一项为：某机械公司于本判决生效后十日内支付王某2018年4月1日至2022年1月31日延时加班工资差额17888.83元、休息日加班工资差额76769.85元、节假日加班工资差额1944.83元；

三、驳回王某的其他诉讼请求。

【法官后语】

加班是指用人单位在正常工作时间以外安排劳动者进行工作，是基于用人单位根据生产经营需要对劳动者的工作时间进行额外安排而产生。加班的认定应同时满足两个条件：一是时间要件，工作日延长的时间、双休日或节假日；二是事实要件，从事单位安排的工作或为工作做准备。基于以上两个条件，因为加班是一种持续的工作状态，出差期间仅有打卡记录并不代表进行了正常工作，劳动者主张加班费的，应当就加班事实的存在承担举证责任。

部分用人单位在《员工手册》或《考勤管理制度》等文件中规定员工出差后可以调休，并且发放出差补助。该种情况下，用人单位能否以此抗辩而不予

发放加班费呢？

首先，调休是否可以代替加班费。因延时加班、休息日加班及节假日加班的工资计算标准不同，故针对通常情况而言，只有休息日的加班才可以安排调休的，延长时间的加班与法定节假日的加班，依然应当支付加班费。劳动者休息日加班天数多于用人单位规定的调休天数，用人单位应当补发调休天数折抵后的休息日加班工资。

其次，出差补助能否代替加班费。出差补助，是指用人单位基于劳动者的工作地点变化、日常生活被打乱而支付给劳动者的伙食补贴和其他补助，是一种对员工出差在外期间的额外劳动消耗和生活费额外支出的经济补偿，而且出差补助是出差期间每天均发放的。而加班费是劳动者在规定工作时间之外继续工作所获得的劳动报酬，包含劳动所得和休假损失补偿的成分。故，出差补助和加班费属于不同的项目和待遇，二者的功能截然不同，不能混同。

最后，加班费工资基数应如何计算。加班费的多少与工资基数有关。(1)如果劳动合同对加班工资基数已作出明确约定的，应按照双方的约定计算加班工资。(2)如果劳动合同明确约定工资数额，但没有约定加班工资基数的，应当以劳动合同约定的工资作为加班工资基数。如果劳动合同上工资项目分为基本工资、岗位工资、职务工资等，应以各项总和作为基数计发加班费。(3)如果劳动合同对劳动报酬没有约定，或者约定不明，引发劳动争议的，用人单位应与劳动者重新协商，协商不成的，可由用人单位与职工代表通过集体协商确定，协商结果应签订集体合同或工资协商协议。(4)如果集体合同、劳动合同均没有约定工资数额以及加班工资基数的，应当以劳动者本人实际工资收入作为加班工资基数。需要注意的是，如果劳动合同对工资基数作出明确约定，但是在劳动合同履行过程中用人单位调整劳动者薪资报酬结构后向劳动者发放工资数额增加，则视为双方实际变更了合同约定的工资发放标准，用人单位应该以新的工资标准为基数计算加班费。

编写人：北京市昌平区人民法院 李成环 周洁

网络在线形式“加班”的认定标准

—— 曹某诉某管理公司劳动争议案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

北京市第一中级人民法院(2023)京01民终2674号民事判决书

2. 案由：劳动争议

3. 当事人

原告(上诉人): 曹某

被告(被上诉人): 某管理公司

【基本案情】

曹某于2017年9月25日入职某管理公司任信息中心总监。2022年1月3日,曹某向某管理公司送达因未及时足额支付工资报酬而被迫解除劳动关系通知,双方劳动关系于当日解除。

曹某以要求某管理公司支付加班工资等向北京市昌平区劳动人事争议仲裁委员会提出仲裁申请,该委于2022年4月25日作出裁决,驳回了曹某关于加班工资的仲裁请求。曹某对该裁决不服,诉至北京市昌平区人民法院。

诉讼中,曹某主张其加班事实包括两部分:一是休息日居家线上参加的集团周例会;二是被派至某医院进行的行政总值班和信息技术运维的延时、休息日、法定节假日期间部分。就在线周例会加班事实,曹某提交微信群组聊天记录,显示某管理公司办公室主任发送集团周例会通知和线上会议邀请链接,其另提交其本人的线上会议账户截图,显示按照前述通知时间和会议号参会。上

述证据显示2020年8月2日至2021年12月4日,基本上每周周六或周日均召开周例会,例会开始时间较为固定,多为9:00或9:30,会议时长大多为1小时至2小时不等。微信群组中还发送周例会会议纪要,记载会议情况,载明的参会人包含曹某。就在线周例会加班事实,某管理公司主张,曹某系参加集团周例会,并非该公司会议;且曹某有可能参与一些网络技术上的事宜,但未实际参会;此外,该公司《考勤及休假管理制度》规定加班需进行加班申请及审批,曹某在明确知晓和同意的情形下,从未提交过任何加班申请。双方当事人均认可曹某与某管理公司存在劳动关系期间并未与集团公司存在双重劳动关系或劳务关系。

【案件焦点】

曹某线上参加集团周例会是否属于加班,某管理公司是否应向其支付加班工资。

【法院裁判要旨】

北京市昌平区人民法院经审理认为:劳动者主张加班费的,应当就加班事实的存在承担举证责任。曹某提交的电子证据无法核实微信聊天记录中对话人的身份,会议详情截图未显示有某管理公司相关信息,数据汇总表均为打印字样,某管理公司均不予认可,故曹某提交的证据不足以证明其加班情况,对其要求支付加班工资的诉讼请求,法院不予支持。

北京市昌平区人民法院依据《中华人民共和国劳动法》第四十五条、第五十条,《中华人民共和国劳动合同法》第四十六条、第四十七条及《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条之规定,判决如下:

一、某管理公司于本判决生效后十日内支付曹某2020年2月1日至2020年5月31日工资差额36000元;

二、某管理公司于本判决生效后十日内支付曹某2019年至2021年绩效工资120000元;

三、某管理公司于本判决生效后十日内支付曹某2019年9月25日至2021

年12月31日未休年休假工资14184.83元；

四、某管理公司于本判决生效后十日内支付曹某解除劳动关系经济补偿金158009.99元；

五、某管理公司于本判决生效后十日内支付曹某2022年1月1日工资差额67.73元；

六、驳回曹某的其他诉讼请求。

曹某不服一审判决，提出上诉。北京市第一中级人民法院经审理认为：就周末线上参加的集团周例会，某管理公司认可微信群组的真实性，亦认可该公司办公室主任在群组中发送周例会通知，曹某在上述群组中，且其提交了线上会议参会详情，显示曹某的线上会议账户于通知周例会的会议号按照相应时间参会，上述证据能够形成完整证据链，证明曹某实际参加了集团周例会。某管理公司主张曹某有可能参与一些网络技术上的事宜，未实际参会，但该解释不尽合理，不足以推翻曹某的证据。某管理公司另主张例会属于集团例会，参会不属于某管理公司安排的工作，但相应通知由该公司办公室主任发送，且该公司主张曹某与该公司存在劳动关系期间并未与集团公司存在双重劳动关系或劳务关系，故应认为曹某参加集团周例会系受某管理公司的安排，该公司应对此承担雇主责任。周末周例会虽为远程在线形式，但参会人员受用人单位安排，基于自身业务提供相应劳动，用人单位受领劳动成果，其性质应属于加班。与在线加班无关的加班认定在此不予赘述。

北京市第一中级人民法院依照《中华人民共和国劳动法》第四十四条、第五十条，《中华人民共和国劳动合同法》第四十六条、第四十七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第二项规定，判决如下：

一、维持北京市昌平区人民法院(2022)京0114民初7790号民事判决第一、二、三项；

二、撤销北京市昌平区人民法院(2022)京0114民初7790号民事判决第四、五、六项；

三、某管理公司于本判决生效后十日内支付曹某解除劳动关系经济补偿金

170280元;

四、某管理公司于本判决生效后十日内支付曹某2022年1月1日工资差额203元;

五、某管理公司于本判决生效后十日内支付曹某2021年3月1日至2021年12月31日的工资差额30000元;

六、某管理公司于本判决生效后十日内支付曹某2019年10月1日至2021年12月31日的休息日加班工资130258元、法定节假日加班工资74482元;

七、驳回曹某的其他诉讼请求。

【法官后语】

随着即时通信和远程办公软件的广泛应用,工作模式也越发灵活——用工管理可以通过在线信息的形式发出指令,完成工作内容也不再拘泥于用人单位提供的固定工作场所,通过网络在线形式提供劳动的情形日益普遍。与此同时,“工作的便捷”和“工作侵入生活的便捷”是同时发生的一体两面,劳动者越来越强烈地要求对远程在线提供的劳动支付法定劳动报酬,“隐形加班”成为热议词汇。劳动争议仲裁机构、人民法院就“加班”审查时应虚化工作场所的概念,不能仅因劳动者未在用人单位安排的工作场所工作而否定劳动者的加班事实。

远程通过网络在线形式提供劳动主要有两种模式:(1)网络通信设备系工作的平台和媒介,劳动者在固定工作场所之外依靠网络在线完成工作任务。如通过即时通信工具参加工作会议、销售商品、接受客户咨询等。(2)雇主发出工作指令后,劳动者通过网络通信设备交付工作成果,但实质性劳动过程并非在网络平台完成,而是在固定工作场所之外线下完成。例如,制作、修改文稿、设计方案、代码等,劳动者居家完成并通过在线形式远程交付。远程在线工作模式最初比较集中于互联网、科技型企业,但随着管理理念的发展和技术的成熟,各类行业和岗位都在不同程度地探索远程办公的可能性,如本案中,在线会议的工作方式几乎可以适用于全体劳动者,对固定工作场所局限性的突破不再具有明显的行业和岗位特征。

对于以上两种模式，认定是否构成加班的内在逻辑和审查标准存在共性，均应综合考量以下因素：

一是用人单位的安排。加班需经用人单位安排或同意，劳动者自主延长的工作时间通常不能被认定为加班。如果用人单位的规章制度规定了加班审批制度，劳动者加班的，应当按照规章制度进行审批，劳动者没有经过相应的审批程序而自愿加班，此时用人单位有权拒绝支付劳动者加班工资；但无论用人单位是否存在加班审批制度，有证据证明用人单位直接安排劳动者加班的，经安排延长的工作时间均应当认定属于加班。

二是实质性的工作内容。考察网络在线加班不能简单审查时间的经过，还应当审查劳动者的劳动力是否客观被用人单位占用，以确定用人单位对劳动者的支配性。如果劳动者仅需在线进行简短回复、转发消息等简单处理，不具有实质性的工作内容和劳动产出，一般认为属于履行劳动合同的附随义务，劳动者应基于岗位职责给予必要的协助和配合，不宜认定为加班；如果工作内容超出一般简单沟通的范畴，劳动者付出实质性劳动内容，具有实质性的工作内容和明确的工作产出，应认定为加班。

三是明显占用劳动者的休息时间。用人单位安排加班之所以应当支付加班工资，本质上是对减损劳动者休息权所付出的法定对价，故对休息权是否构成减损是判断是否构成加班的要素。如果用人单位的工作具有偶发性和临时性特征，并未实质影响劳动者生活休息的，可以不认定为加班；反之，如果对劳动者休息时间的占用具有持续性或连贯性特征，应当认定为加班。

裁判机关应确立新形势下网络在线形式加班的审查认定标准，保障劳动者合法权益，让“加班”不再“隐形”。

编写人：北京市第一中级人民法院 王丽蕊 余志燕

北京市门头沟区人民法院 凌志颖

提成工资中“款到提成”的效力认定

——某广告公司诉文某劳动争议案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

重庆市第三中级人民法院(2023)渝03民终1363号民事判决书

2. 案由：劳动争议

3. 当事人

原告(被上诉人):某广告公司

被告(上诉人):文某

【基本案情】

2020年6月15日,文某与某广告公司签订劳动合同,约定某广告公司聘请文某从事广告销售工作,每月业绩考核工资为当月业绩总额的5%(封顶为每月20万元),享受业绩提成,价差的85%归销售人员所得。文某在某广告公司处上班期间,某广告公司按约定每月支付了文某业绩考核工资和部分业务提成及价差。2023年1月3日,某广告公司制作了文某价差、业务提成及客户奖金情况统计表,载明某广告公司应支付文某价差、业务提成及客户奖金合计420173元,客户款项未收部分的价差、业务提成合计198235元,客户奖金为211150元;客户款项已收部分的业绩工资、绩效工资、价差、业务提成合计10788元。文某向劳动仲裁委申请劳动仲裁,请求裁决某广告公司支付其业务提成奖金。2023年3月17日,劳动仲裁委裁决某广告公司支付文某业务提成奖金209023元。

2021年8月，某广告公司(乙方)与某置业公司、某商业公司(甲方)签订的广告合同协议，约定甲方委托乙方制作、发布公交车身广告费用冲抵乙方向某置业公司购买商铺部分费用。某广告公司法定代表人刘某在诉讼中陈述B广场项目房屋产权已登记在其名下。2022年10月18日，某广告公司向某置地公司出具《广告费用抵款证明》，证明某置地公司以某商铺抵偿其欠付某广告公司的广告费用。

【案件焦点】

1. 某广告公司应否支付文某客户未回款的业务提成；2. 广告费用抵款合同履行结果是否影响文某业务提成。

【法院裁判要旨】

重庆市涪陵区人民法院经审理认为：用人单位应按劳动合同约定，及时足额支付劳动者劳动报酬。根据双方签订的员工劳动合同及《销售部管理办法》约定，业务奖金及价差支付时间为合同款项全部收取完毕后，结合文某签字确认的客户奖金情况统计表标记为“已收”部分的金额为10788元，故某广告公司应支付文某业绩工资、价差、业务提成10788元。

重庆市涪陵区人民法院依照《中华人民共和国劳动合同法》第三十条，《工资支付暂行规定》第八条之规定，判决如下：

一、驳回某广告公司的诉讼请求；

二、某广告公司于本判决生效后十日内支付文某业绩工资、价差、业务提成10788元。

文某不服一审判决，提起上诉。重庆市第三中级人民法院经审理认为：文某与某广告公司就提成工资约定“客户款项收取完毕作为支付时间”符合法律规定，可以作为确定双方权利义务的依据。对《统计表》中客户款项收取情况标记为“已收”部分的业务提成10788元，予以确认。某广告公司对同意支付文某招商银行项目业务提成2750元，予以确认。

对于B街和B广场项目的广告费用，某广告公司已与相对方协商一致以商

铺冲抵,某广告公司亦向B街项目相对方出具《广告费用抵款证明》,某广告公司法定代表人认可B广场项目房屋产权已登记其名下,应视为文某已完成前述项目的回款义务,某广告公司应支付前述项目的业务提成116160元。某广告公司辩称因公司经营出现问题涉及给客户退款,前述广告合同未履行完毕,业务提成支付条件不成就。法院认为,某广告公司该行为系企业自身应承担的市场经营风险变相转嫁于文某,其明显加重了劳动者的负担,有违公平原则,故对其该项辩称不予采纳。文某未能举示充分证据证明其他项目提成支付条件已经成就,依法应当承担举证不能的不利后果。需指出,某广告公司应积极采取有效措施促使提成项目相对方支付项目回款,使己方在和劳动者所约定的项目提成的付款条件成就,若长期怠于向第三方主张权利,将依法承担不利法律后果。

重庆市第三中级人民法院依照《中华人民共和国劳动合同法》第四条第四款,《中华人民共和国劳动法》第四十七条,《最高人民法院关于审理劳动争议案件适用法律问题的解释(一)》第五十条,《工资支付暂行规定》第八条,《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第三项,《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条规定,判决如下:

一、撤销重庆市涪陵区人民法院(2023)渝0102民初2370号民事判决;

二、某广告公司在判决发生法律效力后十日内向文某支付业绩工资、绩效工资、价差、业务提成共计129698元;

三、驳回文某的其他诉讼请求。

【法官后语】

实践中,涉及销售回款的用人单位常与劳动者约定提成工资实行“收付原则”,即用人单位收到第三方支付款项后再按约定比例作为提成工资支付给劳动者。本案即涉及提成工资制度的法律适用问题。如何在审判中准确把握提成工资中“款到提成”约定效力及举证责任分配,是本案中值得研究探讨的重点问题。

1. 提成工资中“款到提成”约定的司法实践。对于“款到提成”约定是

否有效存在不同观点，有观点认为，提成的标准以及如何发放应当遵循协商原则，双方就提成发放形式、条件达成的约定应为有效；另有观点认为，项目回款属另一民事法律关系，相关回款能否最终收回受制于诸多因素，总体上属于用人单位的经营风险问题。目前，各地法院对于涉提成案件的裁审意见尚未形成统一意见，对于劳动者离职后所主张的提成项目回款的举证责任分配亦存在分歧。部分法院认为双方有约定按约定，劳动者主张提成款，应由其承担相应回款到账的举证责任；部分法院认为离职情况下，回款是否到账的举证责任应由用人单位承担。

2. 提成工资的性质及其分配方式。提成工资是指用人单位将销售收入或者纯利润按照一定比例分配给员工，根据员工的工作量或者其他指标计算发放的劳动报酬，较之固定工资具有一定的激励性。提成工资分配方式是公权力介入下的有限意思自治。一方面，劳动合同作为一种不完全私法合同，渗透了国家公权力必要干预的、以社会公共利益为本位的合同，社会性是其本质属性。实践中，用人单位为了实现自身利益最大化，可能出现打着“用工自主权”的口号对劳动者合法权益进行“合法侵害”的情形，为此，《中华人民共和国劳动合同法》第四条明确了劳动规章制度的合法要件。另一方面，《中华人民共和国劳动合同法》虽然有一定的社会属性，但仍可归属于民法，民法的相关原则适用于劳动合同中，双方当事人可以按照自己的意志，在不违反法律规定且协商一致的前提下订立“款到提成”约定，尊重当事人基于真实意思表示对相互间权利义务的安排，无疑是实现劳动关系稳定的重要内涵。故，在司法实践中应对用人单位的自主用工权给予必要尊重。

3. 关于提成工资中“款到提成”的具体适用标准。首先，准确识别劳动规章制度和劳动合同效力。“款到提成”对劳动者的约束力主要来源于用人单位规章制度和劳动合同约定。故，判断“款到提成”是否对劳动者适用，需判断用人单位规章制度是否合法合理且程序正当，劳动合同约定是否系双方的真实意思表示。当合法有效的单位规章制度、协商一致的劳动合同中确有“款到提成”约定，则双方均应按该约定进行提成工资的发放。其次，明晰提成项目回

款的举证责任。劳动者在职情形下，无论是基于其享受的权利(较大提成)抑或契约精神，其对于提成项目的回款会积极向第三方催收，劳动者对于相对方是否实际付款知悉且掌握相关证据，劳动者主张提成工资时用人单位抗辩相对方未回款的，除劳动者有证据证明用人单位掌握此类相关证据的，劳动者应举示相应证据证明提成项目已回款。劳动者离职情形下，劳动关系的终止意味着劳动者无权向提成项目的相对方追收项目回款，而离职职工以个人名义向第三方主张相关款项亦难谓正当。随着时间的推移，离职职工对双方财务往来知悉程度日渐下滑，也存在合同相对方基于后期商业合作需要而拒绝为离职职工出具相关证明材料的情形。故，在劳动者离职后的合理期限内，劳动者仍应承担合同相对方回款的举证责任，但此时劳动者举示初步回款证据即可，对其举证能力不宜过于苛求。用人单位认为离职职工所主张的业务提成支付条件不成就的，可举示财务资料、催款材料等证据证明合同相对方未回款。最后，合理平衡双方利益。对于用人单位规定劳动者辞职不得享有其已经付出实际劳动的提成工资或劳动者应当承担相对方逾期付款责任等，属于将市场经营风险转嫁于劳动者，应给予负面评价。对于用人单位违约导致相对方以正当理由拒绝支付提成回款的，应重点审查用人单位的违约行为，若非因劳动者所致，用人单位不能以“款到提成”约定或规定对抗劳动者的提成款合理诉求。此外，劳动关系解除后，用人单位在相对方付款条件未成就的情形下，不积极向相对方主张权利或放弃相关权利，致使向劳动者提成款付款的条件迟迟不能成就或提成款兑现难度增加，属于用人单位不正当地阻止条件成就，或长期怠于向第三方主张权利的，可认定用人单位不当地阻止提成付款条件成就，视为支付条件已成就。

本案中，文某作为公司销售人员，其工资薪酬包含了业务提成，单位规章制度明确业务提成支付条件为客户回款，双方在劳动合同期间亦是按该约定进行发放业务提成，故“款到提成”的相关约定具有约束力。文某离职后主张业务提成，其在合理期间内应当承担提成项目客户回款的举证责任，法院对其举示证据证明的项目客户回款问题予以支持。文某未能举示充分证据证明其他项

目提成支付条件已经成就，依法应当承担举证不能的不利后果。对于某广告公司已与相对方协商一致以商铺冲抵广告费用，相关房屋产权已登记至某广告公司法定代表人名下，应视为文某已完成前述项目的回款义务。因此，法院终审判决最终确认某广告公司应当支付文某业务提成129698元。

编写人：重庆市第三中级人民法院 周建峰

“待公司账户解封后支付工资”的约定无效

—L 公司诉马某劳动争议案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

北京市第一中级人民法院(2023)京01民终774号民事判决书

2. 案由：劳动争议

3. 当事人

原告(上诉人): L 公司

被告(被上诉人): 马某

【基本案情】

马某于2017年入职L公司，担任采购工程师，双方签订了三年期限的劳动合同。2021年6月18日，L公司(甲方)与马某(乙方)签订《终止劳动合同劳动关系协议》，其中正面载明：“L公司与您本人协商一致，公司与您签订的劳动合同关系已于2020年11月30日终止。劳动合同关系延长期于2021年6月18日终止。现就相关事宜明确如下……甲方承诺支付乙方自2020年1月1日起到2021年5月31日终止劳动合同延长期为止欠发工资及停工停产生活费

41109.38元……按照本终止劳动合同协议的备注#1、#2条款的约定处理……”该协议反面载明：“备注：#1.在L公司受到某集团非法集资案件的第三方牵连，杭州公安机关为调查取证而冻结公司银行账号……无法使用公司账户资金支付任何费用……#2.……公司承诺在杭州公安解决集团案件能解封公司账户允许公司支付的第一时间或案件进入司法程序处理法院判决允许公司拍卖财产对员工工资、社保支付的第一时间，履行本协议的承诺。”

杭州市公安局某区分局出具两份《协助冻结财产通知书》，分别冻结L公司及L公司法定代表人账号。

马某以要求确认与L公司自2017年11月20日至2021年6月18日存在劳动关系及要求L公司支付工资、停工停产生活费为由申请仲裁，仲裁委作出仲裁裁决：1.确认马某与L公司自2017年11月20日至2021年6月18日存在劳动关系；2.L公司支付马某工资及停工停产生活费共计41109.38元。L公司不服仲裁结果，于法定期限内起诉。

经询，《终止劳动合同劳动关系协议》由L公司预先拟定，L公司未就将“解封公司账户”或“法院判决允许公司拍卖财产对员工工资、社保支付”作为支付条件与马某进行过协商提举证据，亦未就曾采取合理方式提示马某注意上述条款提举证据。双方均认可L公司账户仍处于冻结中，L公司称不清楚解除冻结时间。

【案件焦点】

《终止劳动合同劳动关系协议》中将“解封公司账户”或“法院判决允许公司拍卖财产对员工工资、社保支付”作为工资支付条件的约定是否有效。

【法院裁判要旨】

北京市海淀区人民法院经审理认为：针对L公司所持支付条件尚未成就这一主张，《终止劳动合同劳动关系协议》系L公司一方拟定，现该公司未就其中关于工资、停工停产生活费支付条件条款与马某进行协商提举证据，故该条款系格式条款。根据《中华人民共和国民法典》规定，采用格式条款订立合同

的，提供格式条款的一方应当采取合理方式提示对方注意免除或减轻其责任等与对方有重大利害关系的条款，按照对方的要求，对该条款予以说明。提供格式条款的一方未履行提示或者说明义务，致使对方没有注意或者理解与其有重大利害关系的条款的，对方可以主张该条款不成为合同的内容。本案中，工资及停工停产生活费支付条件与马某有重大利害关系，现L公司未就支付条件条款曾对马某进行提示及说明提举证据，故法院认定上述条款不作为《终止劳动合同劳动关系协议》的内容。退一步讲，即使不认定为格式条款，根据《中华人民共和国劳动合同法》第二十六条的规定，用人单位免除自己的法定责任、排除劳动者权利的劳动合同条款无效。L公司针对支付马某工资、停工停产生活费设置条件，而工资、生活费是劳动者提供劳动的基本对价和生活保障，现L公司亦自认解封时间无法确定，故上述支付条件能否达成及何时达成均处于无法确定的状态。该条款违反了“用人单位应及时足额支付劳动者劳动报酬”这一法律规定，排除了马某作为劳动者及时获得劳动报酬及生活保障的基本权利，应属无效。综上，L公司所持无须立即支付马某工资及停工停产生活费的诉讼请求，于法无据，法院不予支持，进而判令L公司支付马某工资及停工停产生活费41109.38元。

北京市海淀区人民法院依据《中华人民共和国民法典》第四百九十六条，《中华人民共和国劳动合同法》第二十六条之规定，判决如下：

一、确认马某与L公司于2017年11月20日至2021年6月18日存在劳动关系；

二、L公司于本判决生效之日起十日内支付马某工资及停工停产生活费41109.38元。

L公司不服一审判决，提出上诉。北京市第一中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项之规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

所谓附条件的劳动报酬，是指用人单位在规章制度中规定或在劳动合同中

约定劳动报酬的支付条件，待该条件达成时，向劳动者支付对应的劳动报酬。

用人单位针对劳动报酬设置支付条件的法律效力在司法实践中存在争议。

一、用人单位能否就劳动报酬设置支付条件

《中华人民共和国劳动法》第五十条规定，工资应当以货币形式按月支付给劳动者本人。不得克扣或者无故拖欠劳动者的工资。同时，相关法律法规亦通过最低工资标准、工资支付周期、工时制度等对工资支付作出全面规制。从上述规定来看，按月向劳动者支付工资是用人单位的法定义务，不应附加任何条件。但随着市场经济的发展，劳动报酬呈现多样化趋势，除按月领取工资、加班费外，还包括绩效工资、年终奖、提成、股权激励等，而是否完成一定业绩、是否达到考核分值等会被作为支付相关报酬的依据。如果不允许就此作出约定，则违背当事人的意思自治原则，亦与实践背道而驰。究其原因，劳动法兼具公法和私法属性，在保障劳动者基本权利的前提下，亦需尊重企业的经营自主权及劳动双方的自由意志，故在一定范围内应允许劳动双方针对劳动报酬设置支付条件。

二、用人单位就劳动报酬设置支付条件的边界

《中华人民共和国劳动合同法》第二十六条规定，用人单位免除自己的法定责任、排除劳动者权利的劳动合同无效或者部分无效。从劳动报酬的范围来看，用人单位仅在其自主经营权范围内有权设置支付条件，而不能就劳动者的基本工资、加班工资等正常提供劳动的对价设置支付条件。一般来说，用人单位可根据自身经营状况，为激励劳动者勤勉工作而针对奖金、提成等劳动报酬设置支付条件，且劳动者的工资总额及支付周期不能违反法律法规中的强制性规定。同时，用人单位仅可通过与劳动者协商一致或经民主程序制定规章制度的方式针对劳动报酬设置支付条件，而不能单方作出决定。

三、附条件支付劳动报酬条款的司法审查

司法实践中，针对附条件支付劳动报酬纠纷的审理，需要着重注意以下方面：(1)对“条件”的认定。条件必须是将来发生与否不确定的、双方当事人意定、不违反法律强制性规定的事实。(2)条件成就与否的举证责任分配。根

据“谁主张，谁举证”的举证分配规则，对积极事实的存在，需要主张之人承担举证责任。法律有特殊规定的，依照该规定执行。例如，《最高人民法院关于审理劳动争议案件适用法律问题的解释（一）》第四十四条规定，因用人单位作出的开除、除名、辞退、解除劳动合同、减少劳动报酬、计算劳动者工作年限等决定而发生的劳动争议，用人单位负举证责任。故，在以考核结果或公司经营业绩、部门业绩作为劳动报酬支付条件的情况下，由用人单位就相关条件未成就承担举证责任。（3）特殊情况下条件成就与否的拟定。《中华人民共和国民法典》第一百五十九条规定，附条件的民事法律行为，当事人为自己的利益不正当地阻止条件成就的，视为条件已成就；不正当地促成条件成就的，视为条件不成就。条件成就与否本为不能确定的事实，不能受任何一方当事人不正当地促成或阻碍，否则都难免对他方当事人产生不公平的结果。

编写人：北京市海淀区人民法院 董洪辰

工资异议期条款的效力认定

——赵某诉某信息公司劳动争议案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

北京市第一中级人民法院(2023)京01民终2681号民事判决书

2. 案由：劳动争议

3. 当事人

原告(上诉人): 赵某

被告(上诉人): 某信息公司

【基本案情】

赵某于2013年8月23日入职某信息公司,担任高级副总裁。双方于2018年8月3日签订了无固定期限劳动合同,该劳动合同第十八条约定“员工如对发放的薪资有异议,应在发薪日后五个工作日内提出书面意见,逾期未提出则视为确认和认同”。某信息公司未发放赵某2018年1月至2019年3月的绩效工资,该公司主张未予发放的原因有二:一是赵某在此期间内没有业绩,故不享有绩效工资;二是根据双方劳动合同第十八条的约定,其未在发薪日后五个工作日内提出书面意见,应视为其认可已经发放的工资金额。经询,赵某表示就某信息公司未发放2018年1月至2019年3月绩效工资一事,其仲裁前未提出异议。诉讼期间,某信息公司未能就赵某的绩效考核标准、绩效考核结果以及与绩效考核结果相对应的客观依据提供证据予以证明。赵某月工资标准为30000元,其中基本工资21000元、绩效工资9000元。该案经仲裁前置程序后,赵某因对仲裁结果不服,向北京市海淀区人民法院起诉,请求法院判令:某信息公司向赵某支付:(1)2014年1月1日至2018年12月31日延时及休息日加班工资180000元;(2)2018年1月1日至2019年12月31日未休年假工资81690元;(3)2019年5月1日至2020年4月30日工资390000元;(4)2018年1月1日至2019年3月31日绩效工资135000元;(5)2017年成立合资公司项目奖金100000元。

【案件焦点】

劳动双方存在工资异议期条款约定,劳动者若未在约定的异议期内提出异议,后又向用人单位主张欠付工资的,用人单位可否以工资异议期条款为由进行抗辩,进而排除劳动者对工资的主张,即工资异议期条款的效力应作何评价。

【法院裁判要旨】

北京市海淀区人民法院经审理认为:就绩效工资一节,赵某未于劳动合同中约定的工资异议期内就绩效工资的发放提出异议,法院评价如下:第一,劳

劳动者未及时就薪资数额减少向用人单位提出异议，并正常提供劳动，该状态属于沉默行为，单纯的沉默不构成对薪资减少的确认或认可。第二，本案劳动合同约定的工资异议期限缩了法定时效期间，属于用人单位免除自己的法定责任、排除劳动者的合法权利。综上，法院认定赵某未就绩效工资提出异议，并正常提供劳动，不构成对公司不予发放绩效工资的默示认可，故应当支付赵某涉诉期间的绩效工资。

北京市海淀区人民法院依照《中华人民共和国劳动法》第四十四条、第四十五条，《中华人民共和国劳动合同法》第三十条，《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》第二十七条，《最高人民法院关于审理劳动争议案件适用法律若干问题的解释（三）》第九条，《北京市工资支付规定》第十二条之规定，判决如下：

- 一、某信息公司支付赵某绩效工资135000元；
- 二、某信息公司支付赵某加班工资13793.1元；
- 三、某信息公司支付赵某未休年假工资16551.72元；
- 四、某信息公司支付赵某成立合资公司的项目奖金50000元；
- 五、驳回赵某的其他诉讼请求。

赵某与某信息公司均不服一审判决，提出上诉。北京市第一中级人民法院经审理认为：双方于劳动合同中约定了工资异议期条款，该条款并不能因劳动者未于异议期内提出书面意见而免除用人单位对工资的支付义务，原因在于：其一，劳动者于劳动关系存续期间对用人单位在人格、经济、组织上具有从属性，隶属于用人单位并接受管理，故可能由于多种原因无法以书面形式及时向用人单位提出工资异议，此时并不能以单纯的沉默行为即视为劳动者对工资的认可。其二，用人单位是否向劳动者足额发放工资系客观事实，在劳动者正常提供劳动的情况下获得相应的工资是其法定权利，故劳动者未于劳动合同约定的工资异议期内提出书面

意见并不能视为劳动者对工资请求权作出放弃的处分。其三，劳动者就薪酬待遇问题提起仲裁申请的时效期间为劳动合同解除或终止后1年内，而上述劳动合同约定的内容显然较法律规定限制了劳动者追索劳动

报酬的权利，系某信息公司免除自己的法定责任、排除劳动者的合法权益，属于《中华人民共和国劳动合同法》中规定的劳动合同无效情形，因而劳动合同中对于工资异议期的约定并不产生效力。由此，一审法院认定某信息公司应当支付赵某涉诉期间绩效工资并无不当。

北京市第一中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

工资异议期条款，是指用人单位与劳动者在劳动合同中约定，劳动者未在约定的异议期内就工资实际支付情况向用人单位提出异议，即视为对工资数额的认可。对于工资异议期条款的效力应作何评价，司法实践中存在不同的观点：第一种观点认为，工资异议期条款属于双方当事人的意思自治，应当认定有效，劳动者未于异议期内提出异议系以沉默的方式认同已经发放的工资数额。第二种观点认为，工资异议期条款排除了劳动者的合法权益，属于《中华人民共和国劳动合同法》规定的无效情形。

本案中，合议庭采取了第二种观点，认为不能够以此为由认定劳动者以沉默的意思表示产生变更工资标准或者确认工资金额的法律后果。

一、无法产生变更劳动合同的法律后果

变更劳动合同无论是采取书面形式还是口头形式，均要以用人单位和劳动者就劳动合同变更的内容协商一致为前提。但就工资异议期条款的效力而言：其一，用人单位协商变更工资标准的要约并不明晰。用人单位可能基于多种理由向劳动者支付少于往期金额的工资，但不附加工资金额的解释以及降低工资标准的意思联络，不能被认定为用人单位作出了协商降低工资标准的要约。其二，如果按照工资异议期条款成立的逻辑来推演，用人单位支付低于原水平的工资，劳动者未提出异议即完成协商一致的结果，实质上属于预先剥夺了劳动者与用人单位就变更劳动合同内容进行协商的程序性权利，并不符合“用人单位与劳动者协商一致”的条件。

二、无法发生合意确认工资金额的法律后果

《中华人民共和国劳动合同法》第二十六条第一款第二项规定：“下列劳动合同无效或者部分无效……（二）用人单位免除自己的法定责任、排除劳动者权利的……”笔者认为，工资异议期条款存在排除劳动者权利的情形，劳动者即便未在异议期内提出异议，也不能被认定为作出认可工资金额的表意，理由如下。

其一，异议期条款排除了劳动者的时效权利。用人单位未及时足额支付劳动报酬的，劳动者的救济渠道有三。一是通过一裁两审程序向劳动人事争议仲裁委员会申请劳动争议仲裁，自劳动合同解除或终止后适用一年的仲裁时效；二是直接向人民法院提起诉讼；三是人民法院申请支付令，渠道二和渠道三均适用三年的诉讼时效。实践中，工资异议期条款约定的异议期皆在劳动关系存续期限内，通常时间为发薪后十日以内，均明显短于仲裁和诉讼时效期间。该约定虽不能排除劳动者的起诉权，但实质目的在于排除异议期满后劳动者的胜诉权，本质上是对劳动者仲裁和诉讼时效权利的不当限制和部分排除。

其二，异议期条款加剧劳动者的弱势地位。有别于普通民事法律关系，在劳动关系中，用人单位和劳动者并非平等的民事主体，而劳动者对用人单位具有从属性，劳动者势必隶属于用人单位并接受其管理，于内部形成“此强彼弱”的非对称关系。在劳动关系存续期间，劳动者的表意自由实质上受到限制，劳动者出于追求工作的进步、害怕被职场边缘化等考虑，往往不便于通过非常直接的方式维权，其进行维权的能力也弱于用人单位。而工资异议期条款必然加剧劳动者的弱势地位，进一步限缩劳动者维权的能力。

综合以上论述，笔者认为，劳动者诉请支付欠付工资，用人单位以工资异议期条款为由进行抗辩的，人民法院应不予支持，仍需按照举证责任分配规则，根据在案证据，进行实质审查和裁判。

编写人：北京市第一中级人民法院 王丽蕊 高愉佯

未订立书面劳动合同应付二倍工资差额诉讼时效的认定

—— 朱某诉某环卫服务中心劳动争议案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

河南省驻马店市中级人民法院(2023)豫17民终4978号民事判决书

2. 案由：劳动争议

3. 当事人

原告(上诉人): 朱某

被告(上诉人): 某环卫服务中心

【基本案情】

朱某自2017年6月到某环卫服务中心工作, 岗位为街道冲洗车司机, 实行半日制工作。某环卫服务中心以月工资3000元的标准从2017年6月向朱某支付劳动报酬, 支付至2021年10月。自2021年11月开始由新蔡县国库支付中心代付朱某的工资。朱某在某环卫服务中心工作期间, 双方未签订书面劳动合同。2023年6月27日, 朱某向新蔡县劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁, 新蔡县劳动仲裁委员会于2023年7月4日作出不予受理通知书, 理由为不属于规定的争议范围。朱某不服该通知书, 遂向法院提起诉讼。朱某向新蔡县劳动仲裁委员会申请仲裁及提起诉讼时仍然在某环卫服务中心从事街道冲洗车司机工作。朱某于2023年7月24日不再到某环卫服务中心工作。朱某提出如下诉讼请求: 依法判令某环卫服务中心向朱某支付因未签订书面劳动合同的双倍工资差额33000元。

【案件焦点】

朱某所提出的请求某环卫服务中心支付因未签订书面劳动合同的双倍工资差额，是否超过诉讼时效。

【法院裁判要旨】

河南省新蔡县人民法院经审理认为：根据《中华人民共和国劳动合同法》第八十二条第一款规定：“用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，应当向劳动者每月支付二倍的工资。”某环卫服务中心未与朱某签订书面劳动合同的事实存在，故应支付朱某未签订书面劳动合同11个月的工资差额33000元。

河南省新蔡县人民法院依照《中华人民共和国劳动法》第七条、第十条、第二十四条、第八十三条，《中华人民共和国劳动合同法》第七条、第八十二条第一款、第八十七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条第一款、第一百四十五条规定，判决如下：

- 一、朱某与某环卫服务中心存在事实劳动关系；
- 二、解除朱某与某环卫服务中心之间的事实上的劳动关系；
- 三、限某环卫服务中心于本判决生效之日起十日内支付朱某未签订书面劳动合同双倍工资差额33000元；
- 四、驳回朱某的其他诉讼请求。

朱某与某环卫服务中心均不服一审判决，提出上诉。河南省驻马店市中级人民法院经审理认为：用人单位应支付给劳动者未订立书面劳动合同应付二倍工资中的一倍应为正常的劳动报酬，另一倍赔偿金则不是基于劳动者提供的劳动，而是基于用人单位的违法行为产生的惩罚性赔偿金，性质上与劳动报酬不同。因此，案涉双倍工资差额33000元，应适用普通仲裁时效的规定，申请仲裁的时效期间为1年，从当事人知道或者应当知道其权利被侵害之日起计算。朱某于2017年6月到某环卫服务中心工作，于2023年6月27日提起仲裁申请，该申请已超1年的仲裁时效，对朱某请求的因未签订书面劳动合同的双倍工资差额33000元，不予支持。

河南省驻马店市中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第二项规定,判决如下:

一、维持河南省新蔡县人民法院(2023)豫1729民初4487号民事判决第一项、第二项;

二、撤销河南省新蔡县人民法院(2023)豫1729民初4487号民事判决第三项、第四项;

三、变更河南省新蔡县人民法院(2023)豫1729民初4487号民事判决第三项为某环卫服务中心于本判决生效之日起十日内支付朱某经济补偿金19500元;

四、驳回朱某的其他诉讼请求。

【法官后语】

一、“二倍工资”性质的认定

未签订劳动合同应付“二倍工资”不属于劳动报酬,应当认定为惩罚性赔偿。首先从立法目的上分析,由于在劳动关系中,用人单位与劳动者地位的不平衡,不签订劳动合同,将给劳动者维护权益带来较大的困难,因此,为了对劳动者权益进行倾斜保护,我国劳动法律明确规定用人单位要与劳动者签订书面劳动合同,并设置“二倍工资”罚则以督促用人单位及时与劳动者签订书面劳动合同,强化对劳动者权益的保护,维护用工关系的稳定与和谐。从“二倍工资”取得原因分析,其不同于劳动报酬基于劳动者履行的劳动所获得的对价,而是因用人单位未及时履行法律所规定的与劳动者签订书面劳动合同的义务所受处罚。因此,“二倍工资”是因法律规定而产生,本质上不属于劳动报酬。此外,从法律解释方面分析,虽然法律条文将“二倍工资”表述为“工资”,但不能单纯地从文义解释的角度理解,应当结合体系解释及目的解释,综合分析其真正内涵。《中华人民共和国劳动合同法》第八十二条位于“法律责任”一章,该章主要是对用人单位、劳动者以及劳动行政部门和其他主管部门及其工作人员违反相关法律法规的不利后果的规定。综上,“二倍工资”系违反法定义务的用人单位所应承担的法律责任,具有法定性、惩罚性的特征,

其性质应属于惩罚性赔偿金。

二、“二倍工资”的时效制度

“二倍工资”的时效计算应从当事人知道或者应当知道其权利被侵害之日起计算。理由如下。

1. 从诉讼时效制度设置的法理来看,根据全国人大常委会法制工作委员会的解读,劳动争议诉讼(仲裁)时效规定具有三个方面重要意义:(1)尽快结束当事人间权利义务的不稳定状态,使之在法律上固定下来,从而维护劳动关系的稳定;(2)督促权利人及时行使请求权,有利于劳动关系的尽快解决;(3)方便劳动争议处理机构尽快介入劳动纠纷,有利于其及时调查取证,正确处理劳动纠纷。^①因此,时效制度的本质是督促当事人尽快行使权利,结束劳动纠纷,从而维护劳动关系的稳定。

2. 从“二倍工资”请求权的取得来看,“二倍工资”请求权无异于普通民事权利,“二倍工资”请求权是指用人单位由于违反了签订书面劳动合同的法定义务而使得劳动者所取得的权利,该请求权的取得与其他普通的民事权利别无二致,故诉讼时效也应适用普通仲裁时效从当事人知道或者应当知道其权利被侵害之日起计算一年的规定。

3. 从“二倍工资”性质的认定来看,根据《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》第二十七条第一款、第四款规定:“劳动争议申请仲裁的时效期间为一年。仲裁时效期间从当事人知道或者应当知道其权利被侵害之日起计算。……劳动关系存续期间因拖欠劳动报酬发生争议的,劳动者申请仲裁不受本条第一款规定的仲裁时效期间的限制;但是,劳动关系终止的,应当自劳动关系终止之日起一年内提出”,以及前文对于“二倍工资”性质的认定,“二倍工资”并非劳动报酬,系对于用人单位怠于履行与劳动者签订书面劳动合同法定义务的一种惩罚性赔偿,因此,“二倍工资”的时效理应适用《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》第二十七条第一款之劳动争议普通仲裁时效规定,即从当事

^①全国人大常委会法制工作委员会行政法室编著:《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法解读》,中国法制出版社2008年版,第92页。

